

Curso Examen de Grado

Módulo 3: Derecho de Bienes

Presentación.

Módulo 3: Derecho de Bienes

Los alumnos conocerán la regulación del Código Civil relativa los bienes, los modos de adquirir, así como las limitaciones al dominio y las acciones destinadas a proteger el dominio y la posesión.

Los alumnos deben ser capaces de conceptualizar los distintos tipos de bienes y derechos reales; comprender la regulación del dominio en el sistema nacional, como de los modos de adquirir la propiedad y demás derechos reales limitados; comprender, distinguir y aplicar las instituciones de mera tenencia, posesión y dominio, dando énfasis en sus relaciones y diferencias.

Los contenidos se presentan a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: De los Bienes.
- Unidad 2: De la Propiedad.
- Unidad 3: De la Tradición.
- Unidad 4: De la Posesión.
- Unidad 5: De la Prescripción Adquisitiva.
- Unidad 6: De las Limitaciones al Dominio.
- Unidad 7: De la Acción Reivindicatoria.

Durante el desarrollo del módulo, los y las participantes dispondrán de los contenidos a través del sitio del curso. Accederán a recursos como PDF, sitios de interés, multimedios y bibliografía relacionada con los contenidos, así como también se propone la realización de actividades de evaluación para medir sus progresos.

Las consultas sobre contenidos, serán canalizadas a través del correo electrónico y el Foro de Debate.

Bien, iniciemos ahora nuestro aprendizaje, revisando los contenidos del módulo 3.

Unidad 1: De Los Bienes.

Tema 1: Definición.



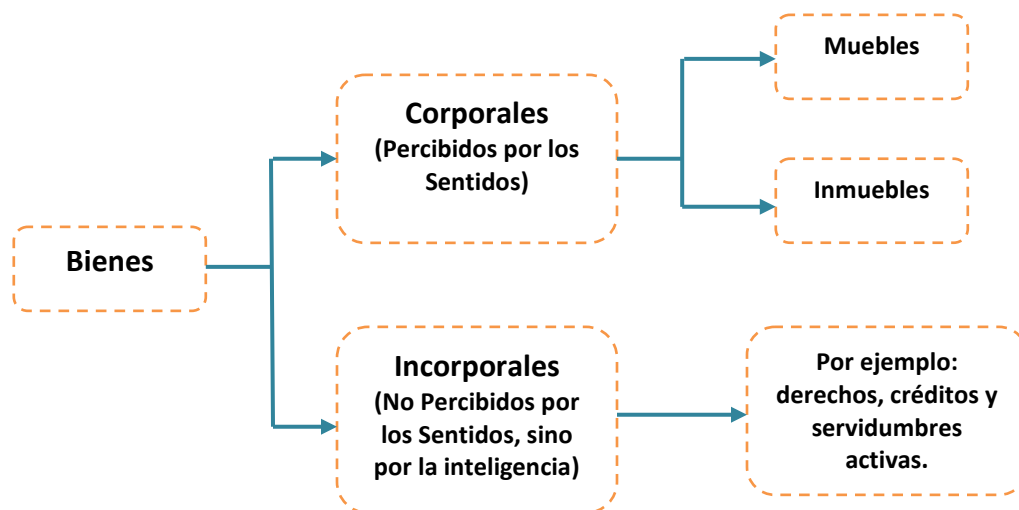
El concepto de bien, supone previamente la **noción de cosa**. En principio puede decirse que es cosa todo aquello que no es persona, o mejor, hablando en términos positivos, cosa es todo aquello que tiene existencia en el mundo material, ya sea en forma corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. Debemos desprender que la expresión cosa es el género, siendo los bienes una de sus especies.

En efecto, no todas las cosas son bienes sino que para que lo sean se requiere que las cosas, pudiendo procurar al hombre una utilidad, sean susceptibles de apropiación privada. **Lo que caracteriza a los bienes es la circunstancia de poder ser objeto de propiedad privada**, y no el hecho de producir una utilidad al hombre, pues hay cosas como el aire, el sol, la alta mar que producen gran utilidad, y que, no obstante ello, no son bienes por no poder ser objeto de apropiación por los particulares.

Tema 2: Diversas Clasificaciones de los Bienes.

2.1 Bienes Corporales e Incorporales.

El artículo 565 del CC dispone: **“Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Las corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa o un libro. Las incorporales son las que consisten en meros derechos, como los créditos o las servidumbres activas”**. La importancia de esta clasificación de las cosas en corporales e incorporales reside en que dos modos de adquirir, la ocupación y la accesión, se aplican sólo a las cosas corporales.



2.1.1 Cosas corporales.

El artículo 566 del CC señala: **“Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles”**. Conforme al primer inciso del artículo 567 del CC, muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Sin embargo, como veremos más adelante, hay cosas que, siendo muebles por su naturaleza, el legislador las considera inmuebles atendiendo a la fin a que están destinadas, conforme lo señalado en el artículo 570 del CC. Por su parte, el artículo 568 del CC dispone: **“Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos”**.

Tanto las cosas muebles como las inmuebles tienen en nuestro CC una distinta reglamentación, basada más bien en razones históricas que prácticas. Nuestro CC otorga gran preferencia a los inmuebles y ello se manifiesta en las siguientes diferencias:

1. La venta de bienes raíces debe efectuarse por escritura pública, al par que la de los muebles es un simple contrato consensual, conforme al artículo 1801 del CC.
2. La tradición de los inmuebles se efectúa por la inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces (en adelante “CBR”) conforme al artículo 686 del CC; la de los muebles por la simple entrega material conforme al artículo 684 del CC.
3. En materia de prescripción adquisitiva ordinaria, para los muebles se requiere un plazo de dos años; para los inmuebles cinco años, conforme al artículo 2508 del CC.

4. En materia de sucesión por causa de muerte, los herederos no pueden disponer de los inmuebles mientras no se les haya otorgado la posesión efectiva y se hayan practicado las inscripciones que contempla el artículo 688 del CC; exigencias que no se aplican a los bienes muebles.
5. La venta de los bienes raíces del pupilo debe hacerse en pública subasta y previo decreto judicial conforme a los artículos 393 y 394 del CC, requisitos que no rigen para la generalidad de las cosas muebles.
6. La acción rescisoria por lesión enorme sólo procede en la venta o permuta de bienes raíces, conforme al artículo 1891 del CC.
7. En materia de sociedad conyugal, porque mientras los bienes muebles que los esposos aportan al matrimonio o que los cónyuges adquieran a cualquier título durante él, entran a formar parte de la sociedad conyugal, los bienes raíces que se hayan aportado o que se adquieran durante el matrimonio a título gratuito, permanecen en el haber del respectivo cónyuge.
8. En lo referente a las cauciones, la prenda recae sobre los muebles, en tanto que la hipoteca se aplica a los inmuebles.
9. En materia penal también tiene importancia la distinción entre muebles e inmuebles, porque los delitos de robo y hurto sólo se refieren a cosas muebles, en tanto que el que se apropia de bienes ajenos inmuebles comete el delito de usurpación.
10. Dentro del sistema del CCO, los actos de comercio versan sobre bienes muebles, conforme lo dispuesto en el artículo 3.
11. Por último, en materia de competencia de los Tribunales, tiene facultad para conocer de una acción inmueble el juez del lugar en que éste está ubicado; en lo referente a acciones muebles, lo es el juez del lugar en que deba cumplirse la obligación, salvo ciertas excepciones.

a) Bienes muebles.

Pertenecen a esta categoría aquellos bienes que pueden transportarse de un lugar a otro sin que pierdan su individualidad, sin que dejen de ser lo que son. Se dividen en muebles por naturaleza y muebles por anticipación.

i. Muebles por naturaleza.

Pueden subclasificarse en semovientes y en cosas inanimadas. Son semovientes los que pueden transportarse de un lugar a otro por sí mismas, como los animales; y son cosas inanimadas las que sólo se mueven por una fuerza extraña, como una mesa o a un automóvil. Esta clasificación carece prácticamente de importancia porque ambas categorías de bienes están sujetos a un mismo régimen jurídico. El inciso final del artículo 567 del CC dispone que se exceptúan de esta categoría de bienes los que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino.

ii. Muebles por anticipación.

Son aquellas cosas que, aunque unidas a un inmueble, son consideradas como muebles por la ley, para el efecto de constituir derechos sobre ellas a favor de otra persona que el dueño. A ellos se refiere el artículo 571 del CC que dispone: “Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las yerbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se reputan muebles aún antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera”. La enumeración contemplada no es taxativa sino meramente ejemplar.

El artículo 571 del CC está basado en el principio que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Consecuentemente con el principio indicado, el artículo 1801 del CC dispone: *“La venta de los bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas, mientras no se ha otorgado escritura pública. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente se adhieren al suelo, como piedras y sustancias materiales de toda clase, no están sujetos a esta excepción”*.

Por otra parte, el artículo 574 del CC prescribe: *“Cuando por la ley o por el hombre se usa de la expresión bienes muebles sin otra clasificación, se comprenderá en ella todo lo que se entiende por cosas muebles conforme al artículo 567 del CC”*. Quedan pues excluidos los muebles por anticipación y los muebles incorporales.

iii. Muebles de una casa.

El inciso final del artículo 574 del CC dispone: “En los muebles de una cosa no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de arte y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías ni en general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa”.

b) Bienes inmuebles.

El artículo 568 del CC dispone: **“Los inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios o los árboles”**.

i. Inmuebles por naturaleza.

Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras u minas. Por su esencia, estas cosas son inmóviles.

ii. Inmuebles por adherencia o por accesión.

Los contempla el artículo 568 del CC al decir que inmuebles son las cosas que adhieren permanentemente a ella, como los edificios o los árboles. Los inmuebles por adherencia son aquellos bienes que, aunque sean muebles, se reputan inmuebles por estar permanentemente adheridos a un inmueble. La ley exige la concurrencia de dos requisitos para darle a un bien el carácter de inmueble por adherencia: primero, que la cosa esté adherida a un inmueble; y, segundo, que la adherencia sea permanente.

El artículo 569 del CC dispone: “Las plantas son inmuebles mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones, que puedan transportarse de un lugar a otro”. Hay que tener presente que los frutos de los árboles son también inmuebles por adherencia, ya que el artículo 571 del CC los considera muebles para el sólo efecto de constituir derechos a favor de otra persona que el dueño. Tampoco es necesario que la adherencia sea hecha por el propietario del inmueble, por lo demás, así lo han declarado en forma reiterada los Tribunales.

La enumeración que hace el artículo 568 del CC no es taxativa, como no lo es ninguno de los contenidos en esta materia. Esta circunstancia ha permitido a la jurisprudencia determinar que son inmuebles por adherencia los ferrocarriles, los túneles, los diques, las obras portuarias, las líneas telegráficas, etc.

iii. Inmuebles por destinación.

El artículo 570 del CC dispone: “Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento”. Si dejan de estar al servicio de un inmueble recobrarán su primitivo carácter de muebles. La norma reside en el deseo del legislador de evitar que una finca sea despojada de lo necesario para su explotación.

Del mismo artículo 570 se desprende que deben reunirse dos requisitos para dar a un bien mueble el carácter de inmueble por destinación: primero, la cosa debe estar destinada al uso, cultivo y beneficio de un inmueble; y, segundo, el destino de dichos bienes debe ser permanente. Doctrinariamente se dice que no basta la destinación permanente de dichos muebles para que pasen a ser inmuebles por destinación, sino que es preciso que dicho destino le sea dado por el dueño del inmueble. Pero como se han incluido también en los inmuebles por destinación algunos que lo son por su adherencia, no podemos decir que sea una característica de los inmuebles por destinación el que su destino les haya sido dado por el dueño del inmueble.

La diferencia entre los inmuebles por adherencia y los por destinación reside en que los primeros están unidos a un inmueble formando un solo todo, de manera que no pueden separarse de ellos sin detrimento; en cambio, los inmuebles por destinación no están unidos al suelo, pues si lo estuvieran perderían gran parte de su utilidad.

Conforme al artículo 572 del CC: “Las cosas de comodidad u ornato que se clavan o fijan de las paredes y que pueden removerse fácilmente sin detrimento de las mismas paredes, como estufas,

espejos, cuadros, tapicerías, se reputan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en las paredes, de manera que formen un mismo cuerpo con ellas, se considerarán parte de ellas, aunque puedan separarse sin detrimento”. Resulta, por lo tanto, que estas cosas pueden ser inmuebles si están embutidas en las paredes aunque puedan separarse sin detrimento, en cambio, si están simplemente clavadas o fijadas en la pared, son muebles. Es esto una cuestión de hecho que deberá apreciarse en cada caso concreto que se presente.

2.1.2 Cosas incorporeales.

El artículo 565 del CC dispone que las cosas incorporeales: **“Son las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Se caracterizan porque no pueden ser percibidas por los sentidos, sino por la inteligencia”**. Las cosas incorporeales se dividen en **derechos y acciones**, y éstos a su vez pueden ser **derechos reales y personales; muebles e inmuebles**. El CC dispone en el artículo 576 que los bienes incorporeales son los derechos reales o personales.



Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos reales nacen las acciones reales conforme al artículo 577 del CC. El artículo 579 del CC agrega que el censo, en cuanto se persigue a la finca acensuada, es también un derecho real.

Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales conforme lo dispuesto en el artículo 578 del CC.

Se puede efectuar el siguiente paralelo entre los **derechos reales y los personales**:

1. El número de derechos reales es limitado. No hay otros que los que la ley determina. El número de derechos personales es ilimitado, hay tantos derechos personales como relaciones jurídicas puedan crearse.
2. En el derecho real hay solo dos elementos: el sujeto activo y el objeto del derecho. En el derecho personal hay tres elementos: el acreedor, el deudor y el objeto.

3. El titular del derecho real se aprovecha directamente de la cosa objeto del derecho o de la utilidad que éste pueda proporcionar. La relación entre el titular del derecho personal, el acreedor, y la cosa es indirecta, es a través del deudor.
4. El derecho real, dado que se ejerce directamente en la cosa, sin consideración a determinada persona, es absoluto. El derecho personal es relativo.

Civilmente la acción es el derecho deducido en juicio; en Derecho Procesal, acción es el derecho constitucional que tienen los particulares para recurrir a los Tribunales de Justicia en defensa de un derecho que tienen o creen tener. Hemos visto que las acciones siguen una clasificación paralela a los derechos. La acción real es la que protege los derechos reales; la acción personal equivalente a derecho personal o crédito. La acción real, igual que el derecho real, es una acción absoluta, pues se ejerce sin respecto a determinada persona. La acción personal, en cambio, sólo puede ejercerse en contra de la persona que contrajo la obligación correlativa; es por tanto, una acción relativa.

La clasificación de los bienes en muebles e inmuebles se puede aplicar a los derechos y acciones. Pudiera parecer absurdo que las cosas incorpóreas pudieran ser muebles o inmuebles, sin embargo, el legislador admite esta clasificación con el objeto de determinar la competencia de los Tribunales y en atención a las cosas corporales sobre las que recaen los derechos y acciones. El artículo 580 del CC dispone: “Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se debe. Así la acción de usufructo sobre un inmueble es inmueble. Así la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada es inmueble, y la acción del que ha prestado dinero, para que se le pague, es mueble”. Resulta, por lo tanto, que el carácter de derecho mueble o inmueble va a depender de la naturaleza de la cosa sobre la que han de ejercerse o que se debe. Tanto los derechos reales como los personales pueden ser muebles o inmuebles. Nuestros Tribunales han declarado casos específicos: primero, las acciones de una sociedad anónima son bienes muebles; segundo, la acción dirigida a obtener la cancelación de una hipoteca es inmueble; tercero, la acción relacionada con el mandato es inmueble si se exige al mandatario la entrega de los bienes raíces adquiridos en el ejercicio de su encargo; y, cuarto, los derechos litigiosos deben estimarse como bienes muebles o inmuebles según sea la cosa que se persigue por medio de la acción ejercida en el juicio respectivo.

Los derechos personales pueden recaer sobre cosas o sobre derechos. Si la obligación es de hacer, atendiendo a si la cosa debida es un hecho o una abstención, no podría atenderse a la naturaleza de la cosa para calificar el derecho personal de mueble o inmueble. Por eso, el artículo 581 del CC dispone: “Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que un artífice ejecute la obra convenida, o resarza los perjuicios causados por la inejecución del convenio entra por consiguiente en la clase de los bienes muebles”.

Hay derechos y acciones, que atendiendo al hecho de no tener un carácter patrimonial o a otra causa, escapan a la clasificación de muebles o inmuebles. Ello sucede, por ejemplo, con la acción de divorcio, con la nulidad de matrimonio, etc. El derecho real de herencia también escapa a esta clasificación. En realidad la herencia es una universalidad jurídica, como se estudiará más adelante.

a) Bienes Principales y Accesorios.	Las cosas principales son aquellas que pueden subsistir en forma independiente, sin necesidad de otras, como por ejemplo, el suelo. Las cosas accesorias son las que están subordinadas a otras sin las cuales no pueden subsistir, como por ejemplo, los árboles. La importancia de esta clasificación reside en el hecho que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo accesorio puede presentarse a lo principal de diversas maneras: tanto el uno como el otro pueden ser inmuebles, o bien, lo principal puede ser inmuebles y lo accesorio mueble. La clasificación de las cosas en principales y accesorias se aplica también a las cosas incorporales, como por ejemplo, la servidumbre que es un derecho real accesorio al dominio.
b) Bienes Divisibles e Indivisibles.	Una cosa es físicamente divisible cuando puede ser separada en parte, sin que por ello pierda su individualidad, por ejemplo, los alimentos. Una cosa es intelectualmente divisible cuando es susceptible de dividirse en su utilidad, por ejemplo, dos copropietarios de un automóvil. Todas las cosas son divisibles, por lo menos intelectualmente; sin embargo, algunas son indivisibles por expresa disposición de la ley, por ejemplo, el derecho de servidumbre de tránsito, la prenda, la hipoteca, etc.
c) Bienes Muebles Consumibles y No Consumibles.	Las cosas consumibles son aquellas que no pueden hacerse uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan, conforme lo señalado en el segundo inciso del artículo 575 del CC. La consumibilidad no sólo comprende el uso material de las cosas, sino también su destrucción jurídica, es decir, la enajenación o disposición de bienes, como ocurre con el dinero. Las cosas inconsumibles son aquellas que no se destruyen por el primer uso, sin perjuicio que a la larga ello suceda, por ejemplo, un sombrero, un libro, etc. La consumibilidad o inconsumibilidad de una cosa es un atributo que depende de la sola naturaleza de ella, no es necesario compararla con otra. Esta clasificación tiene bastante importancia pues hay

	contratos que no pueden recaer sobre cosas consumibles, como ocurre con el arrendamiento o el comodato, y otros que sólo pueden tener por objeto cosas consumibles, como el mutuo. En conclusión, se puede sentar la siguiente regla: las cosas consumibles no pueden ser jamás objeto de una relación jurídica que dé al que goza de la cosa la calidad de mero tenedor.
d) Bienes Muebles Fungibles y No Fungibles.	Si una cosa en un acto jurídico está determinada en el género puede decirse que es fungible. Una cosa es fungible cuando en concepto de las partes, puede ser reemplazada por otra equivalente; puede decirse que son fungibles aquellas que tienen el mismo poder liberatorio, por ejemplo, el vino, la leche, el agua, etc. Una cosa no es fungible cuando no existe otra equivalente que pueda reemplazarla, por ejemplo, un cuadro famoso. La fungibilidad o no fungibilidad de una cosa va a depender de la voluntad de las partes: si la cosa es única en su especie, y el pago no puede efectuarse sino con dicha cosa, ella no es fungible. En segundo lugar, para saber si una cosa es o no fungible, es necesario compararla con otra que tenga el mismo poder liberatorio. Mientras la consumibilidad de las cosas depende de su naturaleza, la fungibilidad depende de la voluntad de las partes, pero estas dos cualidades están tan íntimamente ligadas que a menudo se cae en error; de ahí la aparente confusión del artículo 575 del CC. Examinando dicho artículo se llega a la conclusión de que el legislador no definió las cosas fungibles, sino que sólo se limitó a decir que entre las cosas fungibles están las consumibles y esto lo ha dicho porque ordinariamente las cosas consumibles son fungibles: generalmente pueden reemplazarse una por otras, a menos que las partes hayan acordado otra cosa. El inciso final del artículo 575 dispone: “Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas fungibles”. Hay aquí también una cierta impropiedad del lenguaje del legislador: las especies monetarias son consumibles en cuanto desaparecen para su dueño, pero son fungibles, en cuanto pueden reemplazarse por otras. La Corte Suprema ha declarado que conforme al artículo 575 del CC que define las cosas fungibles, éstas se dividen en dos categorías: aquellas que lo son por su naturaleza, o sea, porque no puede

	hacerse el uso conveniente sin que se destruyan y las especies monetarias que son fungibles sólo en cuanto su valor parece para el que las emplea como tales.
e) Bienes Comerciables e Incomerciables.	Esta clasificación atiende al hecho de si las cosas pueden o no ser objeto de actos jurídicos. La regla general es que las cosas sean comerciables. Los preceptos que contemplan la incomerciability de ciertas cosas son excepcionales; por lo tanto, deben interpretarse restrictivamente. La incomerciability puede ser absoluta o permanente, transitoria o momentánea. Son absolutamente incomerciables las cosas comunes a todos los hombres, conforme al artículo 585 del CC, los bienes nacionales de uso público, los derechos personalísimos, las cosas destinadas al culto divino conforme a los artículos 586 y 587 del CC, etc. Son transitoriamente incomerciables las cosas enumeradas en los números tercero y cuarto del artículo 1464 del CC: “Las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello y las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio. La importancia de esta clasificación reside en el hecho que las cosas incomerciables no pueden ser adquiridas por prescripción, de conformidad a lo establecido en el artículo 2498 del CC.
f) Bienes Apropiables e Inapropiables.	Las cosas apropiables, es decir, los bienes, pueden tener dueño o carecer de él. Los bienes que carecen de dueño se llaman mostrencos, los inmuebles en estas condiciones toman el nombre de vacantes. En nuestra legislación, sólo pueden existir los bienes mostrencos, pues respecto de los vacantes, el artículo 590 del CC establece un derecho a favor del Fisco. Las cosas inapropiables son aquellas sobre las cuales no se puede constituir dominio, y son llamadas por el artículo 585 del CC, cosas comunes a todos los hombres, como el aire, el sol, etc. El uso y goce de las cosas comunes a todos los hombres son determinados entre individuos de una nación por las leyes de ésta y entre distintas naciones por el Derecho Internacional, conforme lo dispuesto en el inciso final del artículo 585 del CC. Las cosas apropiables son aquellas que pueden ser objeto de dominio y que nosotros hemos denominado bienes. Las cosas apropiables pueden ser bienes de derecho privado y bienes de derecho público o bienes nacionales. Bienes de dominio

	privado son aquellos que pertenecen o que pueden ser adquiridos por los particulares. Bienes nacionales o bienes de dominio público son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, conforme al inciso primero del artículo 589 del CC. Se subdividen en bienes nacionales de uso público y bienes del Estado o fiscales, según su uso pertenezca o no a todos los habitantes de la República, conforme lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 589 del CC.
g) Bienes Singulares y Universales.	Son bienes singulares los que constituyen una unidad, natural o artificial. Son bienes universales las agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero que forman un todo funcional y están relacionados por un vínculo determinado. Las universalidades pueden ser de hecho o jurídicas. Las universalidades de hecho son un conjunto de bienes que, no obstante conservar su individualidad, forman un todo al estar unidos por un vínculo de igual destino, generalmente económico. Los bienes que la componen pueden ser de la misma o distinta naturaleza. Esto permite distinguir dentro de las universalidades de hecho dos categorías: las colecciones y las explotaciones. El vínculo que une a las cosas singulares para formar la universalidad de hecho es el común destino o finalidad, que generalmente es de carácter económico. La doctrina entiende que la universalidad de hecho sólo comprende bienes, es decir, sólo elementos activos y no pasivos o deudas, que serían aceptables únicamente en las universalidades jurídicas. Las universalidades de derecho son un conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas consideradas jurídicamente como formando un todo indivisible. Contienen tanto elementos activos como pasivos. En el derecho chileno la universalidad jurídica típica es la herencia. No existe en nuestro ordenamiento una reglamentación especial de las universalidades.
h) Bienes Presente y Futuros.	Atendiendo a la existencia real de los bienes al momento de crearse una relación jurídica se clasifican en presentes o futuros. Los presentes son los que a un momento determinado, al celebrarse una relación jurídica, tienen una existencia real. Los futuros son los que a esa época no existen y tan sólo se espera que existan.

Unidad 2: De La Propiedad.

Evolución histórica.

Se ha dicho que la actual organización social descansa sobre dos bases: la propiedad y la familia. El derecho de propiedad es el más amplio y completo de los derechos reales, pues otorga a su titular la plenitud de las facultades que se puede tener sobre una cosa. La labor de los filósofos y economistas de la revolución francesa hace triunfar la idea de libertad para cultivar y enajenar las tierras. A fines del siglo XIX surge una nueva doctrina que ve en la propiedad una función social, que hace primar sobre los derechos del dueño, los que tiene la colectividad sobre los bienes susceptibles de satisfacer sus necesidades.

Tema 1: Definición.

El artículo 582 del CC dispone: **“El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno”**. El precepto transcrito sólo hace alusión al derecho de propiedad sobre una cosa corporal; para llenársete vacío el artículo 583 señala: “Sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”.

Tema 2: Caracteres.

El derecho de dominio presenta las siguientes características: es un **derecho real, es absoluto, es exclusivo, y, es perpetuo**.

Es un **derecho real**, como lo indican los artículos 577 y 582 del CC. De ahí que esté amparado por una acción real, la reivindicatoria conforme al artículo 8890 del CC.



Es un **derecho absoluto** porque comprende el total de facultades que se pueden ejercer sobre una cosa: uso, goce y disposición, otorgando a su titular el máximo de utilidad. Se deriva, en consecuencia, que el dueño del suelo tiene derecho al subsuelo y a la superficie, es decir, a todo aquello que sea útil a su titular.

Es un **derecho exclusivo y excluyente**, porque sólo corresponde el uso y goce de la cosa a la persona que es dueño de ella, no pudiendo nadie oponerse a este uso y goce.

Es un **derecho perpetuo**, porque por lo general, no se extingue por el transcurso del tiempo o por el no ejercicio. Sin embargo, hay ciertas propiedades temporales, que en ningún modo están reñidas con lo dicho, como sucede con la propiedad intelectual, industrial, fiduciaria, etc.

Tema 3: Facultades que otorga el derecho de dominio a su titular.

De la propia definición y de su carácter absoluto, se desprende que el derecho de propiedad comprende tres facultades: **uso, goce y abuso**.

El uso, es la facultad para servirse de la cosa según su naturaleza; así, el propietario de una casa puede habitarla.

El goce, consiste en el derecho de gozar de la cosa, percibiendo todos los frutos que ella es susceptible de producir; así, el propietario de una casa recibe el pago de la renta y el de un fundo su cosecha, goce jurídico y natural, respectivamente.

El abuso, o sea, el derecho de hacer con la cosa lo que a uno le plazca, viene a darle fisonomía propia al derecho de dominio, distinguiéndolo de los demás derechos reales. Otros derechos reales como el usufructo o la habitación, conceden a su titular el derecho de usar y gozar de la cosa, pero sólo en el dominio encontramos la facultad de disposición. La expresión abuso no debe entenderse en el sentido de ser contraria a la ley, sino únicamente debe dársele el alcance de que el dueño puede abusar de la cosa jurídicamente, enajenándola, o materialmente, destruyéndola, consumiéndola o transformándola.

Tema 4: La facultad de disposición es de orden público.

En el CC existe una serie de disposiciones que tienen por objeto impedir que se entorpezca la libre enajenación de la propiedad, por ejemplo, los artículos 745 y 769 que prohíben la constitución de fideicomisos y usufructos sucesivos; el artículo 1126 que prohíbe los legados con la condición de no enajenar la cosa; el artículo 1964 que prohíbe el arriendo con la condición de no enajenar la cosa, etc. Todos estos preceptos nos permiten afirmar que, en nuestro derecho, la libre enajenación es una facultad de la esencia de la propiedad.

Tema 5: Casos excepcionales en que se permite que se limite la facultad de disposición.

Ello sucede: **primero**, en el caso del artículo 751 del CC que permite que el constituyente prohíba al propietario fiduciario que enajene la propiedad fiduciaria; **segundo**, en materia de usufructo, el constituyente puede prohibir al usufructuario que enajene o ceda su derecho conforme al inciso tercero del artículo 793 del CC; y, tercero, puede donarse una cosa con la condición de no enajenar, conforme al primer número del artículo 1432 del CC.

Tema 6: Valor de la cláusula de no enajenar.

El problema reside en saber cuál es el valor de la cláusula de no enajenar en aquellos casos en que el legislador no se ha pronunciado.

Una doctrina estima que la cláusula es válida por las siguientes razones: **primero**, porque en derecho privado puede hacerse todo aquello que no esté expresamente prohibido; **segundo**, porque en ciertos casos excepcionales se prohíbe una cláusula en tal sentido, por tanto, la regla general es que ellas sean válidas; **tercero**, porque si el dueño de una cosa puede desprenderse de uso, goce y disposición, con mayor razón podrá desprenderse sólo de esta última facultad; y, cuarto, porque el tercer número del artículo 53 del Reglamento del CBR faculta para inscribir todas las prohibiciones legales, convencionales y judiciales que entran la libre enajenación de los inmuebles.

Otra doctrina plantea que la cláusula de no enajenar engendra una obligación de no hacer. Por consiguiente, si enajena la cosa, viola una obligación que tenía de abstenerse, de no hacer. Y ello, en conformidad al artículo 1555 del CC se traduciría en una acción de indemnización de perjuicios. Esta doctrina ha sido combatida porque se dice que la obligación de no hacer, se refiere siempre a actos o hechos materiales, pero no a actos o hechos jurídicos. Por lo demás, si esta doctrina le niega valor a la cláusula de no enajenar, no es posible que su violación se traduzca en una indemnización de perjuicios. El artículo 1536 del CC hablando de la cláusula penal, que no es otra cosa que una liquidación anticipada y convencional de los perjuicios que se originan por el no cumplimiento o por el cumplimiento tardío de la obligación, dice que la nulidad de la obligación principal también acarrea la nulidad de la cláusula penal, y la cláusula penal no es sino una forma especial de la indemnización de perjuicios.

Por último, otra doctrina niega valor a la cláusula, señalando que **es nula por ilicitud del objeto** por las siguientes razones: **primero**, el legislador considera la facultad de enajenar como de orden público; **segundo**, de aceptarse la cláusula de no enajenar se produciría una situación curiosa porque el derecho de dominio otorga las facultades de usar, gozar y disponer de la cosa, y si el dueño de la cosa ha renunciado a la facultad de disposición, éste derecho no tendría titular;

tercero, el **tercer** número del artículo 53 del Reglamento del CBR dice que las prohibiciones que contempla sólo se pueden inscribir en aquellos casos en que la ley lo ha permitido ya que dicho reglamento tiene su límite en la ley, aunque fue dictado con posterioridad y podría haberlo modificado tácitamente; y, **cuarto**, el artículo 1810 del CC dispone que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no esté prohibida por la ley y, en consecuencia, se dice que sólo la ley puede prohibir la enajenación de una cosa pero no los particulares.

La Corte Suprema ha dicho que la cláusula de no enajenar no es nula sino que constituye una condición resolutoria. No envuelve un vicio de nulidad de la venta hecha en contravención a ella, sino que constituye una condición resolutoria establecida a favor del vendedor. Sin embargo, hay que tener presente que de acuerdo al inciso final del artículo 1480 del CC toda condición resolutoria inductiva a un hecho ilegal o inmoral se tendrá por no escrita y la cláusula de no enajenar sería ilícita porque entraba la libre enajenación de los bienes, facultad que el legislador estima que es de orden público. Por tanto esta cláusula, por ser ilegal, debe tenerse por no escrita. En otro caso el mismo Tribunal declaró que constituye una limitación del dominio la estipulación en virtud de la cual se acuerda que un crédito no podrá cederse a terceros. Esta ni otras limitaciones como la del fideicomiso, el usufructo, el uso o habitación, desnaturalizan el dominio mismo. Todas ellas se conforman con la disposición legal que define el dominio, no obstante impedir la disposición arbitraria de una cosa determinada. La jurisprudencia francesa reconoce valor a esta cláusula siempre que concurren dos circunstancias: primero, que haya un legítimo interés en prohibir la enajenación; y, segundo, que esta prohibición no sea perpetua o de un plazo indefinido.

Tema 7: Limitaciones al derecho de dominio.

La Constitución Política de la República dispone en el inciso tercero del número veinticuatro del artículo 19 lo siguiente: *“Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”*. Por lo tanto, el único medio por el cual un individuo puede ser privado de su dominio es por ley general o especial que autorice la expropiación, por causa de utilidad pública o de interés nacional.

El propio artículo 582 del CC, al definir el derecho de dominio, establece que él tiene dos limitaciones: el derecho ajeno y la ley.

1. **Limitaciones establecidas por el derecho ajeno.** Hay en el CC disposiciones que, aplicando la teoría del abuso del derecho, contienen una serie de limitaciones al derecho de propiedad, por ejemplo, los artículos 941, 942 y 946 del CC.

2. **Limitaciones establecidas por la ley.** Todas ellas se fundan en el principio que el interés social debe primar sobre el interés particular de los respectivos dueños. Las más importantes son las expropiaciones por causa de utilidad pública, materia propia del derecho administrativo, las restricciones de carácter sanitario, la servidumbre, el usufructo, la propiedad fiduciaria, etc.

Tema 8: Diversas Clases de Propiedad.

8.1 En cuanto a las cosas objeto del derecho.

La propiedad puede clasificarse en:

Propiedad Civil:	Materia de nuestro estudio.
Propiedad Minera:	Toma el nombre especial de pertenencia y será materia propia del derecho de minería.
Propiedad Intelectual:	A ella se refiere el artículo 584 del CC al decir: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se registrará por leyes especiales.
Propiedad Industrial:	También se refiere a ella el artículo 584 del CC.
Propiedad Austral	
Propiedad Indígena.	

8.2 En cuanto a su extensión.

El derecho de propiedad puede clasificarse, primeramente, en propiedad plena y en mera o nuda propiedad.

La plena propiedad es aquella en que el propietario conserva la totalidad de sus atributos, es decir, de usar gozar y disponer de la cosa. En cambio, **la nuda propiedad es aquella en que el propietario está desprovisto del derecho de goce, y será estudiada en el usufructo.**

También, en cuanto a su extensión, el derecho de propiedad puede clasificarse en propiedad absoluta y propiedad fiduciaria.

La **propiedad absoluta es aquella que no tiene limitaciones en cuanto a su duración, que no está sujeta a gravamen o condición**

alguna. La propiedad **fiduciaria es aquella que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición**, conforme al artículo 733 del CC.

8.3 En cuanto al sujeto.

Se divide en propiedad individual y en copropiedad. El dominio, como fluye del artículo 582 del CC, es un derecho exclusivo y excluyente. Hasta ahora, nosotros nos hemos puesto en el caso de que una sola persona tenga en sus manos las facultades de usar, gozar y disponer de la cosa, propiedad que puede llamarse individual, ya que tiene un solo titular. Sin embargo, es posible, y el propio CC lo permite y reglamenta, que varias personas sean titulares del derecho de dominio sobre la misma cosa: es ésta la llamada **copropiedad o comunidad**.

Tema 9: La Copropiedad.

9.1 Generalidades.

Existe copropiedad **cuando varias personas ejercen sobre una misma cosa derechos de una misma naturaleza**. Esta última característica es fundamental; así, en el usufructo dos personas ejercen derechos, pero no hay comunidad entre el nudo propietario y el usufructuario porque los derechos de que ellos son titulares son de diversa naturaleza. La copropiedad está reglamentada, siguiendo la doctrina de Pothier, dentro de los cuasicontratos, artículos 2304 y siguientes del CC.

9.2 Comunidad y copropiedad.

La indivisión de la propiedad puede recaer sobre una universalidad jurídica o sobre una especie o cuerpo cierto. En el primer caso debe hablarse más propiamente de **comunidad**, en el segundo de **copropiedad**.

9.3 Origen de la copropiedad o comunidad.

La propiedad plural, en cuanto a su origen, puede tener diversas fuentes. Puede resultar de un contrato, como sería el caso de dos o más personas que compraran la misma cosa o bien y en que una de ellas la enajenara a la otra una parte de sus derechos sobre la cosa. Puede resultar de un hecho jurídico, como lo sería la muerte de una persona, operando de tal modo la sucesión por causa de muerte y generando una comunidad entre los herederos. También es el caso de la disolución de la sociedad conyugal, ya que por el fallecimiento de uno de los cónyuges, se forma

una comunidad entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto. En el caso de la disolución de las sociedades civiles y comerciales, se forma una comunidad mientras se procede a su liquidación.

9.4 Duración de la indivisión.

La comunidad o copropiedad es generalmente ilimitada; ya hemos visto que al legislador le interesa que la propiedad no tenga trabas en cuanto a su circulación, de ahí que no mira con buenos ojos a la indivisión y procure por todos los medios que ella dure el menor tiempo posible.

Indivisión de tiempo indeterminado encontramos, por ejemplo, en la comunidad que se forma con ocasión de la muerte de una persona, pero en cualquier momento un heredero puede pedir que se proceda a la liquidación; igual sucede en la comunidad que se produce al disolverse la sociedad conyugal.

Indivisión de tiempo determinado encontramos, por ejemplo, cuando dos personas adquieren una cosa en común pueden pactar que la indivisión durará un determinado tiempo, siempre que no sea mayor de cinco años, pues un plazo mayor no es permitido por la ley, preocupada siempre por la libre circulación de la propiedad de conformidad a lo establecido en el artículo 1317 del CC. Es claro que este plazo de cinco años puede ser prorrogado tantas veces como se desee, pero mientras dure el pacto no se podrá pedir la división por ninguno de los contratantes.

Indivisión de duración perpetua o forzada sucede, por ejemplo, en la comunidad que existe sobre las tumbas o mausoleos, en atención al carácter familiar de esta propiedad; en ciertas servidumbres; en los edificios divididos en pisos o departamentos; en los lagos de dominio privado, es decir, aquellos no navegables por buques de más de cien toneladas y que pertenecen en forma indivisa a los propietarios riberaños, etc.

9.5 Naturaleza jurídica de la copropiedad o comunidad.

Se ha esbozado tres doctrinas que tratan de explicar la naturaleza jurídica de los derechos que los comuneros tienen en la cosa común.

➡ **La primera doctrina es la de la cuota ideal en el total de la comunidad.**

Ella dice que los indivisarios no tienen sino una cuota abstracta, ideal en el total de la comunidad, sin que sus derechos se radiquen en ningún bien particular. La divergencia entre los autores se produce cuando se trata de saber que derecho es el que tienen los comuneros sobre las cosas que forman la indivisión. Para algunos sería un derecho sujeto a la condición suspensiva consistente en que una vez partida la comunidad se le adjudicarán esos bienes. Para otros el derecho de cada indivisario sobre los bienes que forman la comunidad sería un

derecho de dominio sujeto a condición resolutoria que, una vez liquidada la comunidad, no se le adjudiquen a él dichas cosas. Por último, otros estiman que los comuneros no tienen sobre las cosas comunes sino una expectativa de que una vez terminada la comunidad se le entreguen algunas de las cosas en pago de la cuota ideal que tenía en la propiedad indivisa.

➡ **La doctrina romana**, más práctica que la anterior, estima que la comunidad otorga a cada indivisario una cuota efectiva en cada una de las cosas que la forman. La doctrina romana, se traduciría en una doble situación: primero, cada comunero tienen un derecho de dominio sobre su cuota, derecho que es absoluto, perpetuo y exclusivo; y, segundo, en cuanto a la cosa común existiría un derecho colectivo, apareciendo aquí, en forma clara, la copropiedad.

➡ **La doctrina alemana** de la propiedad colectiva plantea que los comuneros no tienen sobre la cosa común ningún derecho, ni en todo, ni en parte, ni material ni intelectualmente. Todos los indivisarios son titulares del derecho de dominio sobre las cosas comunes, derecho que no podría dividirse. El criterio alemán de la propiedad colectiva no es sino una aplicación de la idea del patrimonio finalidad, afecta al cumplimiento de determinado fin, opuesto a nuestro concepto de patrimonio, atributo de la personalidad. Puede decirse, en conclusión, que las cosas comunes no tienen dueño, ya que en el patrimonio de cada indivisario no figura su cuota en la comunidad, debido a que ésta es algo completamente independiente de los comuneros. Es por ello que la comunidad es un patrimonio de afectación no ligado a ninguna persona.

Nuestro CC parece seguir la *doctrina romana*, con la dualidad de situaciones ya vistas. Sobre su cuota cada comunero tiene un derecho absoluto, como se desprende de los artículos 892, 1812 y 2417 del CC, que autorizan al comunero, respectivamente, para reivindicar, vender o hipotecar su cuota en forma absolutamente libre, sin necesidad del consentimiento de los demás indivisarios. En lo referente a la cosa común, existe un derecho colectivo, una copropiedad, estando el derecho de cada comunero limitado por el de los demás. Aplicación de este principio lo constituyen los artículos 2304 y siguientes del CC.

9.6 Término de la comunidad.

De conformidad al artículo 2312 del CC la **comunidad termina** por:

1. La reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona.
2. La destrucción de la cosa común.
3. La división del haber común.

El artículo 1317 del CC autoriza a los comuneros a solicitar la partición, en cualquier momento, es decir, nadie está obligado a permanecer en la indivisión. De ahí que la acción de partición sea imprescriptible. Sin embargo, hay casos excepcionales en que no puede hacerse uso de este derecho por las siguientes razones:

- Cuando se ha pactado la indivisión por plazo, que no exceda de cinco años, renovables a voluntad.
- En los casos de indivisión forzada, como el que existe en los lagos de dominio privado, de las tumbas y mausoleos, etc.

Tema 10: De los Modos de Adquirir la Propiedad.

10.1 Concepto.

Los modos de adquirir el dominio son ciertos hechos materiales a los cuales la ley les atribuye la virtud de hacer nacer o traspasar el derecho de dominio. El CC no los define, sino que se limita a enumerarlos en el artículo 588 diciendo que son tales la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. El legislador olvidó enumerar un sexto modo de adquirir el dominio: **la ley**.

La ocupación, definida en el artículo 606 del CC, es aquel modo de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o por el derecho internacional.

La accesión, en conformidad con el artículo 643 del CC, es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella.

La tradición, conforme lo dispuesto en el artículo 670 del CC, es un modo de adquirir el dominio de las cosas que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y, por la otra, la capacidad e intención de adquirirlo.

La prescripción, de acuerdo al artículo 2492 del CC, es un modo de adquirir las cosas ajenas, por haberse poseído durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.

La sucesión por causa de muerte, conforme al artículo 951 del CC, es aquel modo de adquirir por el cual una persona adquiere todos los bienes de un difunto o una cuota de ellos.

La ley es evidentemente un modo de adquirir y, por este medio, el padre adquiere el usufructo sobre los bienes de sus hijos, etc.

10.2 Campo de aplicación de cada uno de los modos de adquirir.

A pesar que el artículo 588 del CC está ubicado en el título correspondiente al derecho de dominio, hay que advertir que los modos de adquirir también sirven para adquirir otros derechos personales.

Por **medio de la ocupación pueden adquirirse las cosas corporales**, pero sólo los muebles, ya que los inmuebles que carecen de dueño, pasan a poder del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 590 del CC.

La **accesión tiene un campo de aplicación un poco más extenso que la ocupación**, pero también bastante limitado, ya que se circunscribe únicamente a las cosas corporales, ya sean muebles o inmuebles.

En la **prescripción se extiende aún más la posibilidad de adquisición**; en efecto, por medio de ella se pueden adquirir no sólo las cosas corporales, bien sean muebles o inmuebles, sino también las cosas incorpóreas, pero restringida a los derechos reales, con excepción de las servidumbres discontinuas y de las continuas inaparentes, conforme al artículo 882 del CC. En otras palabras, la prescripción no permite la adquisición de los derechos personales y de las servidumbres enumeradas.

La **tradición permite adquirir todas las cosas corporales**, muebles e inmuebles, sean derechos reales o personales.

Por último, por medio **de la sucesión por causa de muerte** se pueden adquirir no sólo las cosas corporales e incorpóreas, sino también las universalidades jurídicas, esto es, todo el patrimonio transmisible de una persona. Excepcionalmente es posible adquirir universalidades jurídicas por medio de la tradición y de la prescripción; ello sucede tratándose del derecho de herencia.

10.3 Clasificación de los Modos de Adquirir.

10.3.1 Originarios y derivativos.

Son originarios aquellos que provocan el nacimiento de un derecho sin que haya relación de causa a efecto con el antecesor, esto es, cuando el primer titular es la persona que adquiere la cosa. Son originarios la ocupación, la accesión y la prescripción.

En cambio, el modo de adquirir es **derivativo** cuando el dominio no nace inmediatamente en el titular sino que hay traspaso de dominio, habiendo relación directa de causa a efecto entre el antecesor y el sucesor. Tal sucede en la tradición y en la sucesión por causa de muerte.

Tiene importancia práctica esta clasificación por cuanto si el modo de adquirir es originario, para medir al alcance del derecho que se adquiere, basta con atender al titular y nada más. Por el contrario, para ver el alcance del derecho que se tiene tratándose de un modo de adquirir derivativo, hay que atender al derecho que tenía el otro dueño, porque nadie puede transmitir o transferir más derechos que los que tiene.

10.3.2 A título singular y a título universal.

Son modos de adquirir a **título singular** aquellos que no permiten la adquisición de universalidades jurídicas, sino únicamente de bienes de una persona o una cuota de ellos. La ocupación y la accesión son siempre a título singular. La sucesión por causa de muerte puede ser a título singular, cuando se adquieren legados, y a **título universal**, tratándose de herencias. La tradición y la prescripción, por regla general, son a título singular; excepcionalmente, en el caso del derecho de herencia, pueden ser a título universal.

10.3.3 Por actos entre vivos y por causa de muerte.

Los primeros son aquellos que operan el **traspaso del dominio en vida** de las personas que intervienen, como sucede con la ocupación, accesión, tradición y prescripción. La sucesión por causa de muerte, en cambio, requiere para que opere, la muerte del causante.

10.3.4 A título gratuito y a título oneroso.

En el modo de adquirir a **título gratuito**, el adquirente no hace sacrificio pecuniario alguno. Este carácter lo tiene la ocupación, la accesión, la prescripción, la sucesión por causa de muerte y la tradición en el caso de las donaciones. Es a título oneroso cuando al adquirente la adquisición del dominio le significa un sacrificio pecuniario; en este caso se encuentra, por regla general, la tradición.

10.4 El dominio sólo se puede adquirir por un modo.

Es ésta una verdad indiscutible. En cambio, como lo señala el artículo 701 del CC, se puede poseer una cosa por varios títulos. Si bien se puede poseer una cosa por varios títulos, el dominio se

adquiere por uno sólo y, en consecuencia, *basta un solo modo de adquirir*, no pueden concurrir varios respecto de unos mismos bienes.

10.4.1 Título y modo de adquirir.

Cuando opera la tradición se requiere también que haya un título traslativo de dominio. Podría decirse que el **título es la causa que habilita para adquirir el dominio**, el antecedente que viene a justificar el hecho material que ocasiona el nacimiento o el traspaso de los derechos reales. Es el antecedente jurídico que sirve de causa y justificación para la verificación de una transferencia de dominio.

Además de exigirlo el artículo 703 del CC, es indispensable que a la tradición acompañe un título, porque en nuestro derecho, a la inversa de lo que sucede en Francia, de los contratos sólo nacen derechos personales, son fuentes de las obligaciones y jamás derechos reales. En todo contrato, para que pueda cumplirse la obligación de transferir el dominio, debe haber un modo de adquirir. En la tradición, por tanto, el título no se pide tanto como un antecedente, sino más bien para cumplir la obligación personal que nace del contrato.

Se discute si los demás modos de adquirir requieren también de un título. Alessandri ha extendido la exigencia del título a los demás modos de adquirir. Así, en el caso de la ocupación, de la accesión y de la prescripción, éste título se confundiría con el modo de adquirir, y, tratándose de la sucesión por causa de muerte, el título sería el testamento o la ley, según se suceda por vía testada o intestada. La disposición del artículo 703 del CC podría producir confusiones porque dice que el justo título puede ser constitutivo o traslativo de dominio, y agrega que son constitutivos la ocupación, la accesión y la prescripción; pero este artículo, en realidad, se está refiriendo al justo título que se requiere en el caso de la posesión regular, que no tiene nada que ver con el título antecedente de los modos de adquirir. Aparte de ello, hay una serie de argumentos para concluir que el título sólo se requiere tratándose de la tradición y no de los demás modos de adquirir:

- i. Porque en la sucesión por causa de muerte se puede suceder a una persona parte intestada y parte testada. Si se aceptara la opinión de Alessandri llegaríamos al absurdo que se podría adquirir a dos títulos, tesis que es rechazada generalmente.
- ii. Porque la doctrina que exige título en todo caso es incompleta, pues no se pronuncia respecto a cuál sería el antecedente cuando la ley es el modo de adquirir.
- iii. Porque el artículo 588 del CC sólo habla de modos de adquirir el dominio y para nada de título, deduciéndose por tanto, que basta con la existencia del modo de adquirir. Excepcionalmente el legislador, tratándose de la tradición, menciona y exige un título traslativo de dominio; en los demás modos de adquirir no se habla para nada de títulos.

- iv. Porque, por último, si en la ocupación, en la accesión y en la prescripción, el título se confunde con el modo de adquirir, significa que aquel es inútil y no sirve sino para complicar los conceptos.

Unidad 3: De La Tradición.

Tema 1: Conceptos generales.

La tradición se fundamenta en que una de las partes, **el tradente, tiene la intención de traspasar o transferir el dominio de una cosa determinada a otra, el adquirente, que tiene, a su vez, la intención de adquirirlo.** Según la concepción del derecho romano sobre los contratos, éstos no transfieren el dominio; constituyen solamente el título o antecedente que puede justificar la adquisición del dominio, y dicha adquisición se produce no como efecto directo del contrato, sino que como efecto directo de la tradición, que es el modo de adquirir. La entrega con la connotación jurídica de transferencia de dominio es lo que constituye en líneas esenciales a la tradición como modo de adquirir.

Para la adquisición del dominio el CC sigue la doctrina del derecho romano, que distingue entre el **contrato**, por una parte, **y el modo de adquirir**, por otra. Del contrato nacen solamente derechos personales. El dominio se adquiere por el modo de adquirir, en este caso, la tradición. El contrato es simplemente un antecedente, o título como lo llama la ley, que justifica la adquisición del dominio por la tradición.

Cabe considerar que toda tradición supone una entrega, a la cual está obligado, por lo general, una de las partes que celebra un contrato que impone tal obligación. Pero no todos los contratos que hacen nacer para una de las partes la obligación de entregar una cosa, justifican que la entrega que se realice permita adquirir el dominio. Sólo presentan este carácter los contratos que se llaman translaticios de dominio, en virtud de los cuales una de las partes asume la obligación de hacer la tradición con la significación jurídica de transferir el dominio.

En materia de transferencia de dominio el CC se aparta del derecho francés, que considera que el solo contrato es apto para transferirle dominio, y sigue, como se ha visto, la doctrina del derecho romano que distingue claramente entre el modo de adquirir, por una parte, y el título translaticio, por otra. La importancia de la tradición radica que en todos los contratos translaticios de dominio que imponen a una de las partes la obligación de transferir el dominio, el deudor sólo puede cumplir su obligación efectuando la tradición de la cosa. O sea, cada vez que la obligación de una persona consiste en dar una cosa, con la connotación jurídica que tiene la obligación de dar, el deudor debe hacer una tradición. Tradición y enajenación son sinónimas; enajena una cosa quien hace tradición de la misma. Los contratos translaticios no constituyen enajenación, en ellos una o ambas partes sólo se obligan a enajenar.

Tema 2: Definición de la tradición.

El artículo 670 del CC dispone: **“La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice de dominio se extiende a todos los otros derechos reales”**.

Cuando el CC utiliza la palabra tradición, por lo general lo hace como sinónimo de entrega, y no bajo la perspectiva de un modo de adquirir el dominio, lo que debe tenerse en consideración para evitar equívocos. La tradición que permite la adquisición del dominio y que es la definida por la ley, supone siempre la entrega de una cosa de manos del tradente al adquirente; pero no toda entrega produce el efecto de la tradición como modo de adquirir el dominio. Sólo la entrega que hace la parte que contrajo la obligación de dar en virtud de un título translativo de dominio constituye jurídicamente una tradición, que puede operar la transferencia del dominio si se cumplen los requisitos legales. También debe destacarse que por la tradición se puede adquirir, no sólo el dominio, sino que también los demás derechos reales. Cabe mencionar, finalmente, que también se pueden adquirir por tradición los derechos personales, lo que permite apreciar el amplio alcance de la tradición como modo de adquirir tanto cosas corporales como incorporeales, sin limitación alguna.

Tema 3: Naturaleza jurídica de la tradición.

La tradición es un acto jurídico bilateral o convención, que requiere para que nazca a la vida del derecho la manifestación de voluntad de dos partes: **tradente y adquirente**. La primera efectúa voluntariamente la entrega de la cosa y la segunda, voluntariamente, la recibe. Cabe preguntarse cuál es la intención que persiguen las partes cuando celebran el acto jurídico tradición, entendido como modo de adquirir el dominio.

Lo primero que cabe advertir es que la tradición no crea un derecho. Solamente opera el traspaso del derecho de dominio que ya existía, de manos del antiguo titular a uno nuevo.

Bajo el esquema de la doctrina clásica, la tradición es una convención que persigue modificar un derecho. Tal modificación resulta del hecho que la tradición produce como efecto el cambio de titular del dominio, que antes era otra persona. El concepto de la tradición como una convención que modifica un derecho ha sido objeto de críticas por un sector de la doctrina pues el mero cambio de la persona del titular no implica realmente una modificación del derecho, pues éste sigue siendo el mismo. Por lo anterior algunos, teniendo presente que la tradición no crea el

derecho de dominio, que ya existía, y que tampoco lo modifica como tal, estiman que el propósito perseguido con la convención es uno propio y específico: traspasar dicho derecho.

Según se ha mencionado, para establecer la naturaleza jurídica de la tradición, atendiendo al derecho de dominio que en virtud de ésta se adquiere y desechándose que la tradición es un contrato, cabe concluir que es una convención que modifica un derecho o, si se quiere, que opérale traspaso de un derecho. Bajo este prisma la tradición es una convención por medio de la cual se extingue la obligación de hacer la tradición que se había contraído en virtud de un título; debiendo considerarse, según el esquema general de la doctrina clásica, como una convención que extingue un derecho o que extingue una obligación.

En síntesis, podemos concluir que las partes que celebran la convención llamada tradición, persiguen un doble propósito:

- i. Mirada desde la perspectiva del dominio que se adquiere, las partes tienen la intención de modificar el derecho de dominio radicado en un titular determinado, lo que se logra cambiando la titularidad del dominio de una persona a otra.
- ii. Mirada desde la perspectiva de la obligación que ha contraído una persona de hacer la tradición, las partes tienen intención de extinguir dicha obligación por la prestación de lo que se debe; o lo que es lo mismo, pero desde el ángulo del acreedor, las partes tienen intención de extinguir el derecho personal que había adquirido una persona para exigir que se le haga tradición de una cosa.

Tema 4: Características de la tradición como modo de adquirir el dominio.

Los modos de adquirir el dominio son los hechos jurídicos a los cuales la ley atribuye la significación de hacer nacer el derecho real de dominio o de operar su traspaso. La tradición, como uno de ellos, presenta las siguientes características:

a) La tradición es un modo de adquirir derivativo.	Se aplica a la tradición el principio contenido en el aforismo de que nadie puede transferir más derechos que los que tiene ni nadie puede adquirir más derechos que los que tenía el anterior titular. Si una persona que alega ser dueña de una cosa por tradición se ve en la necesidad de probar el dominio, deberá acreditar en primer lugar los hechos o supuestos de hecho que la ley establece para este modo de adquirir, como es que se le hizo entrega de la cosa en virtud de un título translaticio. Pero ello, si bien suficiente para probar la tradición, no es suficiente para probar que la tradición le transfirió el dominio, ya que para que se produzca este efecto es menester que la persona que le hizo la tradición haya tenido la calidad de dueño de la cosa.
---	---

b) La tradición es un modo de adquirir entre vivos.	Ello no obsta para que pueda convenirse que la tradición que se efectúe de una cosa debe entenderse que no se transfiere el dominio mientras no se produzca la muerte de una persona.
c) La tradición es un modo de adquirir a título gratuito o a título oneroso.	Se habla de tradición a título gratuito cuando el adquirente no queda obligado por el título a desembolsar nada a cambio del bien que adquiere. Se habla, en cambio, de tradición a título oneroso, cuando el adquirente ha quedado obligado por el título a efectuar un desembolso pecuniario a cambio de la cosa que adquiere.
d) La tradición es un modo de adquirir generalmente a título singular y excepcionalmente a título universal.	La tradición del derecho real de herencia, que tiene por objeto el patrimonio de una persona difunta o una cuota del, constituye el caso de excepción en que la tradición es a título universal.

Tema 5: Alcance de las palabras entrega y tradición.

La doctrina diferencia claramente el significado jurídico de los términos entrega y tradición, lo que ya advertían los romanos. En su acepción vulgar o corriente, la palabra **entrega significa poner en manos o en poder de otro una cosa, o sea, designa el acto por el cual una persona traspasa materialmente una cosa a manos de otra.** La diferencia entre la simple o mera entrega y la tradición radica en que jamás la primera permite que quien reciba la cosa adquiera el dominio. Para saber cuando estamos en presencia de un acto que constituye entrega y cuando en frente de una tradición, se debe simplemente atender al título en virtud del cual se recibe la cosa, porque hay títulos como los contratos translativos que establecen la obligación de hacer tradición y permiten presumir la intención del tradente de transferir el dominio; y hay otros, en cambio, que sólo consideran una simple o mera entrega que no permite presumir la intención de transferir el dominio.

El efecto que produce la tradición es muy distinto del que deriva de una simple entrega. **El que recibe una cosa porque se le hizo la tradición adquiere el dominio, siempre que el tradente sea dueño y que la tradición cumpla los demás requisitos para que transfiera el dominio.** Y aunque el tradente no sea dueño, procediendo la tradición de un título translativo, la persona que recibe la cosa adquiere su posesión. En cambio, el que recibe una cosa por la simple o mera entrega y no la y tradición, es obvio que no adquiere el dominio, pero tampoco adquiere la posesión. Es un mero tenedor de la cosa que reconoce dominio ajeno. En doctrina se afirma como aforismo que toda tradición constituye una entrega pero no toda entrega constituye una tradición. Se observa, asimismo en la doctrina, que entre los términos entrega y tradición hay una relación de género a

especie; la entrega es el género y la tradición una especie de entrega que permite a través de ella la transferencia del dominio.

La distinción entre lo que jurídicamente constituye entrega y lo que constituye tradición no aparece reflejada en el CC con la precisión con que la formula la doctrina. Es posible concluir que cuando el legislador utiliza la palabra tradición lo hace con la acepción amplia que ésta tiene, en el sentido de entrega a uno de una cosa, pero en cabal conocimiento de que la tradición, entendida como entrega, puede en ciertos casos transferir el dominio. Es importante, en consecuencia, tener presente que en nuestro CC las palabras **entrega y tradición son sinónimos**, y que cuando el CC habla de tradición lo hace con la acepción de entrega, salvo cuando se refiere específicamente a la tradición que transfiere el dominio. Por consiguiente, y dentro de la terminología del CC, la palabra genérica es tradición, y una especie de ella es la tradición que trasfiere el dominio, lo que no trae ningún problema de interpretación ni consecuencias prácticas.

Tema 6: Requisitos de la Tradición.

Los artículos 670 y siguientes del CC señalan los requisitos que debe reunir la tradición para que transfiera el dominio. Antes de entrar a su análisis nos parece necesario considerar cuáles son los requisitos esenciales o indispensables para que el acto jurídico que el legislador llama, en general, **tradición**, adquiera existencia jurídica, independientemente del hecho que transfiera o no el dominio.

La existencia jurídica del acto llamado tradición supone la concurrencia de dos elementos esenciales: **primero**, la presencia de dos partes, toda vez que la tradición es una convención y éstas requieren la manifestación de voluntad de dos partes; y, **segundo**, el traspaso de una cosa de manos de una persona a otra. Dicho traspaso opera como consecuencia de dos actos. El primero, el de la persona que pone la cosa en manos o en poder de la otra; y, el segundo, el de la persona que recibe la cosa ya sea materialmente en sus manos o de otra manera por la cual ésta quede en su poder. Por lo tanto, es indispensable para la existencia de la tradición que la parte que tiene derecho a exigirla reciba la cosa que la otra pone en su poder. No es suficiente que ésta última manifieste su voluntad de hacer la entrega de la cosa si la persona a quien quiere traspasarla no consiente en recibirla. Ello, a lo más, constituiría una oferta de entrega, pero no una tradición, porque la tradición supone que una de las partes voluntariamente pone la cosa en manos de la otra. Cumplidos estos requisitos, nace a la vida del derecho el acto jurídico llamado tradición. Con su sola concurrencia la parte que recibe la cosa puede adquirir la mera tenencia de la misma, pero no es suficiente para que la tradición transfiera el dominio.

Para que la tradición opere los efectos de modo de adquirir el dominio o para que haga posible la transferencia del dominio, deben cumplirse los requisitos que establece la ley cuando regula la tradición como modo de adquirir el dominio. Tales requisitos son los siguientes:

- a) Existencia de un tradente, por una parte, y de un adquirente, por la otra.
- b) Intención en el tradente de transferir el dominio y en el adquirente de adquirirlo.
- c) Entrega que de la cosa hace el tradente al adquirente, y que supone el consentimiento de ambos.
- d) Facultad en el tradente de transferir el dominio.
- e) Capacidad de las partes.
- f) Existencia de un título translativo de dominio.
- g) Cumplimiento, en ciertos casos, de solemnidades especiales para la enajenación.

a) Existencia de un tradente y de un adquirente.

Lo que la ley requiere es que una de las partes tenga la calidad jurídica de tradente y que la otra tenga la de adquirente. Para que la tradición transfiera el dominio la parte que entrega tiene que tener la calidad jurídica de tradente y, la que recibe, la calidad de adquirente.

El inciso primero del artículo 671 del CC dice que se llama tradente a la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, de lo que se desprende que no es suficiente que una de las partes entregue la cosa para que tenga la calidad jurídica de tradente, sino que es indispensable para ello que por la tradición transfiera el dominio de la cosa que entrega él, personal y directamente, u otra persona a su nombre como representante legal o voluntario.

El mismo inciso primero del artículo 671 del CC dice que se llama adquirente a la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre, de lo que se hace posible desprender, a su vez, que no basta para tener la calidad jurídica de adquirente que se reciba la cosa que otro entrega sino que es necesario que la persona que recibe la cosa personal o directamente o por intermedio de un representante legal o voluntario que la recibe a su nombre, adquiera por la tradición el dominio.

El concepto legal de tradente y de adquirente se estructura sobre la base de que la tradición transfiere el dominio, por una parte, y que se adquiere, por la otra. En estricto rigor, no hay tradente si por la tradición la persona que entrega o a nombre de quien se entrega la cosa no transfiere el dominio, como tampoco hay adquirente si por la tradición la persona que recibe o a nombre de quien se recibe la cosa no adquiere el dominio. El artículo 671 del CC supone, en todo caso, es que aún cuando no se den las calidades jurídicas de tradente y adquirente existe el acto jurídico tradición, pues parte de la base que una parte entrega y la otra recibe, independientemente del hecho que la tradición no transfiere el dominio, precisamente por faltar el tradente o el adquirente.

El artículo 671 del CC revela que tanto el tradente como el adquirente pueden concurrir personalmente a la tradición, o bien representados por una persona con poder de representación. Lo anterior significa que se aplica a la tradición el principio general que permite a las personas celebrar actos jurídicos por intermedio de representantes, produciéndose los efectos de la representación señalados en el artículo 1448 del CC.

El inciso tercero del artículo 671 del CC presenta una particularidad en lo que atañe a la representación, pues establece un caso de representación legal que se da en la tradición: la del tradente en la enajenación que se hace como consecuencia de una venta forzada por decreto judicial a petición de un acreedor, en pública subasta. En tal enajenación el juez tiene la calidad de representante legal de la persona cuyo dominio se transfiere.

b) Intención en el tradente de transferir el dominio y en el adquirente de adquirirlo.

Es necesario que las partes que celebren el acto lo hagan con una intención precisa: **en el tradente, transferir el dominio; en el adquirente, adquirirlo.** Para que pueda configurarse esa intención, será indispensable, en primer lugar, que la tradición tenga como antecedente un título translaticio de dominio, pues sólo en éstos surge la obligación de hacer una tradición que transfiera el dominio. En cambio, jamás podrá presumirse esta intención si la entrega se fundamenta en un título de mera tenencia. Tratándose de la tradición de las cosas corporales muebles, el artículo 684 del CC exige que la intención del tradente de transferir el dominio, no obstante que es posible presumirla del título translaticio, se exteriorice en forma expresa, por alguno de los medios que la disposición establece, de modo tal que no pueda surgir duda en cuanto a que el tradente quería transferir el dominio de la cosa que ha adquirido el adquirente.

Los medios por los cuales debe figurar la transferencia de dominio de las cosas corporales muebles, según la citada disposición, son los siguientes:

i. Permitiendo el tradente al adquirente la aprehensión material de una cosa presente.

Desde el momento que el tradente permite al adquirente la aprehensión material de la cosa presente, está manifestando, en concepto de la ley, su intención de transferir el dominio del bien respecto al cual se permitió la aprehensión material por parte del adquirente.

ii. Mostrándosela.

El acto por el cual el obligado a hacer la tradición muestra la cosa debe ser inequívoco, en el sentido antes indiciado; es decir, no debe caber duda de que quien muestra la cosa, por ejemplo, un movimiento de la mano, lo hace con la intención de transferir el dominio de la cosa que enseña o señala a la otra parte para que la vea.

iii. Entregando el tradente al adquirente las llaves del granero, almacén, cofre o lugar en que esté guardada la cosa.

Entendiéndose con tal hecho que el vendedor tiene la intención de transferir el dominio de la cosa que se encuentra guardada en un lugar determinado.

iv. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido.

Entendiendo la ley que con tal hecho revela la intención de transferir el dominio de dicha cosa.

v. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a cualquier otro título no translaticio de dominio; y recíprocamente, por el mero contrato en que el dueño se constituye en usufructuario, comodatario, arrendatario, etc.

El quinto número del artículo 684 del CC contempla dos casos. El primero de ellos se produce cuando una persona que tiene una cosa por un título de mera tenencia, celebra después un contrato translaticio que tiene por objeto la misma cosa. La ley, junto con fingir en este caso una tradición que, en realidad no se produce, entiende que el solo contrato translaticio revela inequívocamente la intención de transferir el dominio de la cosa. El segundo caso de tradición ficta se produce cuando el dueño de una cosa celebra un contrato translaticio en relación con la misma, manteniendo sin embargo la cosa en su poder, no como dueño, sino que como mero tenedor.

Se ha visto que en la tradición de las cosas corporales muebles, la intención del tradente de transferir el dominio debe figurar por alguno de los medios que la ley establece. En cambio, en lo relativo a la intención del adquirente de adquirir el dominio, el CC no contiene ninguna disposición que señale como debe manifestarse, probablemente en consideración a que la recepción que hace el adquirente de la cosa que le entrega el tradente en cumplimiento de la obligación de hacer la tradición en virtud de un título translaticio de dominio, constituye inequívoca manifestación de la intención de adquirir el dominio de tal cosa.

c) Entrega que de la cosa hace el tradente al adquirente, y que supone el consentimiento de ambos.

Hemos señalado que la entrega es de la esencia de toda tradición y que naturalmente la supone la tradición que transfiere el dominio. Teniendo en consideración las diversas disposiciones del CC que se ocupan de la materia, es necesario formular algunas distinciones para establecer cómo debe hacerse la entrega, en el entendido que se trate de una tradición que permita la adquisición del dominio:

- I. Tradición de cosas corporales muebles o de derechos reales constituidos sobre éstos.
- II. Tradición de frutos o de cosas que forman parte de un predio.
- III. Tradición de inmuebles o de derechos reales constituidos sobre éstos, con excepción de las servidumbres.
- IV. Tradición de las servidumbres.
- V. Tradición del derecho real de herencia.
- VI. Tradición de las minas.
- VII. Tradición de los derechos personales.

I. Tradición de cosas corporales muebles o de derechos reales constituido sobre éstos.

La tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal mueble debe hacerla el tradente entregando la cosa corporal mueble al adquirente por alguno de los medios que señala el artículo 684 del CC. No está demás reiterar que toda entrega supone que una persona traspasa a otra una cosa y que ésta la recibe, ya sea materialmente o de otra manera que le permita incorporar la cosa bajo su poder de dominación. Si el título es translativo de dominio en relación con la cosa que debe entregarse, sólo cabe entenderse cumplida la obligación del deudor si el medio por el cual pone en manos o poder del acreedor la cosa mueble permite a éste la adquisición de la posesión. En cambio, si el título es de mera tenencia, la entrega debe permitir a quien recibe la cosa adquirir la nueva tenencia de la misma. Analizaremos a continuación la enumeración del artículo 684 del CC que dispone: “La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes:”

i. “Permitiendo el tradente al adquirente la aprehensión material de una cosa presente”.

Corresponde a lo que los romanos conocían con el nombre de tradición real, y consiste en que el obligado a la tradición de una cosa que se encuentra delante o en presencia tanto de éste como de quien tiene derecho a exigirla, permite que el segundo la pueda coger o asir materialmente, con el objeto de que la cosa quede en poder de este último. La tradición debe entenderse verificada cuando el adquirente aprehende la cosa, es decir, realiza el acto de cogerla o asirla materialmente, con la intención de hacerla suya. La entrega por la aprehensión material, aplicable a las cosas muebles que pueden tomarse fácilmente con las manos, es, sin duda, la más corriente en la práctica. Normalmente, cuando se compra una cosa que por su tamaño y peso permite tomarla con las manos, el vendedor va a pasar la cosa al comprador o le va a permitir que la tome éste directamente.

Si la tradición se verifica por el solo hecho de que el tradente haya permitido la aprehensión de la cosa, la negativa del adquirente a tomarla o recibirla en sus manos sería irrelevante. En cambio, si la tradición no se realiza sino cuando el adquirente recibe la cosa porque la ha aprehendido materialmente, la negativa de éste impide estimar consumada la entrega. Esta última tesis es la que nos parece jurídicamente correcta, por dos razones: primero, porque parte de la base que no puede existir el acto jurídico entrega sin la aceptación o recepción de la cosa por el adquirente; y, segundo, porque la tradición es un pago efectivo o solución, esto es, la prestación de lo que debe el deudor, y si el acreedor se niega a recibirla se deberá recurrir a una forma especial de pago que se llama pago por consignación, previsto en los artículos 1598 y siguientes del CC.

ii. **“Mostrándosela”.**

Los romanos la conocían con el nombre de tradición de larga mano, que consiste en que el obligado a hacer la tradición pone la cosa a la vista de la otra parte, con la intención de que quede a disposición de ésta, lo que el adquirente acepta. En esta forma de entrega hay una suerte de aprehensión simbólica, resultante del hecho de que a quien se muestra la cosa la mira como suya, como si realmente la hubiera tomado o cogido materialmente. En nuestra opinión, y de acuerdo con el concepto que postulamos de entrega, se nos hace difícil estimar cumplida la obligación de hacer la tradición de una cosa mueble por el sólo hecho de que el deudor la ponga a la vista del acreedor, inclusive asumiendo la aceptación del adquirente. La intención del tradente de transferirle dominio de la cosa se manifestó antes de que la entrega se verificara materialmente: en el momento que el tradente mostró al adquirente la cosa con que cumpliría la obligación de hacer la tradición. La interpretación que criticamos se aparta de los principios que sigue el CC para que se adquiriera la posesión de los bienes muebles. Está en contradicción con el concepto de posesión que supone, como uno de sus elementos esenciales, la tenencia de la cosa.

Nos encontramos en presencia de una tradición ficta, es decir, de una tradición que finge la ley como consecuencia de la celebración de un contrato translativo, en virtud de la cual si bien el adquirente no tiene materialmente la cosa en su poder, porque el tradente sólo se la ha mostrado, adquiere de igual forma la posesión, porque se entiende que el tradente tiene la cosa a nombre y en lugar del adquirente y que es un mero tenedor de la misma. Esta interpretación, si bien jurídicamente posible, presenta el inconveniente de que el CC se refiere expresamente a las tradiciones fictas en el tercer número del artículo 684.

- iii. **“Entregando el tradente al adquirente las llaves del granero, almacén, cofre o lugar en que esté guardada la cosa”.**

En el derecho romano se le denominaba tradición simbólica, y consiste en la entrega material de las llaves del lugar en que está guardada la cosa que hace el tradente al adquirente, quien las recibe. Hay un traspaso material de las llaves de manos del uno al otro. Estimamos que la entrega y recepción de las llaves opera la transferencia del dominio, aunque no se haya entregado materialmente la cosa que está guardada en el almacén, cofre o granero. Ello, porque las llaves figuran, representan o simbolizan la cosa; y porque con la recepción de las llaves se incorpora la cosa que éstas simbolizan al poder de dominación del adquirente, sin necesidad de tomar materialmente su posesión.

- iv. **“Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido”.**

Era otra figura que el derecho romano consideraba como tradición simbólica, y consiste en que el tradente se encarga de poner la cosa a disposición del adquirente en el lugar convenido. Se discute si podría estimarse que se verificó la entrega y operó la transferencia del dominio por el solo hecho de que el vendedor asuma la obligación. La respuesta afirmativa equivale a suponer que la tradición se realiza por el sólo contrato en que las partes estipulan la obligación, y más aún, aunque la cosa no llegue, en definitiva, a quedar en disposición del comprador, lo que ocurrirá si el vendedor no cumple el encargo. El proyecto de 1853 requería que el encargo fuese cumplido, o sea, que se pusiera realmente la cosa a disposición del adquirente, requisito que fue posteriormente eliminado, lo que revela que el legislador lo consideró innecesario.

Concordamos con la opinión de Claro Solar y estimamos que se verifica la entrega y opera la tradición una vez que se cumple cabalmente la obligación convenida, porque sólo en ese momento puede estimarse que el adquirente recibe la cosa y queda a su disposición. Creemos que la eliminación de tal requisito se debe a que el legislador lo consideró innecesario por encontrarse implícito, en la disposición, el cumplimiento del encargo. No hay que olvidar que el artículo 684 del CC no está referido directamente a la forma o maneras de hacer la entrega, sino que a los medios por los cuales debe figurar la intención del tradente de transferir el dominio, la que en este caso, se manifiesta por el compromiso que asume el obligado a poner la cosa a disposición de la otra parte.

- v. **“Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a cualquier**

otro título no translaticio de dominio; y recíprocamente, por el mero contrato en que el dueño se constituye en usufructuario, comodatario, arrendatario, etc.”.

Estas son las llamadas tradiciones fictas y que corresponden a lo que en derecho romano se conocía con el nombre de tradición brevi manus y constitutum possessorium.

La tradición brevi manu consiste en suponer que el que tenía la cosa como mero tenedor, sin ánimo de dueño, por el hecho de adquirir respecto de ella un título translaticio de dominio, ha recibido la cosa misma, como si se le hubiese entregado corporalmente, permitiéndosele que la tome por sí mismo, brevi manu, y suprimiéndose así, por lo tanto, el acto de restitución de la tenencia de la cosa al propietario para que éste inmediatamente hiciera entrega material de ella al adquirente que antes la había tenido en su poder en virtud de un título no translaticio de dominio. En el quinto número del artículo 684 del CC la ley finge una tradición porque el adquirente de la cosa en virtud de la tradición ficta tiene de hecho la cosa bajo su señorío o poder de disposición. Lo que ocurre es que la relación que se tenía sobre la cosa va a cambiar: primero se tenía una relación de mera tenencia, que emana del título de mera tenencia; y después se tiene una relación de dominio o de posesión, que se adquiere como consecuencia de la tradición que finge la ley.

El constitutum possessorium consiste en que el dueño de una cosa mueble celebra en relación con la misma un contrato translaticio de dominio, estipulándose en el mismo contrato que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc., o lo que es lo mismo, que el dueño conserva la cosa en su poder, pero no a título de tal sino de mero tenedor. La ley finge una tradición que en el hecho no se efectúa, entre el vendedor y el comprador, que habilita a éste para adquirir el dominio y la posesión de la cosa. Si bien el adquirente de esta posesión ficta no tiene materialmente la cosa, se da a su respecto el corpus como requisito de la posesión, porque el poseedor puede tener la cosa por sí mismo o por otra persona que la tiene en lugar y a nombre de aquel, y el tradente que conserva la cosa como mero tenedor la tiene a nombre y en lugar del adquirente.

Para terminar con el estudio de las maneras de hacer la entrega en la tradición que tiene por objeto una cosa corporal mueble, es conveniente reiterar el principio general que hemos comentado en relación con cada uno de los números del artículo 684 del CC. La entrega de las cosas muebles puede efectuarse por cualquier medio que permita al adquirente entrar en posesión de la cosa, considerando que ésta supone como elemento esencial la tenencia de la misma. Si en virtud de la entrega que hace una parte a la otra esta última incorpora la cosa bajo su poder, en términos tales que la puede detentar con ánimo de señor y dueño, debe estimarse que

la entrega ha permitido la adquisición de la posesión y que se ha verificado la tradición a que el tradente se encontraba obligado.

Otro principio que no hay que olvidar es que el solo contrato translativo no permite entrar en posesión de la cosa porque falta la tradición, que sirve como título posesorio. Sin embargo, en el mutuo, que es un contrato real, y que también tiene la calidad de título translativo de dominio, la tradición de la cosa, indispensable para que el contrato se perfeccione, sirve, al mismo tiempo, para que el mutuario entre en posesión de la misma.

II. Tradición de piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 685 del CC la tradición de las cosas que forman parte de un predio, refiriéndose a las cosas muebles por anticipación, se efectúa en el momento de la separación de estos objetos, lo que podría llevar a suponer que la entrega se entiende verificada por el solo hecho de la separación de las cosas, aun cuando el adquirente no las haya recibido. Sin embargo el inciso segundo del citado artículo revela que tal interpretación es equivocada al decir que aquel a quien se debieran los frutos de una sementera, viña o plantío, podrá entrar a cogerlos, fijándose el día y la hora de común acuerdo con el dueño. Este inciso permite complementar el anterior, en el sentido que la entrega de las cosas muebles por anticipación sólo puede efectuarse en el momento de la separación, oportunidad en que el tradente puede efectuar la entrega y el adquirente recibirlas.

III. Tradición de los inmuebles y de los derechos reales constituidos en éstos.

La tradición del dominio y de los otros derechos reales sobrevienen raíces, con la sola excepción del derecho real de servidumbre, debe hacerse por la inscripción del título en el Registro del CBR, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 686 del CC.

En consecuencia, la ley requiere inscripción para la tradición de los siguientes derechos reales:

- i. Dominio, cuando recae sobre bienes raíces.
- ii. Usufructo y uso, cuando recaen sobre bienes raíces.
- iii. Habitación.
- iv. Censo.
- v. Hipoteca.

Algunos estiman errada la referencia que el artículo 686 del CC hace a los derechos reales de uso y habitación, toda vez que dichos derechos son intransferibles e intransmisibles, por lo que tienen la característica de ser personalísimos, esto es, nacen y se extinguen en un solo titular, de manera que mal podría suponerse, en consecuencia, la tradición de uno de estos derechos reales, más

todavía si la ley establece que su enajenación adolece de objeto ilícito en el segundo número del artículo 1464 del CC. No compartimos dicha opinión pues el artículo 686 del CC se aplica para la constitución de un derecho de uso y habitación, que tiene como antecedente un contrato gratuito u oneroso. Para que se adquiriera el respectivo derecho es indispensable la tradición, la que se efectúa por la inscripción.

Efectuada la inscripción en los casos que la ley la requiere, la ley finge que se ha efectuado la entrega, con la connotación que tantas veces hemos anotado, esto es, que una parte entrega y la otra recibe. Tanto es así que con la inscripción el adquirente entra en posesión del inmueble respecto del cual se hizo la tradición, aunque estenio se le haya entregado materialmente.

Sin embargo la inscripción, que es una entrega jurídica o ficta si se quiere, que, como veíamos, permite entrar en posesión del derecho real de que se trata, no constituye el medio por el cual el adquirente puede asumir la posesión material o, en su caso, tenencia del inmueble sobre el cual se ejerce el derecho real. Sin embargo, las facultades que reconoce la ley para el titular del dominio o para el poseedor del derecho de dominio, uso, goce y disposición de la cosa, requieren para su ejercicio la posesión material del inmueble. De este modo, podemos decir que el vendedor del inmueble tiene dos obligaciones conceptualmente diferentes: primero, hacer la tradición del derecho real de dominio, obligación que se cumple con la inscripción; y, segundo, hacer la entrega material del inmueble que permita su posesión material, la que se cumple con el traspaso material del mismo, de manos del vendedor al comprador.

En doctrina, la obligación de hacer la tradición se llama obligación de dar; y la de hacerle mero traspaso material de la cosa, obligación de entregar. El artículo 1548 del CC reconoce ambas obligaciones cuando señala que la obligación de dar contiene la de entregar, lo que debe entenderse en el sentido de que el obligado a hacer la tradición, cuando ésta, como ocurre con la inscripción de inmuebles, no opera el traspaso material de la cosa, está obligado a efectuar dicho traspaso, si el derecho real que se transfiere o que se constituya supone para su ejercicio la posesión material de la cosa o su mera tenencia. Sin embargo, hay casos en que el derecho real que se adquiere por la tradición no supone para su ejercicio que el adquirente tenga la posesión o la mera tenencia de una cosa, por ejemplo, la hipoteca.

IV. Tradición del derecho real de servidumbre.

La tradición del derecho de servidumbre se rige por el artículo 698 del CC que exige para que se verifique escritura pública en que el tradente exprese constituir servidumbre y el adquirente aceptarla, agregando la disposición que la escritura podrá ser la misma del acto o contrato. En consecuencia, la tradición de un derecho de servidumbre no requiere inscripción, aunque excepcionalmente la Ley sobre Constitución y Adquisición de la Servidumbre de Alcantarillado en predios urbanos la exija.

V. Tradición del derecho real de herencia.

Supone que el causante haya muerto sino se daría el caso de objeto ilícito del artículo 1463 del CC. El CC no contiene ninguna disposición que señale como debe efectuarse. De partida, el artículo 686 del CC no incluye al derecho real de herencia entre aquellos para cuya tradición es necesaria la inscripción, ni aun cuando la herencia comprenda bienes raíces. Este vacío legal determina la necesidad de establecer el medio idóneo para hacer la tradición del derecho real de herencia, surgiendo dos interpretaciones.

La primera, del profesor José Ramón Gutiérrez, distingue si entre los bienes hereditarios existen o no inmuebles. Si hay uno o más inmuebles, la tradición del derecho real de herencia requiere inscripción, pues ésta es la regla general tratándose de la tradición de derechos reales que se ejercen sobre inmuebles.

La segunda interpretación, postulada por el profesor Leopoldo Urrutia, considera que el derecho real de herencia se ejerce sobre una universalidad distinta de los bienes que la componen, por lo cual sería un derecho real sui generis, al cual es inaplicable la clasificación de mueble o inmueble, según sea la cosa sobre la que se ejercerse.

La jurisprudencia se ha inclinado por la última interpretación y considera que la tradición del derecho real de herencia no requiere de inscripción. Se ha resultado que no siendo la herencia un derecho mueble ni inmuebles, corresponde aplicar a su tradición el estatuto jurídico general, que es el que regula la tradición de los muebles. En consecuencia, la tradición del derecho real de herencia deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere dicho derecho y aceptando ésta última su adquisición. En la práctica, la tradición del derecho real de herencia suele hacerse por escritura pública, en la que el tradente expresa ceder el derecho real de herencia y el adquirente acepta la cesión.

VI. Tradición de las minas.

El inciso final del artículo 686 señala que se estará a lo dispuesto en el Código de Minería.

VII. Tradición de los derechos personales.

La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título, hecha por el cedente al cesionario, conforme lo dispuesto en el artículo 699 del CC. Cabe mencionar que la entrega del título, por una parte, y su recepción por la otra, perfecciona la tradición de los derechos personales entre las partes. Sin embargo, para que la cesión de un crédito produzca efectos contra el deudor o terceros, debe ser notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste, conforme lo dispuesto en el artículo 1902 del CC.

d) Facultad en el tradente de transferir el dominio.

Este requisito se encuentra expresamente contemplado en la definición de la tradición del artículo 670 del CC y significa que para que la tradición transfiera el dominio el tradente debe ser dueño de la cosa o del derecho real de que se trata. Tratándose de otro derecho real que no séale dominio, como es el usufructo, sólo la tradición que haga el dueño de una cosa con el objeto de constituir un usufructo permite la adquisición de ese derecho real por el usufructuario y sólo la tradición que haga el usufructuario dueño del derecho de usufructo permite la transferencia del derecho de usufructo. Lo mismo puede decirse en relación con los demás derechos reales. Como consecuencia de ser la tradición un modo de adquirirse dominio derivativo, sólo transfiere el dominio si el tradente es dueño.

La ley señala los efectos de la tradición cuando el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él a su nombre:

- i. No se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada, conforme al artículo 687 del CC. La misma disposición agrega que si el tradente adquiere después el dominio se entenderá haberse éste transferido desde el momento de la tradición.
- ii. No obstante carecer el tradente de la facultad de enajenar por no ser dueño, la tradición hecha al adquirente opera un importante efecto: permite a éste adquirir la posesión de la cosa o derecho real de que se trata y consecuentemente, de acuerdo al artículo 683 del CC, el derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido ese derecho.
- iii. Por otra parte, si el tradente tenía algún derecho respecto de la cosa, como sería el exigir el pago de las rentas de arrendamiento a la persona a la cual la tenía entregada en arrendamiento, transfiere dicho derecho al adquirente.

e) Capacidad de las partes.

El artículo 670 del CC requiere en el tradente facultad e intención de transferir el dominio y en el adquirente capacidad e intención de adquirirlo. Esto ha llevado a algunos a interpretar que el adquirente debe ser capaz de goce, esto es, de adquirir el derecho de dominio, y que el tradente debe ser capaz de ejercicio, pues sólo así tendría la facultad para transferir el dominio. Todas las personas son capaces para adquirir el dominio por tradición. Una cosa distinta es que ciertos títulos translativos no permiten servir de antecedente a la tradición que pudiera hacerse en virtud de ellos, como por ejemplo, el título de compraventa entre el marido y la mujer.

En nuestro concepto, cuando la ley dice que en el tradente debe haber facultad de transferir el dominio, se refiere a que éste debe ser dueño; y cuando dice que en el adquirente debe haber capacidad de adquirir el dominio, no se refiere a la capacidad de goce, pues, como veíamos, todas las personas son capaces de adquirir el dominio por tradición. El requisito de capacidad en el

adquirente lo creemos referido a la capacidad de ejercicio, en el sentido de que el adquirente debe tener la aptitud jurídica para comparecer por sí mismo en el acto jurídico tradición sin el ministerio o autorización de otras personas, o bien, si es incapaz de ejercicio, por intermedio de su representante legal o autorizado por éste.

Si bien la ley no exige expresamente la capacidad en el tradente, no cabe duda de que se aplica a la tradición el requisito general en virtud del cual las partes que celebran un acto jurídico deben ser capaces. Si el tradente es incapaz absoluto necesariamente debe concurrir al acto jurídico tradición representado por su representante legal; y si es incapaz relativo representado por su representante legal o autorizado por éste. En consideración a que la tradición es una enajenación, el tradente debe ser capaz, asimismo, de enajenar la cosa o derecho objeto de la tradición. Y bajo esta perspectiva podría asumirse que el tradente no tiene capacidad de enajenar las cosas cuya enajenación la ley prohíbe, aunque sea capaz de ejercicio, por ejemplo, el tradente no es capaz de enajenar la cosa embargada sin consentimiento del acreedor o sin la autorización del juez.

f) Existencia de un título translativo de dominio.

En nuestro sistema jurídico para que se adquiera el dominio o cualquier otro derecho real es menester, por una parte, un modo de adquirir; y, por la otra, un título, es decir, un antecedente que justifique la adquisición del dominio por el modo respectivo. A diferencia de lo que ocurre en los modos de adquirir el dominio originario, en los cuales el título y el modo se confunden, en los modos de adquirir derivativos se aprecia claramente la diferencia entre el título y el modo, y el distinto rol jurídico que desempeñan ambos por ser actos jurídicos diferentes.

El título que sirve de antecedente a la tradición se llama título translativo de dominio. El artículo 703 del CC dispone que son títulos translativos de dominio: *“Los que por su naturaleza sirven para transferirlos, como la venta, la permuta, la donación entre vivos, etc.”*. A los títulos translativos que menciona el CC a vía ejemplar pueden agregarse otros que tienen este carácter, como el aporte en dominio a una sociedad, el cuasiusufructo, la transacción cuando recae sobre un objeto no disputado, etc. El título que impone la obligación de hacer la tradición o, lo que es lo mismo, el hecho jurídico que constituye la fuente de tal obligación, puede no ser un contrato, sino otro, como por ejemplo, el delito civil, que obliga a hacer la tradición de una cantidad de dinero para reparar o indemnizar los perjuicios.

El artículo 675 del CC establece que: *“Para que valga la tradición se requiere un título translativo de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Así, el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges”*. Cuando el título translativo es un contrato, para que la tradición transfiera el dominio se requiere que el contrato sea válido; porque si éste es declarado nulo, la tradición que se hubiera efectuado teniendo a tal contrato como antecedente carecería de título para transferir el dominio. Aunque el contrato adolezca de tales vicios, como produce todos los

efectos que le son propios mientras la nulidad no sea declarada, sirve como título suficiente para la tradición y el adquirente adquiere el dominio si la nulidad no se declara judicialmente. Si bien la ley considera que la tradición que emana de un contrato declarado judicialmente nulo no transfiere el dominio, porque supone que el contrato nunca existió, permite que se adquiera la posesión irregular de la cosa.

Cabe tener presente, por otra parte, que la ley exige que el título sea válido respecto de la persona a quién se confiere, lo que significa que el contrato debe servir como un medio idóneo o eficaz para que la tradición que se haga en virtud de él permita al adquirente adquirir el dominio. Esta falta de aptitud no deriva directamente del título, sino de la particular circunstancia de las personas que lo celebran.

g) Cumplimiento, en ciertos casos, de solemnidades especiales para la enajenación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 679 del CC: “Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas”. La ley exige, en algunos casos determinados, solemnidades especiales para la enajenación. Así, generalmente en atención a la particular calidad o estado de la persona del tradente y con el objeto de protegerlo, la ley puede requerir solemnidades para la enajenación de los bienes de propiedad de éste, por ejemplo, al artículo 255 del CC que dice que tratándose de la enajenación de los bienes raíces del hijo de familia y pupilo se requiere autorización previa del juez con conocimiento de causa.

Las enajenaciones, o lo que es lo mismo, las tradiciones que se efectuaren sin cumplir las solemnidades especiales que requiere la ley, podrán ser declaradas nulas, con lo que se entiende que nunca operaron el efecto de transferir el dominio. Nótese que la nulidad en este caso afecta directamente al acto jurídico tradición, porque el vicio se advierte en éste y no como ocurre en otros casos en que el vicio de nulidad existe en el contrato translativo, con lo cual la ineficacia de la tradición para transferir el dominio se produce como consecuencia de la declaración de nulidad del título.

Tema 7: Modos de Adquirir el Dominio en los cuales la ley requiere Inscripción.

Hemos visto que tratándose de la tradición del dominio y de todos los derechos reales sobre inmuebles, con la sola excepción de las servidumbres, la ley exige inscripción del título en el Registro del CBR, de conformidad con lo establecido en los artículos 686 y 687 del CC.

Cabe tener presente, además, que la ley exige inscripción para un acto jurídico que no es un modo de adquirir: **la partición cuando en ella se adjudican inmuebles**. El artículo 687 del CC requiere inscripción para el acto de partición cuando se adjudican inmuebles que antes se poseían proindiviso al disponer: *“Si por un acto de partición se adjudican a varias personas los inmuebles, o*

parte de los inmuebles que antes se poseían proindiviso, el acto de partición en lo relativo a cada inmueble o cada parte adjudicada se inscribirá en el departamento o departamentos a que por su situación corresponda dicho inmueble o parte”. La inscripción del acto de partición no configura jurídicamente una tradición o enajenación, pues en virtud del efecto declarativo de la partición, se supone que el adjudicatario del inmueble fue siempre dueño exclusivo del bien que antes poseía proindiviso con otros. El acto de partición y la adjudicación que del pueda resultar constituyen lo que la doctrina llama títulos declarativos de dominio, esto es, los que se limitan a reconocer derechos preexistentes. En todo caso, conviene tener presente que la inscripción prevenida en el inciso final del artículo 678 del CC, aunque no constituye tradición del derecho real de dominio, se requiere para mantener la historia de la propiedad raíz.

Hay que tener finalmente presente que el legislador también requiere inscripción tratándose de otros modos de adquirir, distintos de la tradición. Ellos son la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva, que analizaremos en los números siguientes.

De lo dicho se infiere, entonces, que en tres modos de adquirir el dominio de bienes raíces o que se refieran a bienes raíces la ley requiere inscripción:

- Tradición.
- Sucesión por causa de muerte.
- Prescripción adquisitiva.

La ley requiere, asimismo, inscripción para el acto de partición cuando se adjudican inmuebles.

Tema 8: Inscripción en el modo de adquirir sucesión por causa de muerte.

El artículo 688 del CC requiere las siguientes inscripciones cuando hay inmuebles dentro de los bienes que componen la herencia:

- Inscripción del decreto judicial que da la posesión efectiva, y si la sucesión es testamentaria, del testamento.** La posesión efectiva es una resolución judicial que reconoce la calidad de herederos a quienes lo comprueben ante el juez.
- Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo 687 del CC. Esto es, la inscripción el inmueble o de los inmuebles hereditarios a nombre de todos los herederos.** La referencia que hace el CC es, en verdad, a una inscripción llamada comúnmente primera inscripción especial de herencia, en virtud de la cual el inmueble inscrito a nombre del causante queda inscrito a nombre de todos los herederos.

- iii. **La inscripción especial prevenida en el inciso tercero del acto de partición en que se adjudican inmuebles o parte de los inmuebles que antes se poseían proindiviso.** Esta es la llamada segunda inscripción especial de herencia, que debe hacerse sólo cuando habiendo varios herederos, uno o más de ellos, en virtud de un acto de partición, se adjudican un inmueble hereditario.

8.1 Finalidad para la cual se requieren las inscripciones señaladas en el artículo 688 del CC.

Las inscripciones del artículo 688 del CC no se requieren para que los herederos adquieran el dominio de los inmuebles hereditarios. El dominio lo adquieren por el modo sucesión por causa de muerte, sin que se necesite, para que éste opere sus efectos, inscripción alguna, aunque entre los bienes de la herencia existan inmuebles. Tampoco se requieren las inscripciones del artículo 688 del CC para que los herederos adquieran la posesión de los inmuebles hereditarios. Dicha posesión, como lo dice el mismo artículo, se confiere por el sólo ministerio de la ley, situación corroborada por el artículo 722 del CC.



La respuesta la da el mismo artículo 688 del CC al disponer que las inscripciones se exijan para que los herederos puedan disponer de los inmuebles hereditarios. En primer lugar debe inscribirse el decreto de posesión efectiva y el testamento, si lo hubiere. Luego, los herederos deberán practicar la llamada primera inscripción especial de herencia respecto de cada uno de los inmuebles. Efectuada esta inscripción, los herederos podrán disponer de consuno de los inmuebles hereditarios. Este acuerdo de los herederos que los habilita para disponer de consuno queda normalmente reflejado en el contrato translativo que antecede la enajenación misma. Finalmente, si como consecuencia de un acto de partición uno de los herederos se adjudica el inmueble, para que pueda disponer de él y enajenarlo como propietario único y exclusivo del mismo, deberá practicarse al segundo inscripción especial de herencia.

Tema 9: Inscripción tratándose del modo de adquirir prescripción adquisitiva.

El artículo 689 del CC señala: *“Siempre que por una sentencia ejecutoriada se reconociere, como adquirido por prescripción, el dominio o cualquiera otro de los derechos mencionados en los artículo 686 y siguientes del CC, servirá de título ésta sentencia y se inscribirá en el respectivo registro o registros”*. Por su parte, el artículo 2513 del CC dispone: *“La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos; pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción”*.

De los artículos transcritos, queda claro que la inscripción se requiere, no como un requisito para adquirirle respectivo derecho real ni menos para adquirir su posesión, sino que exclusivamente con el objeto de hacer oponible la sentencia en contra de terceros. Los artículos citados dejan de

manifiesto, que los títulos, tomada la palabra en su acepción de documento que deja constancia de un derecho, que se lleven al CBR para su inscripción, sólo pueden consistir en una copia de escritura pública o en una resolución judicial.

Tema 10: Consecuencias que derivan de la falta de inscripción, tratándose de un modo de adquirir que la requiere.

Como se ha visto, el CC requiere inscripción tratándose de tres modos de adquirirle dominio sobre inmuebles: la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva.

a) Con respecto a la tradición.

La omisión de la inscripción requerida para la tradición del dominio o de otro derecho real mencionado en el artículo 686 del CC, viene a ser lo mismo que si la tradición nunca se hubiere hecho. En efecto, si la ley exige inscripción para la tradición del derecho real de que se trata, en términos tales que las palabras tradición e inscripción son sinónimos, la natural consecuencia es que sin inscripción no hay tradición. En el evento que no obstante falta de inscripción el vendedor haga hecho entrega material del inmueble, que permite posesión material del mismo, cabe preguntarse si el comprador adquiere la posesión legal del inmueble. Creemos que el comprador no adquiere legalmente la posesión del inmueble aunque se le haya hecho la entrega material del mismo y aunque lo tenga materialmente en su poder con ánimo de señor y dueño, porque para adquirir la posesión debe haberse verificado la tradición, por lo que la entrega material que se le hizo no le permitirá adquirir legalmente la posesión. La entrega material del inmuebles sin que se haya hecho la inscripción permite, a lo más, la llamada corrientemente inscripción material, que resulta del solo hecho que el comprador tiene la cosa en su poder, pero no la posesión jurídica, con una importante consecuencia: el comprador no podrá adquirir el dominio por prescripción adquisitiva.

Sin perjuicio de que este tema será desarrollado en extenso más adelante, podemos anticipar que el criterio que sustentamos no es unánime, porque hay doctrina y jurisprudencia que se inclina por la tesis contraria, en el sentido de que el comprador a quien se le ha hecho la entrega material, aunque no se haya practicado la inscripción, adquiere jurídicamente la calidad de poseedor. Por el momento nos limitaremos a citar dos artículos que respaldan nuestra posición: El artículo 696 del CC dispone: “Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la manera que en dichos artículos se ordena”. Por su parte, en plena concordancia con el anterior, el artículo 724 del CC dispone: “Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el Registro del CBR nadie podrá adquirir la posesión de ella si no es por este medio”.

b) Con respecto a la sucesión por causa de muerte.

La falta de las inscripciones requeridas por el artículo 688 del CC en el modo de adquirir sucesión por causa de muerte, no impide, como se ha dicho, que los herederos adquieran el derecho real de herencia sobre la universalidad o el dominio sobre todos y cada uno de los bienes que componen la herencia. Tampoco impide que los herederos adquieran la posesión legal de la herencia. Pero dicha posesión no habilita a los herederos para disponer de los inmuebles hereditarios. La enajenación del inmueble hecha por los herederos, que supone que se practicó una inscripción a nombre del tercero a quienes los herederos hicieron la tradición, no permite a éste adquirir el dominio ni la posesión real o verdadera del inmueble, y por lo tanto, no podrá adquirir por prescripción alguna mientras no se efectúe las inscripciones que prescribe el artículo 688 del CC.

c) Con respecto a la prescripción.

La falta de inscripción de la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de un derecho real inmueble, no presenta problemas de interpretación: impedirá, simplemente, que el beneficiado con dicha inscripción la pueda hacer oponible a terceros, mientras no se efectúe la inscripción.

Tema 11: Causales de Invalidez de la Tradición.

Los artículos 672 a 677 del CC contemplan diversos requisitos para la validez de la tradición, lo que hace suponer que su omisión acarrea la invalidez o nulidad de la tradición.

Dice el artículo 672 del CC: *“Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño”.*

De una primera lectura del artículo transcrito se podría inferir que la voluntad del tradente es un requisito de validez de la tradición, lo que pugna con la doctrina clásica en lo relativo a los requisitos de los actos jurídicos, pues ésta considera a la voluntad como el primer requisito de existencia de todos los actos y convenciones. Si concebimos el acto jurídico tradición como una entrega que hace una persona a otra, requisito esencial para que dicha entrega exista jurídicamente, es que una de las partes consienta en traspasar la cosa. Si no existe la voluntad de entregar sino que una totalmente distinta que resulta, por ejemplo, del hecho que el traspaso de la cosa se produce, no como consecuencia de un acto voluntario, sino con ocasión de que una persona la arrebató a otra, no existe bajo ningún concepto una entrega y, por lo mismo, no hay tradición.

El artículo 672 del CC, en consecuencia, mal podría interpretarse en el sentido de que es nula la tradición si falta en una de las partes la voluntad de entregar. Si falta la voluntad de una cualquiera

de las partes no hay tradición ni se producen los efectos de ésta, lo que descarta por completo la posibilidad de una nulidad. Por lo mismo, el acto no es anulable si ni siquiera llegó a constituirse como tal, lo que impidió que produjera ningún efecto. Un hecho queda claro: se verifica voluntariamente una entrega. Pero quien la entregó a título de tradición no tenía la facultad para hacerlo, pues no era dueño de la cosa y tampoco era representante legal o mandatario del dueño que pudiera actuar en representación de éste.

En nuestro concepto, cuando el artículo 672 del CC menciona al tradente se refiere inequívocamente al dueño de la cosa. En caso contrario, dicha entrega no va a transferir el dominio pues falta la voluntad del dueño o del tradente, lo que significa que es inoponible a éste.

Cabe preguntarse a continuación, si el consentimiento del dueño constituye un requisito de validez de la tradición, en términos tales que si dicho consentimiento faltara, la tradición podría invalidarse a través de la declaración judicial de nulidad. En otras palabras, determinar si la falta de consentimiento del dueño constituye un vicio de nulidad de la tradición. Nos inclinamos por la respuesta negativa, tomando en consideración que el artículo 682 del CC contempla específicamente la sanción que la ley señala para la tradición hecha por quien no es el verdadero dueño de la cosa y que no es la nulidad, sino que impedir que la tradición produzca el efecto de transferir el dominio. Aun no siendo el tradente dueño de la cosa, la tradición existe como tal y surte efectos de significativa importancia: permite, por una parte, que el adquirente adquiera los derechos transferibles del tradente sobre la cosa; y, por la otra, que el adquirente adquiera la posesión de la misma, de acuerdo al artículo 683 del CC. No se necesita la declaración de nulidad de la tradición para que se produzcan las consecuencias anotadas, las que surgen por la sola circunstancia de que quien hizo la tradición resulta no ser el verdadero dueño de la cosa.

La tradición de cosa ajena no produce efectos con respecto al dueño de la cosa. La tradición es inoponible al dueño, de lo que resulta una consecuencia importante: si con ocasión de la entrega de la cosa que hizo una persona que no era dueña de la misma ni representaba al dueño, el verdadero propietario perdiera la posesión de la cosa, éste podría recuperarla ejerciendo la acción reivindicatoria. En cambio, si la tradición hecha por quien no es dueño de la cosa produjera efectos con respecto al propietario, éste perdería el dominio, dejaría de ser titular de dicho derecho real y, por lo mismo, no podría reivindicar, porque la acción reivindicatoria corresponde al dueño. Por excepción la tradición de una cosa ajena es oponible al dueño y produce efectos respecto a éste en los dos casos que menciona la ley: primero, cuando el dueño o el representante del dueño ratifican la tradición; y, segundo, cuando el que hizo la entrega de la cosa adquiere con posterioridad el dominio de la misma por cualquier modo de adquirir. En ambos casos la ley establece el efecto retroactivo consistente en fingir que quien entregó la cosa tenía la calidad de dueño al momento de la tradición.

Tanto la venta como la tradición de cosa ajena son inoponibles al dueño en el sentido, como veíamos antes, que no producen efectos respecto a éste. En relación con el dominio del dueño, ni la una ni la otra alteran o modifican tal derecho, que sigue radicado en el propietario, con lo cual no se manifiesta un menoscabo para el dominio que surja como consecuencia de la venta o de la tradición de una cosa ajena. Sin embargo, la tradición que hizo quien no es dueño a un tercero le va a significar la pérdida de la posesión de la cosa al verdadero dueño, y como consecuencia de lo anterior, eventualmente la pérdida del dominio, si el poseedor de la cosa adquiere el dominio de ésta por prescripción adquisitiva, todo lo cual puede evitar el dueño por intermedio de la acción reivindicatoria.

Dice el artículo 673 del CC: *“La tradición, para que sea válida, requiere también el consentimiento del adquirente o su representante. Pero la tradición que en su principio fue inválida por haber faltado este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación”.*

Como lo hemos dicho reiteradamente, toda entrega supone como elemento esencial, no sólo la voluntad de la persona que quiere traspasar la cosa a otra, sino que también la voluntad de la segunda, en el sentido que acepta recibir la cosa. No hay entrega por ende si no hay recepción de la cosa. No puede faltar voluntad del adquirente si éste personal y directamente recibe la cosa. Pero sí puede entenderse que falta la voluntad del adquirente si éste no recibió personalmente la cosa, sino que un tercero, que la recibió a nombre del primero sin tener poder para representarlo. El adquirente, en este caso, no es la persona a nombre de la cual se adquirió la cosa porque falta, precisamente, la voluntad de ésta y sabido es que nadie está obligado a adquirir derechos en virtud de una convención que opera el nacimiento o traspaso de éstos contra su voluntad. La tradición no es nula, sino que es ineficaz, pero solamente respecto de la persona a nombre de quien se recibió la cosa, para quien la tradición le es inoponible. Sin embargo, esta persona puede aceptar que la tradición que efectuó otra sin poder para representarlo produzca efectos a su respecto, es decir, que le sea oponible.

Dice el artículo 674 del CC: *“Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere, además, que éstos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal”.*

La representación puede ser legal o voluntaria. La diferencia entre ambas surge como consecuencia de que el poder que tiene una persona para representar a otra puede emanar directamente de la ley o de un acto voluntario del representado. El mandatario tendrá la calidad de representante voluntario del mandante si éste le ha dado poder de representación, es decir, le ha conferido la potestad de celebrar actos a su nombre. Es menester, además que el representante obre dentro de los límites de su mandato o representación legal, es decir, debe ajustarse estrictamente a las facultades que contempla el poder de representación. Y dichas facultades son, en el caso de la representación legal, las que establece la ley, y en el caso de la

representación voluntaria las que establece la persona que otorga el poder y, supletoriamente, las que contempla la ley en el contrato de mandato.

El artículo 674 del CC requiere para la validez de la tradición que el representante que actúe a nombre del tradente o adquirente obre dentro de los límites del poder, de lo que podría desprenderse que si no se cumple este requisito la tradición es nula. Creemos, sin embargo, que tampoco se da en este caso una situación de nulidad. La sanción de nulidad es coherente con la antigua doctrina que le atribuye a la representación la naturaleza jurídica de una ficción de la ley. Cabe tener en consideración que la teoría de la ficción de la ley para explicar la representación y sus efectos ha sido desechada por la doctrina moderna, que atribuye a la representación una naturaleza jurídica radicalmente diferente: la de modalidad del acto jurídico en que incide, porque con las modalidades se produce una alteración o cambio de los efectos o de la manera en que operan los efectos de un acto. Para que la representación opere jurídicamente como modalidad y se produzca la alteración que la modalidad supone, es indispensable que el representante se atenga estrictamente a las potestades que le confiere el poder. No significa ello que el acto celebrado adolece de nulidad en caso contrario. Simplemente no se producirá la alteración a que la modalidad está encaminada; los efectos del acto, siguiéndose los principios generales, sólo se radicarán en las partes que personal y directamente concurrieron a su celebración o, lo que es igual, el acto va a producir efectos respecto de la persona que actuó a nombre de otra y no respecto de la persona a nombre de quien la primera lo celebró.

En nuestro concepto, debe interpretarse el artículo 674 del CC sobre la base de que la representación es una modalidad de los actos jurídicos. En consecuencia, para que se produzcan los efectos de la representación, la parte que comparece a nombre del tradente o del adquirente debe obrar conforme al poder. Sólo así la tradición produce efectos para el representado. En cambio, sin quien hace la tradición a nombre del dueño obra sin ajustarse a las facultades o limitaciones del poder, la entrega que haga a nombre del tradente no transfiere el dominio al adquirente, pues quien hizo la entrega no era dueño de la cosa ni representaba verdaderamente al dueño en lo que atañe a la enajenación de la misma. Es decir, se producen los mismos efectos que veíamos al analizar la tradición cuando el tradente no es el dueño de la cosa. En tal caso, la tradición no afecta al dueño; es ineficaz respecto a éste porque le es inoponible, y su derecho de dominio se conserva incólume. Pero como la entrega que se hizo de la cosa en virtud de un título translativo de dominio permite a quien la reciba adquirir posesión, lo que necesariamente implica que el dueño pierde la posesión que tenía sobre la cosa, éste último podrá recuperarla entablando, por ejemplo, una acción reivindicatoria.

Por excepción, la entrega que hace a nombre del dueño una persona que no lo representa, se entiende que transfiere el dominio cuando el dueño ratifica la tradición en forma expresa o tácita. Por la ratificación el dueño acepta hacer oponibles para su persona los efectos del acto que, de otra manera, no lo alcanzarían. Algo similar ocurre en la situación inversa, cuando una persona

participa en la tradición como representante de quien tenía derecho a exigirla en virtud de un título translaticio de dominio.

Como conclusión, en la tradición hecha por un representante legal o mandatario que no obra dentro de los límites del poder, no existe un vicio que pueda acarrear la nulidad de la tradición. Lo que ocurre es, simplemente, que la tradición no produce efectos para el representado, lo que significa que no es oponible a ésta.

Dice el primer inciso del artículo 675 del CC: *“Para que valga la tradición se requiere un título translaticio de dominio, como el de venta, permuta, donación, etc.”.*

También esta disposición da a entender como un requisito de validez de la tradición, cuya omisión se sancionaría con nulidad, la existencia de un título translaticio de dominio. Pensamos que tampoco se trata aquí de un problema de nulidad. Su omisión no es causal de nulidad de la tradición, sino que impide que ésta produzca el efecto de transferir el dominio e, inclusive, impide que la entrega haga nacer posesión en la persona que recibe la cosa.

Dice el inciso segundo del artículo 675 del CC: *“Se requiere además, para que valga la tradición, que el título sea válido respecto de la persona a quien se le confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges”.*

Cuando el título adolece de algún vicio de nulidad, lo que se puede pedir es la nulidad del contrato y no la nulidad de la tradición. La declaración de nulidad del contrato produce importantes consecuencias en la tradición que se efectuó en virtud de tal título: impide que ella produzca el efecto de transferir el dominio, pues se supone en virtud del efecto retroactivo de la nulidad que nunca existió el título translaticio. Sin perjuicio de lo anterior, la declaración de nulidad del título no obsta a que la tradición que se hizo opere un efecto significativo: igual la persona que recibe la cosa adquiere la posesión. La ley, si bien aplica los efectos generales de la nulidad en cuanto a la transferencia del dominio, según los cuales mal podría la tradición operar dicha transferencia porque nunca existió el título nulo, hace una excepción a tales efectos en cuanto a la adquisición de la posesión, toda vez que entiende, en el hecho, existente el título en virtud del cual se hizo la tradición, para el solo objeto de que se justifique la posesión adquirida en virtud de ésta.

Dice el artículo 676 del CC: *“Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse, o de la persona a quien se hace la entrega, ni en cuanto al título. Si se yerra en el nombre sólo es válida la tradición”.*

El artículo 677 del CC agrega: *“El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título translaticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato y por la otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea*

cuando por las dos partes se suponen títulos translativos de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por otra donación”.

El legislador consideró necesario reglamentar el error en la tradición, si bien los artículos 676 y 677 del CC se inspiran en los principios generales establecidos para el error el llamado en doctrina esencial y para el error en la persona contenido en los artículos 1453 y 1455 respectivamente.

a) El error recae en la identidad de la especie que debe entregarse.

El error en la identidad de la cosa específica de que se trata constituye una de las situaciones de error esencial que recoge el artículo 1453 del CC. Por lo general el error se produce en el contrato, en el título translativo, y no en la tradición. Pero también puede haber error en la tradición misma, cuando el tradente equivocadamente cree entregar una cierta cosa determinada y en verdad entrega otra distinta, o cuando el adquirente cree equivocadamente recibir una cierta cosa determinada y en realidad recibe otra. El problema no es de fácil solución en la práctica, pues si el tradente que entregó que, en verdad, no debía pretende su restitución, el adquirente puede negarse a ella, alegando que desde el momento en que el deudor entregó una cosa distinta de la que debía con el consentimiento del acreedor, se extinguió la obligación por un modo de extinguir que no es el pago efectivo, sino que la dación en pago; y por la inversa, lo mismo podría argumentar el tradente si el adquirente alega que no se extinguió la obligación por el hecho de haber recibido una cosa distinta de la debida.

Insistimos que el error no se produce en el título, lo que significa que en virtud del título translativo las partes entendieron perfectamente y están de acuerdo en que una tiene que entregar un individuo de una especie determinada y la otra que tiene derecho a exigir la entrega de ese individuo. El error se produce en la tradición, pues quien cree estar entregando una cosa con una determinada identidad, en realidad entrega otra con una identidad distinta; y por la inversa, quien cree recibir una especie con una determinada identidad recibe, en verdad, una diferente.

En la tradición, aunque una de las partes sufra error en la identidad de la cosa que entrega o recibe, no puede desconocerse que existe el acuerdo de voluntades indispensable para que tal acto exista, en tanto el tradente entrega una cosa y el adquirente la recibe. Lo que ocurre aquí, claramente, es que el consentimiento de una de las partes está viciado porque creyó entregar una cosa y en verdad entregó otra, o porque creyó recibir una cosa y en verdad recibió otra. La diferencia entre las hipótesis de error del artículo 1453 del CC y del artículo 674 del CC justifica que el legislador hubiera dictado ésta última disposición, que de otro modo, y si hubiera coincidido con la situación del artículo 1453 del CC, hubiera sido innecesaria. Concluimos, en consecuencia, que el error en la identidad de la especie que debe entregarse en la tradición, constituye un vicio del consentimiento, que como tal se sanciona con la nulidad relativa de la tradición.

b) El error recae en la persona a quien se hace la entrega del bien, conforme al artículo 676 del CC.

En esta hipótesis el error no se advierte en el contrato sino que en la tradición. La tradición es uno de los actos llamados *intuitu personae*, pues la entrega debe hacerse en consideración a una persona determinada: aquella que tiene el derecho personal para exigirla. Por lo tanto, el error que sufre el tradente en la persona a quien hizo la entrega y que resulta del hecho de tener ésta una identidad distinta de la que creía, permite que la víctima del error solicite la rescisión o nulidad relativa de la tradición, que le permitirá recuperar la cosa entregada. Conforme al inciso final del artículo 676 del CC, el solo error en el nombre y no en la persona no invalida la tradición.

c) El error recae en el título, lo que supone que una parte entienda que el título es translaticio y la otra entiende que el título es de mera tenencia, por ejemplo, una parte tiene el ánimo de entregar a título de comodato y la otra tiene el ánimo de recibir a título de donación, o ambas partes entienden títulos translaticios de dominio, pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por otra donación, conforme lo señalado en el artículo 677 del CC.

Es la hipótesis de error esencial contenida en la primera parte del artículo 1453 del CC. Creemos que el artículo 677 del CC es innecesario desde el momento que a idénticas conclusiones se habría llegado aplicando exclusivamente el artículo 1453 del CC. La falsa o equivocada representación de la realidad que constituye jurídicamente el error, se produce, en este caso, en el contrato translaticio y no en la tradición, de lo que resulta que el contrato translaticio va a ser ineficaz para sustentar, como título, la tradición que pudiera efectuarse en virtud de él. El error de las partes es de hecho: una entiende que entrega en arrendamiento una cosa, por ejemplo, y la otra entiende que tal cosa le fue donada. Es evidente que falta el consentimiento de las partes en lo relativo al contrato que celebran; no se produce el acuerdo de voluntades indispensable para que el acto nazca, lo que deriva del hecho que la voluntad de cada una de las partes está orientada o dirigida a un contrato totalmente diferente del que la otra cree estar celebrando. Si no hay consentimiento, no hay contrato, lo que es jurídicamente consistente, a nuestro juicio, con la sanción de inexistencia que postula la doctrina.

Creemos que en este caso el error no constituye un vicio del consentimiento, porque no hay consentimiento, y no puede estar viciado lo que no existe. Sea que se considere que no hay contrato o que lo hay, caso en que éste debe anularse, de lo que no cabe duda es que la entrega que pudo haberse efectuado de la cosa no justifica la posesión de la misma, pues para adquirirla es indispensable que la entrega se haya fundamentado en un título translaticio de dominio, entendido en su carácter de tal por ambas partes.

En la segunda situación del artículo 677 del CC ambas partes coinciden en que el contrato que celebran es translativo de dominio y que una de ellas está obligada a hacer la tradición de la cosa que permita la transferencia del dominio. Discrepan, en cambio, en la especie de contrato translativo que cada una cree celebrar. Tampoco en este caso se advierte el acuerdo de voluntades indispensable para la existencia de un contrato. En consecuencia, la tradición que se pudo haber efectuado no transfiere el dominio porque no existe jurídicamente el contrato translativo que ésta requiere para producir tal efecto. En nuestra opinión, debería entenderse que la tradición permite la adquisición de la posesión, porque no puede desconocerse como una realidad que la tradición que efectuó una de las partes se hizo con el entendimiento de la otra de que debía permitir la transferencia de dominio, toda vez que ambas coincidían en que la obligación de hacer la tradición emanaba de un título translativo. Si bien la tradición se funda en un contrato que en estricto rigor no existe, podría considerarse dentro del cuarto número del artículo 704 del CC, que considera meramente putativos, es decir, no reales pero con una apariencia de realidad lo suficientemente sólida como para justificar que sirvan como título posesorio.

Por último, el artículo 678 del CC señala que si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error de éstos invalida la tradición, disposición que viene a zanjar una antigua discusión doctrinal.

Tema 12: Desde cuándo se puede pedir la Tradición.

El artículo 681 del CC dispone: *“Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no haya plazo pendiente para su pago; salvo que intervenga decreto judicial en contrario”*.

En consecuencia, la exigibilidad de la tradición dependerá de si se ha fijado o no un plazo en el contrato translativo. En el primer caso se podrá exigir una vez vencido el plazo; y, en el segundo, inmediatamente después de perfeccionado el contrato. Lo anterior se entiende siempre que no intervenga decreto judicial en contrario, esto es, una resolución del juez que impida al deudor cumplir su obligación de hacer la tradición y al acreedor exigirla, como por ejemplo, una prohibición de enajenar o, más amplia, de efectuar cualquier acto en relación con la cosa.

12.1 Tradición bajo Condición.

El artículo 680 del CC dispone: *“La tradición puede transferirle dominio bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese. Verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago, o hasta el cumplimiento de una condición”*.

12.2 Tradición bajo condición suspensiva.

Se produce cuando el tradente entrega la cosa al adquirente, pero bajo la modalidad de que la entrega efectuada no se entiende que transfiere el dominio, a menos que se cumpla una determinada condición.

Los efectos de la tradición bajo condición suspensiva, dependen de los estados en que puede encontrarse la condición:

- i. **Pendiente la condición** debe entenderse que quien recibe la cosa no adquiere el dominio ni la posesión de la misma, sino que la mera tenencia, derivada del hecho que tiene la cosa a nombre de otro, reconociendo dominio ajeno.
- ii. **Cumplida la condición**, la persona que recibió la cosa adquiere el dominio o, lo que es lo mismo, la tradición que se efectuó con anterioridad opera el efecto de transferir el dominio. Ello se explica por el efecto retroactivo de la condición cumplida. Asimismo, debe entenderse que la entrega de la cosa hizo nacer posesión en el adquirente desde la fecha de la tradición.
- iii. En el evento que la **condición falle**, junto con frustrarse definitivamente la expectativa que tenía la persona que recibió la cosa de adquirir el dominio, se entiende que jamás tuvo derecho a que la tradición que se le hizo de la cosa le permitiera adquirir el dominio o la posesión de la misma, con lo que su relación con la cosa no era más que la de mero tenedor.

12.3 Tradición bajo condición resolutoria.

Ella supone que se hace una tradición y que ésta opera los efectos que le son propios, pero bajo el entendido de que el dominio que se adquiere en virtud de ella está expuesto a extinguirse si se cumple una determinada condición.

Los efectos de la tradición bajo condición resolutoria dependen del estado en que se encuentre la condición:

- i. **Pendiente la condición resolutoria**, la tradición efectuada produce todos los efectos que le son propios: permite adquirir el dominio y la posesión de la cosa que recibió el adquirente, de lo que cabe concluir que los efectos de la tradición no están subordinados al cumplimiento de una condición. Sin embargo, el dominio que se adquiere en virtud de la tradición es un derecho afecto al riesgo de extinción. Pero mientras no se cumpla la condición, el adquirente, como dueño, puede ejercer todas

- las facultades a que lo autoriza el derecho real de dominio pues la condición no limita el ejercicio del derecho.
- ii. Cumplida la condición resolutoria, se extingue el derecho de dominio que se había adquirido en virtud de la tradición, entendiéndose, a mayor abundamiento, en virtud del efecto retroactivo de la condición resolutoria cumplida, que la tradición jamás transfirió el dominio y que el adquirente nunca lo adquirió. Creemos, sin embargo, que lo anterior no obsta para estimar que el adquirente adquirió la posesión conforme al cuarto número del artículo 704 del CC, pues creemos que la tradición que se resuelve por el cumplimiento de la condición resolutoria, constituye un título meramente putativo.
 - iii. **Fallida la condición resolutoria**, desaparece la incertidumbre en torno a la extinción del derecho que adquirió la persona a la cual se hizo la tradición. El derecho de dominio se consolida definitivamente, entendiéndose, a mayor abundamiento, que se adquirió por la tradición pura y simplemente, sin que hubiera estado afecto a la posibilidad de extinción.

12.4 Cláusula de no transferirse el dominio sino por el pago del precio o hasta cumplirse una condición.

El segundo inciso del artículo 680 del CC se refiere a la estipulación en el contrato de compraventa de una cláusula en virtud de la cual las partes convienen que la tradición que haga el vendedor al comprador no transfiere el dominio, mientras el comprador no pague el precio o se cumpla otra condición, y señala la ley los efectos de dicha estipulación: **la tradición hecha por el vendedor no permite al comprador adquirir el dominio, entendiéndose, en virtud del efecto retroactivo de la condición cumplida, que la transferencia del dominio operó desde la fecha de la tradición una vez que la condición se cumple.** La ley aplica el principio general contenido en el artículo 680 del CC. En tal caso, la tradición que se haga al comprador será una tradición bajo condición suspensiva, porque la adquisición del dominio requiere, no sólo el modo de adquirir, tradición, sino que se verifique un hecho futuro e incierto, el pago del precio por el comprador o cualquier otra condición suspensiva.

De acuerdo con la disposición de carácter general que permite la tradición bajo condición suspensiva, el artículo 680 del CC, no presenta nada de particular que el legislador haya decidido aplicarlo a la tradición en la compraventa. Sin embargo, cabe advertir que el artículo 680 del CC ha sido duramente criticado porque se encuentra en abierta contradicción con el artículo 1874 del CC, ubicado en la compraventa, que dispone: “La cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud de la paga del precio, no producirá otro efecto que el de la demanda alternativa enunciada en el artículo precedente; y pagando el comprador el precio, subsistirán en todo caso las enajenaciones que hubiere hecho de la cosa o los derechos que hubiere constituido sobre la cosa en el tiempo intermedio”. El artículo 1873 del CC al cual se remite señala: “Si el comprador

estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios”.

Si se aplica el artículo 680 del CC el vendedor puede demandar la restitución de la cosa porque el comprador no adquirió el dominio de la misma. El vendedor, en su calidad de dueño, puede exigir que el comprador se la restituya. Si se aplica el artículo 1874 del CC el vendedor no puede demandar directamente la restitución de la cosa, porque la tradición que hizo al comprador, aún bajo la condición antes mencionada, le transfirió a éste el dominio. Lo único que puede hacer el vendedor, toda vez que se producen los efectos que señala la ley por el incumplimiento de la obligación de una de las partes en un contrato bilateral, es demandar la ejecución forzada de la obligación del comprador de pagar el precio o demandar la resolución del contrato por el cumplimiento de la condición resolutoria tácita. Si opta por la resolución del contrato y ésta es declarada por el juez, se entiende que el contrato nunca existió, por lo que la tradición que se hizo en mérito de él no transfirió el dominio al comprador, de lo que resulta la obligación que asume éste de restituir la cosa.

Como es posible apreciar, ambos contratos atribuyen a la cláusula de no transferir el dominio sino por el pago del precio efectos contradictorios, de lo que cabe preguntarse cuál de las dos disposiciones es la que debe aplicarse. La doctrina nacional es unánime en el sentido que prima el artículo 1874 del CC porque es una norma especial contenida en el título de la compraventa, conclusión que se sustenta en el artículo 13 del CC que señala: “Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere oposición”.

Unidad 4: De La Posesión.

Tema 1: Conceptos generales.



La posesión está definida en el artículo 700 del CC como: **“La tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da portal la tenga por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo”.**

La ley atiende, en primer lugar, a una situación de hecho: la tenencia de una cosa determinada; y, en segundo lugar, a un concepto propiamente jurídico: el ánimo de señor y dueño del que tiene la cosa. El legislador sigue la doctrina del derecho romano, que considera dos elementos constitutivos de la posesión: el corpus, elemento objetivo, tenencia de una cosa, y el animus, elemento subjetivo, el ánimo de señor y dueño.

El elemento hábeas se da no sólo cuando la cosa la tiene por sí mismo el poseedor, sino que también cuando la cosa la tiene otra persona en lugar y a nombre de aquél. Aún cuando entregue la cosa a un tercero por un título de mera tenencia, conserva el corpus porque si bien ha dejado de tener por sí mismo la cosa, el tercero la tiene a nombre y en lugar de aquél.

Para comprender en qué consiste el ánimo de señor y dueño, primeramente, **de acuerdo a la definición de posesión, está solo la tiene el dueño de una cosa o el que se da por tal.** En consecuencia, para que el dueño o el que se da portal adquiera la posesión de la cosa, es indispensable que la tengan, por sí o por un tercero que la tiene a nombre y en lugar de aquél, con la voluntad, con la intención de dueño. La voluntad o la intención de dueño que constituye el ánimo a que se refiere la ley, no significa la convicción o creencia de ser dueño de la cosa. Nos parece, en cambio, más preciso decir que el poseedor se da por dueño de la cosa, como señala el CC, sea que sienta o no que tiene tal calidad. Que se dé por dueño, significa que se representa en su psiquis la relación con la cosa como dueño o como si fuera dueño de la misma. En nuestro concepto, no se requiere para la adquisición de la posesión que la voluntad o la intención de dueño se exteriorice o manifieste a través de una declaración o comportamiento. Y ello deriva del hecho de que es indispensable para que una persona pueda darse por dueño de una cosa, que la tenga en su poder por un título que justifique la posesión, esto es, un título posesorio, teniendo tal calidad los modos de adquirir el dominio que establece la ley. El título posesorio permite presumir que quien tiene la cosa por dicho título lo hace con ánimo de señor y dueño.

El título posesorio es el antecedente jurídico que justifica la adquisición de la posesión, por ejemplo, la tradición que se hizo como consecuencia del título translativo basta para presumir tal voluntad o intención. En cambio, el solo título de mera tenencia, como el arrendamiento, jamás permite que el que tiene la cosa pueda, jurídicamente, darse por dueño de la misma y adquirir su posesión, puesto que revela inequívocamente en quien recibió la cosa una intención diametralmente opuesta a la de dueño.

El ánimo de señor y dueño, en cuanto se manifiesta o exterioriza, implica, en relación con la cosa, la ejecución de actos de aquellos a que sólo tendría derecho el dueño. Estos son los llamados actos posesorios, que se requieren, no para adquirir la posesión sino, generalmente, para probarla, y de todas maneras para adquirir el dominio por prescripción, como se verá más adelante.

Tema 2: Relaciones jurídicas que se pueden tener sobre una cosa: dominio, posesión y mera tenencia.

2.1 Relación de Dominio.

Para adquirir el dominio de una cosa se requiere siempre un modo de adquirir, teniendo tal carácter sólo los hechos jurídicos que determina la ley. Nuestro CC considera como modos de adquirir el dominio los siguientes: **ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte, prescripción y la ley**. Tratándose de los modos de adquirir originarios, la ley considera que dan nacimiento a una relación jurídica que antes no existía o que si existía en un anterior titular, no presenta ninguna relevancia ni produce efecto alguno en el dominio que se adquiere. Tienen el carácter de modos de adquirir originarios la ocupación, la accesión, la prescripción y la ley. En éstos, la adquisición del dominio se verifica por la sola concurrencia de los supuestos de hecho a los cuales la ley atribuye el valor de modo de adquirir originario. En cambio, en los modos de adquirir derivativos, que son la tradición por causa de muerte y la tradición, el dominio que se adquiere es exactamente el mismo que tenía un titular anterior. Es el mismo dominio que deriva o se desplaza hacia la persona del nuevo titular. Como consecuencia de lo anterior, para que opere la adquisición del dominio en los modos de adquirir derivativos, no basta con la sola concurrencia de los supuestos de hecho a los cuales la ley atribuye el valor de modo de adquirir, sino que es necesario, además, que el antecesor de quien deriva el dominio, tradente en la tradición o causante en la sucesión por causa de muerte, haya sido dueño de la cosa. Por lo anterior, la prueba del dominio que se adquiere por un modo derivativo se presenta en la práctica como extremadamente difícil, tanto así, que los romanos la llamaban la prueba diabólica. Esta dificultad probatoria se salva, precisamente, recurriendo a la prescripción, que en esta materia revela gran utilidad práctica.

2.2 Relación de Posesión.

Para adquirir la posesión de una cosa se requiere un título posesorio. Por título posesorio se entiende el antecedente jurídico que justifica la adquisición de la posesión, y que la ley considera títulos posesorios a los mismos modos de adquirir, de lo que resulta que el modo de adquirir puede producir un doble efecto: permitir la adquisición del dominio, por una parte; y, permitir la adquisición de la posesión, por la otra. Así, el dominio puede estar unido a la posesión, lo que ocurre cuando una persona que adquiere el dominio de una cosa, la tiene bajo su poder con ánimo de señor y dueño. Se habla, en tal caso, de dueño y poseedor, a la vez. O bien, el dominio puede estar desprovisto de la posesión. Cabe desde ya advertir que la pérdida de la posesión no resulta indiferente para el dueño, toda vez que la pérdida de la posesión que tenía una persona implica que otra la adquiere, y ésta podrá, generalmente, adquirir el dominio por prescripción. Finalmente, también se puede advertir la posesión desprovista del dominio, caso en el cual se encuentra la persona que adquiere la posesión por un título posesorio, un modo de adquirir el dominio, al cual le falta alguno de los requisitos que permitan la adquisición del dominio, por ejemplo, la tradición hecha por quien no es dueño.

Una vieja discusión doctrina se produce en relación con si la posesión es un hecho o un derecho. Para algunos la posesión sería un derecho puesto que la ley lámpara con las acciones posesorias y con la acción publiciana. La posesión sería, entonces, el derecho que se ejerce sobre una cosa determinada y que permite al titular usar, gozar y disponer de ella, o sea, vendría a ser prácticamente lo mismo que el dominio, con la diferencia que el poseedor no necesariamente es el dueño. Sin embargo, no es posible desconocer que este derecho es esencialmente vulnerable, puesto que se pierde si una persona se apodera de la cosa que otro posee, o en el caso del poseedor no dueño, si el propietario reclama y obtiene la restitución de la posesión, lo que deja en evidencia, en nuestro juicio, que la relación de posesión se sustenta exclusivamente en una realidad de hecho, la tenencia de la cosa con ánimo de dueño. La doctrina resuelve la discusión diciendo simplemente que la posesión es un estado de hecho protegido por el derecho. En nuestro CC, la propia definición del artículo 700 deja de manifiesto que para configurarla la ley atiende a una simple situación de hecho: la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, sin que aluda, como lo hace cuando define un derecho, a las facultades del titular. Confirma lo anterior la circunstancia que la posesión, como una mera realidad de hecho, no se transfiere ni se transmite, sino que comienza con el adquirente, conforme al artículo 719 del CC. Sobre la base de esta situación de hecho, la ley reputa dueño al poseedor mientras otra persona no justifica serlo. Con esta presunción de dominio la ley protege al poseedor cuando, como consecuencia de un conflicto, dos personas alegan, cada una de ellas, la propiedad sobre una cosa: aquel que posee la cosa es reputado dueño. Sin embargo, y como dicha presunción es simplemente legal, la persona que disputa el dominio y que no está en posesión de la cosa puede desvirtuarla, probando que tiene la calidad de dueño.

En cuanto a la posibilidad de poseer una cosa por varios títulos, he dicho que se pueda poseer una cosa por varios títulos es uno de los principios que la doctrina contempla en materia posesoria y que el CC reproduce en el artículo 701 que dispone: “Se puede poseer una cosa por varios títulos”. A diferencia del dominio, que sólo se adquiere por un modo de adquirir, se puede tener la calidad de poseedor de una cosa por varios títulos distintos, lo que quiere decir que es posible que la posesión que adquiere una persona se justifique por más de un solo hecho jurídico.

2.3 Relación de Mera Tenencia.

El artículo 714 del CC dispone: **“Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestrado, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno”**.



Fácil es advertir que la mera tenencia y la posesión presentan un elemento común: la tenencia de una cosa. La diferencia está en el ánimo, en la intención o voluntad con que se tiene la cosa, lo que se desprende inequívocamente del título en que una y otra se fundan: en la primera, un título de mera tenencia; en la segunda, un título posesorio. En la relación de posesión no es indispensable que el poseedor tenga la cosa por sí mismo, siendo posible que otra persona tenga la cosa en su poder, siempre que lo haga a nombre y en lugar del poseedor. Lo anterior lleva a concluir, por una parte, que la relación jurídica de mera tenencia sobre una cosa no puede concebirse sin que otra persona distinta tenga la posesión de la misma; y, por otra, que no es imposible concebir más de una relación jurídica sobre una cosa con titulares diferentes.

La relación de mera tenencia sobre una cosa deriva de un título de mera tenencia. El artículo 714 del CC menciona varios ejemplos de meros tenedores. Las palabras reconociendo dominio ajeno hay que tomarlas, a nuestro juicio, con cuidado. No designan un ánimo o intención real o verdadero, en el sentido que el mero tenedor en su fuero interno reconoce que otra persona es el dueño, pues si tal fuera su alcance cabría concluir que por el solo hecho que una persona que inició una relación de mera tenencia sobre una cosa cambie de intención o voluntad y deje de reconocer dominio ajeno, cambiaría la relación de mera tenencia por otra de posesión, lo que creemos imposible. A nuestro juicio la ley presume que todo título de mera tenencia lleva implícito el reconocimiento de que otra persona tiene la posesión o el dominio de la cosa. Lo que hay que distinguir y tener claro como perfectamente posible es que una persona, de un lado, sea dueño o poseedor de un derecho y, de otro, mero tenedor de la cosa sobre la cual éste se ejerce.

La relación de mera tenencia, al igual que la de dominio y posesión, se ejerce sobre cosas determinadas en su especie. Y por regla general es inmutable, es decir, no cambia por el lapso del tiempo, lo que sí puede ocurrir con la relación de posesión que puede transformarse en la de dominio por el transcurso del tiempo necesario para que opere la prescripción. El artículo 716 del CC señala: “El simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, salvo la regla tercera del artículo 2510 del CC”.

Tema 3: Clasificaciones de la Posesión.

La posesión admite diversas clasificaciones:

- Útil e Inútil.
- Regular e Irregular.
- Viciosa y No Viciosa.

3.1 Posesión Útil e Inútil.

En doctrina se llama **posesión útil la que habilita para ganar el dominio por prescripción**, y **posesión inútil a la que no sirve para este objetivo**. En Chile la gran mayoría de los autores coincide en que el CC no reconoce esta clasificación, pues toda posesión, sea regular o irregular, e incluso las posesiones viciosas, permiten que se pueda adquirir el dominio por prescripción. En nuestro concepto, la clasificación que distingue entre posesión útil e inútil encuentra asidero en el CC, pues de diversas disposiciones se desprende que no basta el mero hecho de la posesión para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. No todo poseedor puede llegar a ser dueño por prescripción, delo que se infiere que la posesión, en este caso, será inútil. Sostenemos que la posesión que no lleva a adquirir el dominio por prescripción es aquella que no va aparejada del ejercicio de actos posesorios, es decir, de actos positivos que sólo hubiera tenido derecho a ejecutar el dueño, y que para prescribir debe necesariamente efectuar el poseedor sin pedir el consentimiento o autorización de aquél.

Nuestra interpretación se funda en un hecho indiscutido: *que la prescripción supone como elementos esenciales, por una parte, la inactividad e indiferencia del dueño; y, por la otra, la actividad del prescribiente, lo que significa que el poseedor no puede limitarse a tener la cosa en su poder con el ánimo de señor y dueño que presume la ley en el título posesorio, sino que es indispensable que manifieste o exteriorice la voluntad o intención de dueño a través de la ejecución de aquellos actos que sólo el dueño hubiere podido ejecutar*. Precisamente tales actos externos y ostensibles son los que permiten a quien puede oponerse a la prescripción advertir o enterarse de que otra persona posee la cosa y revertir esta situación.

La interpretación que postulamos, en el sentido que la ejecución de actos posesorios es de la esencia de la prescripción se ve corroborada por lo dispuesto en el primer número del artículo 2502 del CC que considera interrupción natural de la posesión cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios. Con mayor razón aun, si el poseedor no ejecuta actos posesorios, no exterioriza su ánimo, no tiene lugar la institución de la prescripción, por lo que su posesión será inútil. Otro fundamento lo encontramos en el artículo 894 del CC que establece el tipo de acción reivindicatoria que la doctrina llama acción publiciana al señalar: *“Se concede la misma acción, aunque no se pruebe dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poder ganarla por prescripción”*. Del artículo se infiere que quien entabla esta especie de acción reivindicatoria debe cumplir dos requisitos: haber sido poseedor regular de la cosa cuya posesión perdió; y haberse encontrado en el caso de poderla ganar por prescripción. Este último requisito estaría absolutamente demás si toda posesión y, con mayor razón la posesión regular, que por su calidad es la que privilegia la ley, fuera útil, en el sentido que llevara a prescribir. Ello comprueba que sólo el poseedor que ha ejercido actos posesorios se halla en el caso de poder ganar el dominio por prescripción. Cabe hacer presente que la referencia al poseedor que se halla en el caso de ganar el dominio por prescripción ha sido objeto de especial reflexión por la doctrina nacional, dudosa del alcance que corresponde atribuirle.

3.2 Posesión Regular e Irregular.

El artículo 702 del CC dispone: *“Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es translaticio de dominio, es también necesaria la tradición. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título”*. Por su parte, el artículo 708 del CC señala: *“Posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos señalados en el artículo 702 del CC”*.

Por consiguiente, los **requisitos de la posesión regular**, de acuerdo con el artículo 702 del CC, son los siguientes:

- a) Justo título.
- b) Buena fe al momento de adquirirse la posesión.
- c) Tradición si el título es translaticio de dominio.

Estimamos que el CC incurre en un error. La tradición no es un requisito para adquirir la posesión regular cuando el título es translaticio de dominio, como lo dice el segundo inciso del artículo 702

del CC, sino que es un requisito imprescindible cuando el título es translaticio para que se pueda adquirir la posesión, sea ésta regular o irregular o de la clase que fuere. A nuestro juicio, sin tradición no es que no se adquiere posesión regular, sino que peor aún, no se adquiere posesión irregular ni de ninguna clase. Si el vendedor no hace tradición de la cosa, naturalmente el comprador no adquiere el dominio, pero tampoco el comprador adquiere la posesión. La única posibilidad sería que una de las cláusulas del contrato translaticio contemplara que, no obstante el título de enajenación, el vendedor conserva la cosa pero como mero tenedor, caso en el cual la ley finge la tradición. Aceptar que el comprador adquiere posesión, aunque sea irregular, sobre la cosa, en circunstancias que el vendedor no ha hecho la tradición, implica suponer que el sólo contrato translaticio de dominio es título posesorio, lo que pugna abierta y manifiestamente con los principios generales en materia posesoria, en virtud de los cuales el título posesorio es un modo de adquirir, en la especie, la tradición, pues ésta, según la naturaleza misma de las cosas, es la que permite la tenencia indispensable para adquirir la posesión. Por otra parte, tratándose de la adquisición de la posesión de bienes raíces, también es evidente que el sólo contrato translaticio no hace nacer la posesión, conforme al artículo 724 del CC que expresamente señala que si la cosa es de aquellas para cuya tradición se requiere inscripción, nadie puede adquirir la posesión sino por este medio.

Sostenemos, en consecuencia, que el contrato translaticio jamás permitirá por sí sólo, adquirir posesión. El título posesorio es la tradición y no el contrato. La tradición por cualquier medio idóneo para operar el traspaso de la cosa y la recepción de la misma, sea una entrega real, simbólica o ficta permite adquirir posesión, toda vez que el adquirente, sólo en virtud de la recepción de la cosa, va a poder incorporarla bajo su poder de dominación y constituir así la tenencia, el corpus, que requiere como elemento esencial la relación jurídica de posesión.

En mérito de lo expuesto, somos de opinión que los únicos requisitos de la posesión llamada regular, que es una posesión privilegiada, ya que el poseedor puede adquirir el dominio por prescripción ordinaria, que supone un breve tiempo de posesión y, además, está amparada por una acción real, la publiciana, son justo título y buena fe, lo que concuerda, por lo demás, con el mensaje del CC. Creemos, por consiguiente, que la referencia que hace el CC a la tradición como requisito de la posesión regular cuando el título es translaticio de dominio es equívoca y poco afortunada, en cuanto permite desprender que si falta la tradición se adquiere posesión irregular. Naturalmente cuando el título es translaticio, para adquirir la posesión regular se requiere tradición. Pero si hay un contrato translaticio también se requiere tradición para adquirir posesión irregular, y para concluir así no se requiere una disposición expresa de la ley, pues ello fluye naturalmente de los principios generales de la posesión y del concepto de títulos posesorios. Como mencionábamos antes, en nuestro concepto, la posesión regular debe cumplir dos requisitos: justo título y buena fe, a cuyo estudio nos abocaremos a continuación.

a) Justo Título en la Posesión.

El justo título es constitutivo o translativo de dominio. El artículo 703 del CC dispone: *“Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son translativos de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos, etc. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Las transacciones, en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes no forman nuevo título, pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo”*. De la disposición transcrita se desprende que los justos títulos en materia posesoria se clasifican en constitutivos y translativos.

Creemos que el artículo 703 del CC tiene algunas imprecisiones en el concepto de título, siempre que esta palabra se entendiera bajo la acepción jurídica de antecedente que justifica la adquisición de la posesión, que la ubicación del artículo permite presumir. La primera, que sea título posesorio la prescripción, en circunstancias que mal puede considerarse a ésta como antecedente jurídico para adquirir la posesión anterior al prescribiente, que necesariamente debe fundarse en un título diferente.

Lo que apreciamos como un error grave y más que una imprecisión de lenguaje o de conceptos, es que el legislador hubiera considerado que los contratos translativos de dominio pueden ser un título posesorio. Ello porque, como lo hemos dicho reiteradamente, el solo contrato translativo no habilita para poseer, siendo necesaria la tradición para que el adquirente entre a poseer. El título posesorio es la tradición y no el contrato. La hipótesis del error del legislador se desvanece, sin embargo, si se tiene en cuenta que la palabra título se utiliza con diversas acepciones y significados. Generalmente la ley la usa como sinónimo de antecedente que permite o posibilita la adquisición del dominio por un modo de adquirir y, excepcionalmente, en materia posesoria como antecedente que justifica la posesión. La doctrina romana que inspira a nuestro CC requiere para la adquisición del dominio, por una parte, un modo de adquirir, como fuente principal y directa; y, por la otra, un título, entendido como antecedente que justifica la adquisición del dominio, como fuente indirecta. En los modos de adquirir originarios, el título, que prácticamente se confunde con el modo de adquirir, se llama título constitutivo, teniendo tal carácter la ocupación, la accesión y la prescripción. La distinción entre título y modo en los modos de adquirir originarios, no es más que una abstracción o sutileza jurídica. En realidad, unos mismos hechos jurídicos desempeñan el rol de título y modo, por lo que en el hecho éstos se confunden. La situación es muy distinta en los modos de adquirir derivativos, pues en éstos la distinción entre el modo y el título se advierte con toda claridad. Lo anteriormente expuesto revela, en nuestra opinión, que cuando el legislador en el artículo 703 del CC se refiere a los títulos constitutivos o translativos de dominio lo hace pensando en el título como antecedente necesario para que opere el modo de adquirir, pero no como título como antecedente necesario para adquirir la posesión. De ello

proviene, sin duda, la consideración de que los contratos translaticios sirven como título, pero en ningún caso la posesión como parece insinuar, sino que para adquirir el dominio por tradición.

El alcance que debe darse al artículo 703 del CC es el siguiente: toda posesión necesita un título, entendido cabalmente éste como el antecedente jurídico que la ley considera idóneo para que la posesión nazca. El título posesorio es un modo de adquirir el dominio, sea éste derivativo u originario. El modo de adquirir puede o no operar el nacimiento o traspaso del dominio; ello dependerá de si se cumplen o no los requisitos que establece la ley para que se produzca el efecto propio del modo de adquirir. Sin perjuicio de lo anterior, el modo de adquirir siempre constituye un título posesorio, porque el adquirente en virtud de aquel adquiere jurídicamente la relación de posesión sobre una cosa. Tal como lo señala el artículo 703 del CC, son títulos posesorios la ocupación y la accesión; en cuanto a la prescripción, hemos dicho que sólo puede constituir un título posesorio en cuanto justifica la posesión posterior a la fecha en que la prescripción operó, y no para justificar la posesión anterior. Los otros títulos posesorios son la ley, por una parte, y la tradición y la sucesión por causa de muerte, por la otra.

Otro comentario que surge del artículo 703 del CC es la afirmación que éste contiene, en cuanto a que pertenecen a la clase de los títulos translaticios de dominio, las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. Los títulos antes mencionados constituyen lo que la doctrina llama títulos meramente declarativos de dominio, pues se limitan a declarar o reconocer un dominio preexistente, sin que en virtud de ellos, o como consecuencia de ellos, opere la transferencia del dominio. La partición, lisa y llanamente se limita a reconocer un derecho preexistente y no a crear un nuevo derecho o a traspasar el de un anterior titular. Cabe observar, por otra parte, si la partición en virtud de la cual se adjudica un bien a uno de los comuneros puede constituir un título posesorio. Por el efecto declarativo de la partición, se supone que el adjudicatario adquirió la posesión no cuando se le entregó la cosa que le permitió tenerla como propietario exclusivo, sino que desde la muerte del causante. Y la posesión que se supone adquirida desde ese momento tiene como título posesorio también en el ejemplo, la sucesión por causa de muerte. De lo dicho se hace posible concluir que las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición no son títulos translaticios de dominio, sino meramente declarativos.

El artículo 703 del CC concluye diciendo que las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo título para legitimar la posesión y que las transacciones, en cuanto se limitan a reconocer o declarar derechos preexistentes no forman nuevo título, pero en cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado, constituyen un título nuevo. No merecen comentario especial.

Cabe preguntarse, finalmente, si la transacción puede ser título posesorio. De acuerdo con lo que hemos expresado antes, es imposible considerar como título posesorio al contrato de transacción,

porque los contratos no tienen tal calidad. Una cosa muy distinta es que la tradición de la cosa no disputada que se hace como consecuencia de la transacción puede ser un título posesorio, en el sentido que la parte que recibe dicha cosa adquiere la posesión de la misma, fundamentada en el título tradición.

➡ **Títulos No Justos en la Posesión.**

El artículo 704 del CC dispone: “No es justo título: 1º El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende; 2º El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo; 3º El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial no lo ha sido; y, 4º El meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad heredero, el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc. Sin embargo, al heredero putativo a quien por decreto judicial se haya dado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto, como al legatario putativo el correspondiente acto testamentario que haya sido judicialmente reconocido”.

El artículo 704 del CC nos permite inferir que los títulos no justos o injustos que enumera, presentan en común el hecho de fundarse en una mera apariencia, porque realmente no existen en la forma o de la manera con que se presentan. Bajo esta perspectiva, creemos que todos son putativos o aparentes, por lo que el cuarto número describiría la situación general, y los números anteriores serían casos específicos de títulos meramente putativos.

i. Título falsificado.

En una escritura pública de compraventa de bien raíz aparece una persona vendiendo el bien a un tercero e inscribiéndolo a su nombre, en circunstancias que la primera no compareció nunca sino que lo hizo otra persona suplantándolo y haciéndose pasar por él. El dueño del inmueble no tiene la calidad de parte en el contrato ni en la tradición, por lo que no cabe sino concluir que falta su voluntad en ambas convenciones que, en estricto rigor, serían inexistentes. Inclusive si se estimara que el acto jurídico tradición existe porque se dan sus elementos esenciales, dos parte, una que hace la entrega y la otra que recibe, la tradición se hizo en virtud de un contrato que no ha sido otorgado realmente por la persona que se pretende no puede transferir el dominio porque no existe el contrato. No hay verdaderamente un título translativo de dominio entre las personas que aparecen otorgándolo; falta el título que posibilite la transferencia del dominio y que permita presumir la intención de transferirlo. En consecuencia, la aplicación rigurosa de los principios generales de los actos jurídicos y específicos en materia de tradición y de títulos posesorios, lleva a concluir que la tradición no transfiere el dominio ni permite adquirir la posesión. Sin embargo, y en homenaje a una apariencia de realidad, la ley permite que la tradición se sustente en el contrato translativo aparente, para el sólo efecto de hacer nacer la posesión. Pero como el título falsificado, en concepto de la ley no es justo, la posesión que se adquiere por la tradición que se

hizo en mérito de aquel es, cualitativamente, inferior a la que se habría adquirido si el título hubiese sido verdadero y, a contrario sensu, justo. El adquirente de la tradición solo adquiere posesión irregular, porque falta el requisito justo título de la posesión regular. En suma, la tradición no opera la transferencia del dominio, pero va a constituir título posesorio que habilitará al poseedor que ejecuta actos posesorios para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva ordinaria.

ii. Título conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo.

Este caso difiere del anterior en que quien comparece en el acto atribuyéndose la calidad de representante de otra persona, no está suplantándola ni se hace pasar por ésta. Por el contrario, comparece en su propio nombre y con su identidad real, pero lo hace como representante de otro sin tener, en verdad, poder de representación. Las circunstancias antedichas no invalidan el contrato, que será, sin embargo, inoponible a la persona a nombre de la cual lo celebró otra que no tenía poder para representarla. No puede decirse en este caso, a diferencia del anterior, que no hay título translaticio de dominio, por lo que la tradición que se efectúe encuentra sustento en un contrato real y no en una mera apariencia. Lo que es aparente, sin embargo, es la voluntad del dueño que, en verdad, no ha consentido, con lo que se da la hipótesis de una venta y tradición de cosa ajena. El contrato translaticio no refleja la intención del dueño de la cosa de transferir el dominio, intención que tampoco se encuentra en la tradición, por lo que cabría concluir que la tradición efectuada en mérito de tal contrato no es apta para transferir el dominio ni para adquirir la posesión, porque falta la voluntad del dueño. Sin embargo, también en este caso el legislador cede en la rigurosidad de los principios y acepta hacer una excepción a ellos en consideración a que el contrato translaticio y la tradición que se hizo como consecuencia del mismo, a lo menos en apariencia reflejan la voluntad del dueño, toda vez que una de las partes actúa a nombre y en representación de éste. La excepción consiste en que la ley autoriza que la tradición permita adquirir posesión, manteniendo inalterable el principio de que no transfiere el dominio porque falta la voluntad del dueño. Eso sí que como el título no es justo, la posesión que se adquiere no es más que irregular.

iii. Título que adolece de un vicio de nulidad.

Sabido es que la nulidad, tanto absoluta como relativa, declarada por sentencia firme hace que el contrato se mire como si nunca hubiera existido, fingiendo la ley que las partes no lo celebraron, con lo cual la tradición que se efectuó en virtud del contrato debe entenderse que no transfiere el dominio ni permite adquirir la posesión, pues para ello le falta un requisito esencial: la existencia de un título translaticio. Sin embargo, y también en consideración a una apariencia de realidad que deriva del hecho que cuando se hizo la tradición el contrato no se había anulado y que, por lo mismo, pese a la existencia del vicio de nulidad producía válidamente todos sus efectos, si se llegara a declarar la nulidad la ley entiende, no obstante, que éste existió como tal, pero para el exclusivo objeto de justificar que la tradición que se hizo permite adquirir la posesión, aunque

posesión irregular porque deriva del título injusto. Lo que hemos dicho surge del supuesto que el contrato translaticio hubiera sido declarado nulo. Lo mismo ocurre si el vicio de nulidad se advierte, no en el contrato translaticio, sino que en la tradición, y ésta es declarada nula. La nulidad de la tradición hace que ésta se mire como si nunca hubiera existido, por lo que mal pudo transferirle dominio o permitir la adquisición de la posesión. Sin embargo, y por la misma razón que mencionábamos antes, la ley hace una excepción a los principios generales en materia de nulidad y considera que la tradición declarada nula existió para el sólo efecto de constituir posesión irregular en el adquirente. La verdad es que, sólo si se declara la nulidad, sea del contrato translaticio o de la nulidad misma, se va a entender que el título no era justo y que la tradición sólo permitió adquirir la posesión irregular.

iv. Título meramente putativo.

La posesión se funda en un título meramente putativo cuando el hecho jurídico que sirve de fundamento a la posesión no existe como tal y lo que hay como título posesorio es un modo de adquirir aparente, es decir, que se presenta en el hecho y puede ser percibido como modo de adquirir, aunque en verdad no tenga existencia jurídica. Respecto al ejemplo del heredero putativo que señala el artículo 704 del CC, no se está significando que la persona en quien concurre, a lo menos, la apariencia de heredero tiene que estar de buena fe, en el sentido de que debe creer que tiene la calidad de heredero testamentario o abintestato del causante. Pensamos que también el heredero putativo puede estar de mala fe, es decir, saber que existen otras personas de mejor derecho para la sucesión intestada del difunto o que el testamento en que se le instituyó heredero se encuentra revocado. Lo que importa es que se den en la práctica los hechos o circunstancias que pueden crear justificadamente la apariencia de heredero. Las circunstancias que concluye mencionando el artículo 704 del CC confirman nuestra interpretación en el sentido que el heredero o legatario putativos para que puedan invocar como título posesorio la sucesión por causa de muerte deben fundar la calidad de heredero o legatario en algo más que en sus meros dichos. Es importante distinguir si el heredero putativo posee con justo título o no, en lo que guarda relación con la acción de petición de herencia, que es la que puede entablar el verdadero heredero en contra del que, sin serlo, ocupa la herencia atribuyéndose tal calidad. Si el heredero putativo carece de justo título, tendrá que poseer por diez años para adquirir por prescripción adquisitiva el derecho real de herencia y en cualquier momento, antes que se cumpla dicho plazo, podrá verse obligado a restituir las cosas hereditaria si el verdadero heredero ejerce en su contra la acción de petición de herencia. En cambio, si el heredero putativo posee con justo título y buena fe puede adquirir el derecho real de herencia por prescripción de cinco años, lo que significa que la acción de petición de herencia se extingue si no se ejerce dentro de tal plazo, conforme lo señalado en el artículo 1269 del CC. Con el legatario putativo ocurre algo similar.

b) Buena Fe.

La posesión regular supone justo título y buena fe, la que define el artículo 706 del CC en materia posesoria como. *“La conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa promedios legítimos,*

exentos de fraude y de todo otro vicio. Así en los títulos translativos e dominio la buena fe supone la persuasión de haberse recibido la cosa de quien tenía la facultad de enajenarla, y de no haber habido fraude ni otro vicio en el acto o contrato. Un justo error en materia de derecho no se opone a la buena fe. Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario”.

Concordando los artículos 706 y 702 del CC surgen los siguientes comentarios:

El CC da un concepto muy claro de buena fe en materia posesoria. Nótese que no es la conciencia de haber adquirido la posesión por medios legítimos, sino que el dominio, lo que necesariamente implica que tiene que haber concurrido un modo de adquirir el dominio y corrobora que sólo los modos de adquirir el dominio pueden constituir un título posesorio. El concepto de buena fe del artículo 706 se aplica a todos los modos de adquirir el dominio, sin perjuicio de que para uno de ellos, la tradición, la ley agrega un requisito especial para el adquirente que se encuentre de buena fe: la persuasión de haberse recibido la cosa e quién tenía la facultad de enajenarla, es decir, la convicción de que el tradente es dueño de la cosa y, además, la persuasión de que el contrato translativo que sirve de antecedente a la tradición carece de fraude o de otro vicio.

La ley se pone en el caso de que la conciencia en cualquier modo de adquirir o la persuasión en la tradición con el alcance que se ha señalado para una y otra, que supone un proceso de reflexión y convicción interno, se haya logrado errónea o equivocadamente. El inciso final del artículo 706 del CC es terminante y categórico en señalar que el error de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario, con lo que descarta la buena fe de quien adquirió la conciencia o persuasión a que el artículo se refiere como consecuencia de un error de derecho, lo que es concordante con el artículo 8 del CC. En el inciso tercero del artículo 706 del CC se establece que un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe, lo que significa que quien adquiere la conciencia o persuasión que el artículo menciona por error de hecho, podrá, no obstante el error, ser considerado como poseedor de buena fe si aquel es justo. Un error justo es aquel que razonablemente se puede justificar por las circunstancias de hecho del caso concreto. Es decir, las circunstancias propias y precisas de un caso particular pueden llevar a calificar el error como justo. Ejemplo de error de derecho sería la persona que adquiere por tradición una cosa de una persona que la ha robado, con la creencia que no existe impedimento por el hecho de ser robada la cosa. Ejemplo de error de hecho sería la persona adquiere una cosa que es robada en un establecimiento comercial respetable.

Otro principio importante que hay que tener en consideración es que la buena fe que permite calificar la posesión de regular, debe existir al momento en que se adquiere la posesión, aunque con posterioridad la buena fe se pierda.

3.3 Posesión Viciosa y No Viciosa.

El artículo 709 del CC dispone: **“Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina”**. La palabra viciosa significa defectuosa o de mala calidad. Posesión viciosa es entonces la que adolece de dos defectos que la ley considera graves: a violencia y la clandestinidad.

Los artículos 710 a 712 del CC se refieren a vicio de violencia. De ellos se desprende que posesión violenta es la que presenta las siguientes características:

- i. **Es la que se adquiere por la fuerza, ya sea actual o inminente.** La fuerza es actual cuando alguien se apodera de la cosa arrebatándola al que la tiene en su poder, utilizando para ello medios compulsivos, que suponen procedimientos violentos o brutales. La fuerza es inminente cuando alguien se apodera de una cosa amenazando a quien la tiene en su poder con un mal o daño susceptible de producirle temor. De lo dicho se desprende que la diferencia entre la fuerza actual y la inminente es que el despojo es consecuencia, en la primera, de la violencia; en la segunda, de la amenaza. Con ello se aprecia que la fuerza como vicio de la posesión es similar a la fuerza como vicio del consentimiento. La analogía entre ambos conceptos permite aplicar a la fuerza en materia posesoria algunos principios que contempla la ley cuando reglamenta la fuerza como vicio del consentimiento: la fuerza como vicio de la posesión debe ser grave, injusta o ilícita y determinante. Cabe tener en consideración que también es poseedor violento el que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño le repele, conforme al artículo 711 del CC.
- ii. Para la ley indiferente que la fuerza se ejerza en contra del verdadero dueño, del poseedor no dueño o del que tiene la cosa como mero tenedor. También es indiferente que la fuerza se ejerza personalmente por el que se apodera de la cosa o por sus agentes, y que éstos actúen con o sin el consentimiento o ratificación expresa o tácita de aquel, conforme al artículo 712 del CC.

El artículo 713 del CC se refiere al vicio de clandestinidad, diciendo que la posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Para calificar la posesión **de violenta y de clandestina**, la ley atiende a momentos en el tiempo distintos: el de la adquisición de la posesión, en la violenta; y el de ejercicio de actos posesorios, en la clandestina. En consecuencia, el vicio de violencia es permanente, en el sentido que contamina, por así decirlo, la posesión para siempre. Poseedor clandestino, en cambio, es el que ejerce la posesión ocultándola a los que tiene derecho a oponerse a ella. Cuando ejerza actos posesorios en estas circunstancias será poseedor clandestino y no necesariamente por todo el tiempo de posesión. Deja de ser poseedor clandestino cuando ejerce la posesión sin ocultarla a quienes tiene derecho a oponerse a ella, de lo que se desprende que el vicio de clandestinidad es temporal pues puede desaparecer.

Surge en doctrina la pregunta acerca de si el poseedor vicioso debe considerarse siempre como un poseedor irregular. Sobre el particular hay que tener presente que el poseedor violento será siempre un poseedor irregular, pues para calificar la posesión de violenta se atiende al momento de su adquisición. En cambio, el poseedor clandestino no necesariamente tiene posesión irregular de la cosa, si la adquirió con justo título y con buena fe. Es posible, en consecuencia, que un poseedor regular sea, al mismo tiempo, poseedor clandestino, ésta última calidad desde el momento que ejerza la posesión ocultándola de quien tiene derecho a oponerse a ella, y mientras ejerza actos posesorios con el vicio de clandestinidad. El efecto que la ley expresamente considera como consecuencia de las posesiones viciosas es que privan al poseedor de la posibilidad de entablar acciones posesoria, entendiéndose por tales las que tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de los bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos conforme al artículo 916 del CC. Ello porque de acuerdo al artículo 918 del CC sólo puede instaurar acciones posesorias el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo, concordando la doctrina nacional en que no tiene posesión tranquila el poseedor violento o el clandestino.

También se discute doctrinariamente acerca de si las posesiones viciosas habilitan para adquirir el dominio por prescripción. La doctrina nacional en forma prácticamente unánime responde afirmativamente a esta pregunta, basada en el principio de que toda posesión es útil y aunque tenga vicios de violencia o clandestinidad habilita para prescribir, ya que ninguna disposición del CC limita la prescripción exclusivamente para las posesiones sin vicios y, por el contrario, la permite inclusive para la posesión de menor calidad, que es la irregular, dentro de la cual cabe incorporar a las posesiones viciosas. Discrepa el profesor Rodríguez, quien sostiene que el concepto de la posesión inútil está recogido en el CC, que requiere para la prescripción no sólo la posesión y el transcurso del tiempo, sino que también los demás requisitos legales, uno de los cuales es, precisamente, la falta de vicios de la posesión, pareciéndole jurídicamente absurdo que puedan acogerse a la prescripción posesiones que no justifican ni merecen protección jurídica, más aún porque tal idea es contraria al espíritu y a la letra de la ley. Compartimos la idea planteada de que no toda posesión habilita para prescribir, pero la fundamentamos de manera diversa. Las posesiones inútiles son, en nuestro criterio, las que no van aparejadas del ejercicio de actos posesorios. El ejercicio de actos posesorios por parte del prescribiente, los cuales se exigen con un doble carácter: por una parte, constituyen la exteriorización del ánimo de señor y dueño y la expresión por signos externos y claramente perceptibles de la intención de dueño o de llegar a ser dueño; y, por la otra, constituyen la manera a través de la cual el dueño o la persona que tiene derecho a oponerse a la posesión pueda advertir o darse cuenta que otra tiene la cosa con ánimo de dueño, pudiendo como consecuencia de dicha percepción adoptar las vías legales para recuperar la posesión perdida y evitar la pérdida de dominio que supone su adquisición por el prescribiente. Creemos que la posesión clandestina no puede llevar a prescribir porque, precisamente el ocultamiento de la posesión es que impide al dueño revertir la situación

ejerciendo las acciones legales que le competen. Falta, en consecuencia, uno de los requisitos de la prescripción, el ejercicio de actos posesorios que sean visibles o manifiestos para el dueño o para quien tenga derecho a oponerse a ellos. En cambio, no vemos que estas consideraciones sean valederas para estimar inútil la posesión violenta. En efecto, si el poseedor que adquirió la posesión con violencia ejerce, no obstante, actos posesorios, sin ocultarlos a quien puede oponerse a la posesión, en términos tales que ésta posesión pública o visible para cualquiera persona pueda ser atacada por el dueño, no faltaría el requisito que respecto del ejercicio de actos posesorios supone toda prescripción. Sin embargo, con el razonamiento que el poseedor violento no tiene, en verdad, un título posesorio para fundamentar la posesión, ya que el antecedente de la posesión es la violencia, que no constituye un medio legítimo para adquirirle dominio que supone el título justo ni tampoco la apariencia de legitimidad que debe tener un título injusto, no cabe sino concluir que no tiene jurídicamente la calidad de poseedor, y que sólo la tiene en el hecho, sin título que la justifique. En estricto derecho, el así llamado poseedor violento no es más que un mero detentador de la cosa, que la ley no puede considerar poseedor ni digno de acogerse a las ventajas o beneficios de la posesión.

Tema 4: La Posesión es un Hecho Personal.

El artículo 717 del CC dispone: *“Sea que suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la sucesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores”*.

El artículo 718 del CC complementa el anterior, regulando la situación de los comuneros, luego de la partición en que se adjudica, a uno o más de ellos, una o más cosas que se poseían en común, al disponer: *“Cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindiviso, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión. Podrá pues añadir este tiempo al de su posesión exclusiva, y las enajenaciones que haya hecho por sí solo de la cosa común y los derechos reales con que la haya gravado, subsistirán sobre dicha parte si hubiere sido comprendida en la enajenación o gravamen. Pero si lo enajenado o gravado se extendiere a más, no subsistirá la enajenación o gravamen contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios”*.

Tema 5: Presunciones en Materia Posesoria.

La ley establece diversas presunciones. Hemos mencionado dos: **La presunción de dominio** del inciso final del artículo 700 del CC que señala: *“El poseedor será reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo”* y la **presunción de la tradición** que establece el inciso final del artículo

702 del CC que dispone: “La posesión de la cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, a menos que la tradición haya debido efectuarse por la inscripción del título”.

Corresponde agregar las siguientes que establece el artículo 719 del CC:

- i. Si una persona toma la posesión de una cosa a nombre propio, se presume que dicha posesión a nombre propio ha continuado hasta el momento que se alega.
- ii. Si una persona toma la posesión de una cosa a nombre ajeno, se presume la continuación del mismo estado de cosas.
- iii. Si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio.

Estas presunciones, que resultan de la simple constatación de lo que es normal y corriente, liberan a la persona en cuyo beneficio operan del peso o carga de la prueba.

Tema 6: Posesión que se Toma a Nombre Ajeno.

El artículo 720 del CC señala: “La posesión puede tomarse no sólo por el que trata de adquirirla para sí, sino por sus mandatarios o por sus representantes legales”. La ley no hace más que aplicar el principio general de que los actos jurídicos pueden celebrarse personalmente o por medio de representante legal o voluntario, calidad ésta última que pretende tener el mandatario siempre que actúe a nombre del mandante.

Los efectos que se producen cuando una persona toma la posesión de una cosa, no para sí sino para otra a nombre de la cual actúa, son los siguientes:

- i. En el caso de que tome la posesión a nombre de otro la persona que tiene poder de representación como representante legal o voluntario, la posesión del representado principia en ese mismo acto, aún sin su conocimiento, de acuerdo a lo señalado en el primer inciso del artículo 721 del CC.
- ii. En el caso de que tome la posesión a nombre de otro quien no tiene poder para representarlo, para que la persona a nombre de la cual se actuó adquiriera la posesión, ésta debe ratificar, es decir, aceptar la gestión que efectuó a nombre de él quien no tenía el poder para representarlo. La ratificación opera con efecto retroactivo y se entiende que adquirió la posesión desde el momento que fue tomada a nombre del que ratifica, conforme al segundo inciso del artículo 721 del CC.

Tema 7: Diferente tratamiento legislativo para la adquisición y pérdida de la posesión de los bienes inmuebles con respecto a los inmuebles. Su fundamento.

El legislador constituyó en el país el comúnmente llamado sistema de la propiedad registral o de la propiedad inscrita, similar al que existía en la época en algunos estados alemanes. Según el Mensaje del CC dicho sistema consiste en que la tradición del dominio de bienes raíces y de los demás derechos reales constituidos en ellos, menos los de servidumbre, deberá hacerse por inscripción en un registro semejante al que ahora existe de hipotecas y censos que se refundirá en él. Se trata, en efecto, de una nueva fusión del régimen hipotecario asociando dos objetos que tiene entre sí un enlace íntimo, o que por mejor decir, se incluyen uno en otro: dar una completa publicidad a las hipotecas, y poner en vista de todos el estado de las fortunas que consisten en posesiones territoriales. La transferencia y transmisión del dominio, la constitución de todo derecho real, exceptuadas, como se ha dicho, las servidumbres, exige una tradición; y la única forma de tradición para esos actos corresponde es la inscripción en el registro conservatorio. No dando a la inscripción conservatoria otro carácter que el de una simple tradición, la posesión conferida por ella deja subsistentes los derechos del verdadero propietario, que solamente podrían extinguirse por la prescripción competente.

Por el momento nos limitaremos a consignar algunos principios o ideas matrices que fluyen del Mensaje del CC:

- i. El sistema de inscripción en el CBR, que se efectúa en registros públicos y abiertos a todo el que quiera imponerse de ellos, permite, por una parte, dar completa publicidad a las hipotecas y a los demás gravámenes que se constituyen sobre bienes raíces y, por la otra, poner a la vista de todos las fortunas que consisten en posesiones territoriales.
- ii. Para lograr lo anterior una posibilidad, que se desechó, era obligar a todos los titulares de un derecho real sobre inmuebles a efectuar la inscripción de su derecho dentro de cierto plazo. Dicha posibilidad se desechó porque el legislador temió que la comprobación del derecho fuera fuente de juicios y litigioso ante los Tribunales de Justicia y creara un problema social importante.
- iii. Se optó por otra alternativa, que consiste en hacer obligatoria la inscripción para las transferencias del dominio o constitución de derechos reales sobre inmuebles, e inclusive para las transmisiones del dominio por causa de muerte cuando en la herencia se comprenden inmuebles, verificadas con posterioridad a la fecha en que la ley entró en vigencia. De esta regla sólo se exceptúa la constitución del derecho de servidumbre.
- iv. El legislador estimó que en un tiempo razonable todos los inmuebles se encontrarían inscritos, porque es normal que su propietario lo enajene, inscripción de la tradición, o, por último, aunque no lo enajene, un hecho cierto y que tiene que ocurrir es la muerte del dueño, que hace exigible también la inscripción.

Tema 8: Adquisición y pérdida de la posesión de las cosas corporales muebles.

8.1 Adquisición de la posesión.

Para adquirir la posesión de las cosas corporales muebles deben concurrir los elementos de la posesión: **corpus y animus**. Y ello necesariamente supone la existencia de un título posesorio, que son los únicos que permiten presumir el ánimo de señor y dueño. Todos los títulos posesorios, que como se ha dicho son los modos de adquirir el dominio con la salvedad estudiada de la prescripción, hacen posible la tenencia de la cosa, el corpus, y el ánimo de señor y dueño, el animus, que la ley presume.

Cabe advertir que en esta materia el CC consagra una excepción a las reglas generales en materia de capacidad, pues el primer inciso del artículo 723 del CC dispone: *“Los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal, pero no pueden ejercer los derechos de poseedores, sino con la autorización que compete. Los dementes y los infantes son incapaces para adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos o para otros”*. Como se aprecia, el inciso final contempla una contraexcepción.

Adquirida la posesión, ésta se mantiene mientras subsisten los elementos que la constituyen, esto es, el corpus y el animus. Sin embargo, el artículo 725 del CC dispone: *“El poseedor conserva la posesión, aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o a cualquier otro título no translativo de dominio”*. El que tiene la cosa en virtud de un título de mera tenencia, lo hace en lugar o a nombre del poseedor, lo que significa que tanto el corpus como el animus siguen radicados en éste. El artículo 727 del CC confirma lo anterior al señalar: *“La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero”*.

8.2 Pérdida de la posesión.

Si la posesión supone el corpus y el animus como elementos esenciales, es lógico que se pierda la posesión de las cosas muebles cuando desaparecen conjuntamente ambos elementos, lo que ocurre, por ejemplo, cuando el poseedor enajena la cosa a un tercero o cuando la abandona para que la haga suya el primer ocupante. Se pierde también la posesión de las cosas muebles cuando otro se apodera de la cosa con ánimo de hacerla suya, conforme al artículo 726 del CC. En este caso, la sola pérdida del corpus, la cosa debe estar bajo el poder del poseedor, acarrea la pérdida de la posesión, aunque subsista el ánimo de señor y dueño de éste. Más difícil de imaginar es la pérdida de la posesión por la sola desaparición del animus, manteniendo el corpus. Se cita como ejemplo la enajenación que hace el poseedor de la cosa a un tercero, conservándola por un título

de mera tenencia, operando la tradición ficta. Sin embargo el ejemplo no parece acertado porque en dicho caso se transfirió el corpus y el animus. El hecho de que retenga la cosa en su poder no significa que lo haga a título de poseedor, porque la tiene a nombre y en lugar de la persona a quien la enajenó.

Tema 9: Adquisición y pérdida de la posesión de los bienes raíces.

9.1 Adquisición de la posesión.

Para ver como se adquiere la posesión de los inmuebles, lo primero que hay que analizar es el título posesorio, siendo del caso mencionar que por regla general los mismos títulos que fundamentan o justifican la adquisición de la posesión de los bienes muebles pueden invocarse para adquirir la posesión de los bienes raíces. El título posesorio tiene que ser, en consecuencia, uno de los modos de adquirir el dominio que establece la ley. A continuación se verá cómo opera cada uno de los títulos posesorios que permiten adquirir la posesión de los inmuebles:

9.1.1 El título ocupación o apoderamiento.

Supone que una persona se apropia o adueña de un inmueble.

Sabido es que no se puede adquirir por ocupación el dominio de los bienes inmuebles porque requisito para que opere la ocupación como modo de adquirir no es sólo el acto material del apoderamiento, sino que también que la cosa no pertenezca a otra persona, y ocurre que en nuestro país todos los inmuebles tienen dueño y que éste, en último término y a falta de un titular conocido, el Fisco.



En consecuencia, la persona que se apropia de un inmueble jamás va a adquirir el dominio por ocupación. Pero el apoderamiento que no justifica la adquisición del dominio porque todos los inmuebles tienen dueño, permite, no obstante, adquirir la posesión de cierto tipo de bienes raíces: los inmuebles no inscritos, como se desprende del artículo 729 del CC que dispone: *“Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde”*. Creemos, sin embargo, que en estricto rigor el apoderamiento violento no debería permitir la posesión jurídica de la cosa, en este caso el inmueble no inscrito, porque no existe en tal caso título posesorio alguno que no sea la mera violencia que, como es natural, no puede tener la calidad de título que legitime la posesión. En cambio, en el apoderamiento pacífico concurre, a lo menos, en apariencia un título posesorio, la ocupación, que si bien no es justo, sino que lo contrario, permite adquirir posesión irregular. La justificación a ello surge de considerar el propósito del legislador de promover la inscripción de los inmuebles, constituyendo la situación que hemos descrito una especie de advertencia para los

dueños o poseedores de inmuebles no inscritos y un estímulo o incentivo para que practiquen la inscripción.

No se puede invocar el título ocupación o apoderamiento para adquirir la posesión de los inmuebles inscritos, conforme al segundo inciso del artículo 728 del CC que dispone: *“Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito, no adquiere posesión de ella ni pone fin a la posesión existente”*.

En suma, el título ocupación o apoderamiento, con la salvedad del apoderamiento violento según se veía antes, puede invocarse para adquirir la posesión de inmuebles que no están inscritos, sin que la ley exija como requisito adicional para adquirir la posesión una inscripción en el Registro del CBR. La persona que deriva su posesión del apoderamiento del inmueble no inscrito, que será poseedor irregular, puede adquirir el dominio del mismo por prescripción extraordinaria siempre que ejecute sobre el inmueble actos posesorios y que su posesión no sea clandestina. Por su parte, la persona que se apodera con violencia de un inmueble que no está inscrito, si bien hace perder la posesión anterior, no adquiere jurídicamente la calidad de poseedor sino que la de poseedor de hecho o poseedor material que equivale a la de mero tenedor y no puede adquirir el dominio por prescripción. En cambio, el título apoderamiento no puede invocarse para adquirir la posesión de los inmuebles que están inscritos.

9.1.2 El título accesión.

Supone que una persona funda la posesión de una cosa inmueble porque ésta se ha juntado a otro inmueble sobre el cual tiene el dominio o posesión. Opera como tal desde que se cumplen los supuestos de hecho a los cuales la ley atribuye el carácter de accesión del suelo, sin que se requiera inscripción para adquirir la posesión. En consecuencia, es indiferente para estos efectos que el inmueble o parte del que se junta a otro esté o no inscrito, como también lo es que el inmueble al cual otro accede esté o no inscrito. El propietario o poseedor va a adquirir la posesión de la cosa por el título accesión, sin necesidad de inscripción.

9.1.3 El título prescripción.

Para fundamentar la posesión de un bien raíz es descartado por la doctrina nacional, pues se argumenta que mal puede servir la prescripción como título a una posesión que necesariamente debe haberse adquirido con anterioridad a que la prescripción opere. Puede servir como título posesorio para fundamentar la posesión que se mantiene sobre el inmueble con posterioridad a la fecha en que se cumplió el plazo legal para que aquella opere, sin que tampoco en este caso se requiera inscripción alguna.

9.1.4 El título sucesión por causa de muerte.

Supone que una persona fundamenta la posesión de un bien raíz, inscrito o no, **en la calidad de heredero**. Como se ha mencionado antes, no se requiere ninguna inscripción para adquirir la posesión de los inmuebles invocándose el título sucesión por causa de muerte. Las inscripciones prevenidas por el artículo 688 del CC lo son para el solo efecto de que los herederos puedan disponer de los inmuebles hereditarios.

9.1.5 El título tradición.

Supone que una persona fundamenta la posesión de un inmueble porque otra se lo ha enajenado. Dicho título, a contar desde la fecha en que entraron en vigencia las disposiciones del CC que establece que la tradición del dominio y de los otros derechos reales sobre inmuebles, con la sola excepción de las servidumbres, debe hacerse por la inscripción en el Registro del CBR, puede invocarse para adquirir la posesión de los inmueble que se encuentran o no inscritos, pero siempre que la tradición se haya inscrito en el Registro del CBR. Si falta la inscripción, la entrega material que pudiera haber efectuado el obligado según el contrato translativo a la tradición, no habilita para adquirir posesión regular ni irregular. La persona que tiene materialmente la cosa en su poder no es jurídicamente un poseedor, porque el título que invoca para justificar la posesión, la tradición, no existe por faltar un elemento esencial de ésta, la inscripción. Sin inscripción, en consecuencia, no hay tradición y sin tradición no hay título posesorio. Esta interpretación encuentra apoyo en el artículo 724 del CC que señala: “Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el Registro del CBR, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio”.

Cabe, sin embargo, hacer presente que el criterio que hemos señalado no es compartido por parte de la doctrina y que tampoco ha sido acogido siempre por la jurisprudencia. Fabres inicia la discusión al decir que el artículo 724 del CC sólo puede referirse a la posesión regular, porque sólo en ella se requiere esencialmente la tradición: la posesión irregular, la violenta y la clandestina no necesitan de la tradición o bien pueden existir sin la inscripción en el Registro del CBR como se deduce de los artículos 702, 708, 729 y 730 del CC. Se ha sostenido que cuando se invoca el título tradición para adquirir la posesión de los bienes raíces, estén o no inscritos, no es indispensable la inscripción. Si ésta falta la entrega material de la cosa que se hubiera hecho al adquirente hace nacer en éste posesión, pero irregular. Algunos estiman que el artículo 724 del CC se aplica sólo a los inmuebles inscritos, de manera que si se enajena un inmueble inscrito y no se hace la inscripción de la tradición, el adquirente, aunque tenga la cosa en su poder, no adquiere posesión de ninguna clase. En cambio, si se enajena un inmueble no inscrito y no se practica la inscripción, ello no obsta para que se adquiera posesión irregular, en atención a que falta el requisito

inscripción que supone la posesión regular, pues el hecho que el artículo 729 del CC permita que se adquiera la posesión de un inmueble no inscrito por el apoderamiento, aún violento o clandestino, hace suponer que con mayor razón todavía puede adquirirse la posesión irregular de estos inmuebles si falta la inscripción que requiere su enajenación.

Como decíamos antes, creemos que el título tradición para adquirir la posesión de bienes raíces inscritos o no inscritos, sólo es posible si la tradición existe como tal, es decir, si se ha practicado la inscripción, de manera que sin inscripción no es que no se pueda adquirir la posesión regular sino que sólo irregular porque falta un requisito de la posesión regular, sino que no se puede adquirir posesión porque falta un requisito esencial de ésta. Ello teniendo presente lo siguiente:

- i. Hay disposiciones del CC que se refieren específicamente a los inmuebles inscritos y otras que se aplican exclusivamente a los que no están inscritos. Sin embargo, el artículo 724 del CC no distingue entre inmuebles inscritos o no inscritos, sino que por el contrario, establece una regla imperativa que se aplica indistintamente a una u otra clase de inmuebles. Donde el legislador no distingue no es lícito al intérprete hacerlo.
- ii. Conviene recordar que lo primero que hay que hacer para interpretar la ley es apreciar si el sentido que emana del tenor literal de la norma es o no claro; y es sumamente claro que el artículo 724 del CC no distingue entre los inmuebles inscritos y no inscritos.
- iii. El Mensaje del ejecutivo proponiendo la aprobación del CC, que como hemos dicho antes constituye el elemento más valioso para determinar la intención o espíritu de la ley en esta materia, no da la razón.
- iv. Por otra parte, el argumento sobre la base de que si se puede adquirir posesión de un inmueble no inscrito por el solo apoderamiento aun violento, con mayor razón todavía se podrá adquirir la posesión de estos inmuebles si sólo falta la inscripción del título en el Registro del CBR, que surge del principio de interpretación de que quien puede lo más puede lo menos, no se condice tampoco ni con la letra ni con el espíritu de la ley. Si el legislador permite que se pierda la posesión de un inmueble no inscrito por el apoderamiento, lo hace como una sanción implícita al que tiene un inmueble no inscrito y que consiste en que deja la posesión a merced de los actos de apoderamiento, persiguiendo con ello el claro objetivo de promover la inscripción.

9.2 Pérdida de la posesión de los bienes raíces.

La posesión que tiene una persona sobre un bien raíz se pierde como consecuencia de que otra la adquiera por alguno de los títulos posesorios mencionados anteriormente. Sin embargo, esta regla hay que aplicarla con ciertos matices, derivada del hecho que la posesión de los inmuebles no inscritos se pierde por el apoderamiento que hace de los mismos otra persona, lo que no ocurre con la posesión de los inmuebles inscritos, que está a salvo de tal riesgo de acuerdo al segundo inciso del artículo 728 del CC. Por otra parte, tratándose de la posesión de los inmuebles inscritos

rige una regla especial contenida en el primer inciso del artículo 728 del CC que establece: *“Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por la voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial”*.

Posesión inscrita es la que tiene la persona a cuyo nombre figura una inscripción en el Registro del CBR. Esta sola circunstancia no comprueba que el titular de la inscripción sea dueño del inmueble o del derecho real de que se trata, sino que significa, en concepto de la ley, que tiene la posesión de la cosa, llegando la ley a presumir que se dan en la posesión inscrita los elementos comunes de toda posesión, corpus y animus, aunque en verdad el titular haya perdido el corpus o el animus, respectivamente. Interesará de sobremanera, por lo tanto, a quien pretende haber adquirido la posesión de un inmueble inscrito que se cancele o deje sin efecto la inscripción anterior, pues mientras ésta subsista se mantiene la presunción de que el titular de la inscripción, la persona a cuyo nombre está inscrito el dominio o el derecho real de que se trata, es el actual poseedor.

Sólo los hechos jurídicos que la ley determina como idóneos en el artículo 728 del CC pueden producir la cancelación de la inscripción:

9.2.1 La voluntad de las partes.

Supone no la manifestación unilateral de voluntad de una de las partes, sino que el acuerdo de voluntades de las partes con el propósito de dejar sin efecto una inscripción vigente a nombre de una de ellas. Ello ocurre tratándose de la resciliación de un contrato translativo en mérito del cual se efectuó una inscripción que se quiere cancelar. Creemos que también se produciría la cancelación de la inscripción por voluntad de las partes en el caso de que en un contrato de transacción el poseedor inscrito de un inmueble reconoce que el dominio no le corresponde a él sino que a la otra parte.

9.2.2 La nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro.

Es importante advertir que como lo señala el artículo 728 del CC, la nueva inscripción que cancela la anterior es aquella en que el poseedor inscrito transfiere su derecho, lo que revela que la inscripción por medio de la cual se hace la tradición debe tener, necesariamente, una relación o vinculación directa con la persona a nombre de la cual se encontraba inscrito el derecho que se transfiere.

En caso de que alguien suplante al dueño y la transfiera, la solución no es fácil. Si se considera que lo cancela la anterior, existirían dos inscripciones paralelas, una ineficaz, la de la enajenación, que no otorgó la posesión al adquirente; y, otra eficaz, la que existía a nombre del poseedor inscrito que subsiste y en cuya virtud el titular conserva la posesión. De acuerdo con esta postura, la nueva

inscripción, para que cancele la anterior, debe provenir realmente del poseedor inscrito, lo que supone que éste intervino en verdad en el acto de enajenación, sea porque actuó por sí mismo, personalmente, o porque lo hizo otra persona a nombre de él, pero que tenía poder para representarlo. Esta interpretación presenta, sin embargo, un problema: descarta que pueda cancelarse una inscripción por una nueva que se practica en virtud de un título injusto, como sería el falsificado o el otorgado por una persona en calidad de mandatario o representante legal sin serlo. Y el artículo 728 del CC no dice que sólo cancela la inscripción la nueva que se practica en virtud de un título justo. Si bien el tema es discutible, y existen sentencias en apoyo de ambas tesis, se ha uniformado la opinión de que la nueva inscripción que requiere el artículo 728 del CC para cancelar la primitiva debe provenir realmente o, a lo menos, aparentemente del poseedor inscrito y que la apariencia en este último caso debe manifestarse en el título que se lleva al CBR para inscribir.

9.2.3 El decreto judicial.

La cancelación de la inscripción procede como consecuencia de una sentencia judicial. Por ejemplo, si en un juicio reivindicatorio se condena al poseedor de un inmueble a restituirlo a su dueño, el juez puede decretar que se cancele la inscripción que se había practicado a nombre del poseedor vencido.

De lo expuesto y, a modo de síntesis, es **posible extraer algunas conclusiones**:

La posesión inscrita a que se refiere el artículo 728 del CC es aquella que la ley presume en la persona que tiene una inscripción a su nombre, presumiendo la ley, asimismo, que mientras subsista la inscripción, es decir, mientras no se cancele, el titular de ésta conserva la posesión. Sin embargo, es posible que, no obstante existir una inscripción a nombre de una persona, sin que ésta la hubiera cancelado, el titular de la misma haya perdido la posesión y que otra persona la haya adquirido, lo que puede ocurrir en las siguientes situaciones:

- i. Cuando una persona distinta del poseedor inscrito adquiere la posesión del inmueble a que se refiere la inscripción o de parte de éste por el título posesorio accesión.
- ii. Cuando una persona adquiere la posesión del inmueble a que se refiere la inscripción por el título posesorio sucesión por causa de muerte. La muerte del causante pone término a la posesión que éste tenía sobre el inmueble, no obstante que la inscripción a nombre de éste no se hubiera cancelado. La inscripción subsiste, pero una persona distinta del titular de la inscripción posee el inmueble.

La otra conclusión importante es que la nueva inscripción que cancela la anterior tiene que emanar, a lo menos en apariencia, del poseedor inscrito que figura como tal en ésta última. Sin embargo, este principio que emana del artículo 728 del CC tiene una excepción prevista en el

artículo 730 del CC que dispone: “Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa. En este caso la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa y pone fin a la posesión anterior. Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito, se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra sin la competente inscripción”. Este artículo ha sido objeto de innumerables problemas doctrinarios. Una interpretación sobre el tenor literal lleva a inferir que el inciso segundo se aplica exclusivamente a los inmuebles inscritos, deduciéndose que el inciso primero que se limita a hablar de cosa, se aplica tanto a los muebles como a los inmuebles, pero en este último caso, sólo a los inscritos. Algunos sostienen que si el mero tenedor enajena a nombre propio el inmueble que no está inscrito, aunque no se practique ninguna inscripción, la persona que lo recibió como consecuencia, por ejemplo, de la venta y entrega material, adquiere posesión, y que si enajena, en cambio, un inmueble inscrito, la persona a quien lo enajena adquiere posesión sólo si se hubiere practicado la competente inscripción. Nosotros pensamos que en ningún caso puede interpretarse el artículo en análisis como una excepción al principio que toda enajenación de inmuebles, inscritos o no inscritos, debe hacerse por la inscripción en el Registro del CBR, por lo que no puede haber tradición sin inscripción, como tampoco al principio que si el título es tradición nadie puede adquirir posesión sin la inscripción. El sólo contrato translaticio, como lo hemos dicho tantas veces, aunque vaya acompañado de la entrega material, no es enajenación, sino que se requiere la competente inscripción. Para algunos sólo será competente la inscripción que de alguna manera y aunque sea en forma aparente se relacione con la anterior, pues sólo ella tendrá la aptitud para cancelar ésta. Para otros la competente inscripción no puede ser otra que la que se efectúa con las solemnidades legales por el funcionario competente en el CBR, por lo cual, la inscripción formalmente adecuada a la ley cancela la anterior a pesar de que aparece desvinculada por completo del poseedor inscrito a nombre del cual figura la inscripción que se cancela. La falta de uno cualquiera de los requisitos que hemos mencionado impide considerar competente a la inscripción que se pudiera realizar, con lo cual, y no obstante se practique la inscripción, ésta no produce el efecto de cancelar la anterior, de modo tal que no se pierde, por una parte, posesión, ni se adquiere por la otra.

Tema 10: Recuperación de la posesión de bienes muebles o inmuebles.

La persona que ha perdido la posesión de una cosa, no por un acto voluntario, sino como consecuencia del acto de un tercero que permite a éste adquirir la posesión de la cosa, podrá ejercer las acciones que la ley franquea para recuperar la posesión perdida, las que suponen, como principio general, que quien ha perdido la posesión de la cosa tenga mejor derecho para poseer que aquel que lo ha privado de la posesión. Debe, en consecuencia, recurrir a los Tribunales de Justicia y entablar con tal objeto la acción que corresponda. Si como consecuencia de lo anterior recupera legalmente la posesión, la ley finge en beneficio del poseedor que no fue privado de la posesión, y que ésta la ha mantenido durante todo el tiempo que duró la privación,

conforme lo dispuesto en el artículo 731 del CC que dispone: **“El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio”.**

Tema 11: Prueba de la posesión.

La prueba de la posesión es una materia importante, lo que revela desde ya el hecho de que la persona que prueba tener la posesión de la cosa es reputado dueño por la ley.

11.1 Prueba de la posesión sobre una cosa mueble.

Deberá acreditar que concurren en su caso los dos elementos o requisitos esenciales de la posesión: el corpus y el animus. Para probar el corpus se debe acreditar la existencia de un hecho: la tenencia de la cosa mueble. Para probar el animus el poseedor debe acreditar un hecho diferente: la existencia de un título posesorio que justifique la tenencia de la cosa como poseedor. No necesita el poseedor comprobar el animus o la intención de señor y dueño sino que sólo el título posesorio ya que la ley presume que quien tiene la cosa en su poder por un título posesorio lo hace con el ánimo de señor y dueño. Tampoco se requiere para comprobar exclusivamente la calidad de poseedor de una cosa mueble que se hayan ejercido actos posesorios sobre la misma. Ello será indispensable, sin embargo, cuando la posesión que se pretende demostrar es con el objeto de adquirir el dominio por prescripción. También es indispensable la prueba de actos posesorios en el caso del poseedor regular que entabla una acción publiciana en contra del que lo despojó de la posesión. Por último, creemos necesaria la prueba de actos posesorios cuando dos personas alegan derechos iguales o equivalentes para poseer una cosa, caso en el cual pensamos que debería preferirse a la que ejerció actos posesorios sobre la misma.

11.2 Prueba de la posesión de los bienes raíces.

En lo que se refiere a la posesión de los bienes inmuebles, los problemas de interpretación se producen con dos disposiciones del CC que se ocupan del tema, discrepando la doctrina nacional sobre el sentido y alcance que corresponde dar a cada una de ella. El artículo 924 del CC dispone: *“La posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla”.* Por su parte, el artículo 925 del CC señala: *“Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión”.*

Las dos interpretaciones más importantes acerca de los citados artículos son las siguientes:

- i. El artículo 924 del CC se aplica para probar la posesión de los inmuebles inscritos, en tanto que el artículo 925 del CC rige la prueba de la posesión de los inmuebles no inscritos.
- ii. El artículo 924 del CC regula la prueba de la posesión de los derechos reales inscritos, con la sola excepción del dominio, cuya prueba se rige por el artículo 925 del CC.

A nuestro juicio, para probar la posesión que se tiene sobre un bien raíz o la de derechos reales constituidos en ellos, es fundamental distinguir, previamente, dos situaciones:

- i. Si para adquirir la posesión es indispensable la inscripción.
- ii. Si para adquirir la posesión la inscripción no es un requisito esencial.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 686 y 724 del CC, sostenemos que si la posesión de un inmueble se funda en el título tradición, la inscripción es un requisito esencial para adquirir la posesión. En consecuencia, la persona que con posterioridad a la fecha en que la inscripción se hizo obligatoria pretende haber adquirido la posesión de un inmueble, esté o no inscrito, por tradición, debe probar su calidad de poseedor con la inscripción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 924 del CC. Asimismo, debe probarse por la inscripción la posesión de los derechos reales sobre inmuebles cuando ésta se fundamenta en el título tradición, con la sola excepción del derecho real de servidumbre cuya tradición, como es sabido, no requiere inscripción.

En cambio, la inscripción no es indispensable para probar la posesión de derechos reales sobre inmuebles cuando para adquirir la posesión del respectivo derecho real no se requiere inscripción, lo que ocurre en general tratándose de la posesión de bienes raíces o de derechos reales sobre éstos adquirida con anterioridad a la vigencia del CC. Y bajo la plena vigencia de éste, tampoco es indispensable la inscripción para probar la posesión del derecho real de servidumbre.

Cabe tener en cuenta, finalmente, que tampoco es indispensable la inscripción para probar la posesión de un inmueble adquirida en virtud de un título que no requiere dicha inscripción, como la accesión, la ocupación o el apoderamiento de inmuebles no inscritos, la sucesión por causa de muerte e inclusive la tradición, pero ésta última exclusivamente como título para adquirir la posesión del derecho real de herencia, aunque dentro de la universalidad existan inmuebles.

Por otra parte, el artículo 925 del CC requiere la prueba de la posesión por actos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión. Creemos que dicho artículo guarda perfecta armonía con el principio básico que sustenta a la institución de la prescripción adquisitiva: por una parte, inacción o indiferencia del dueño; y, por la otra, actos posesorios del prescribiente, entendiendo por tales los actos positivos a que se refiere el artículo 925 del CC pero con un agregado que estimamos indispensable y que constituye otro de los requisitos legales de la prescripción: ejecutados sin ocultarlos a la persona que tiene derecho a oponerse a ellos. En consecuencia, somos de opinión que no basta adquirir la

calidad de poseedor para llegar a ser dueño por prescripción, ya que esta institución exige, no sólo que se tenga la posesión de la cosa, sino que se ejecuten actos posesorios en relación con la misma. De la esencia de la prescripción es la actividad del prescribiente, que se manifiesta en el ejercicio de actos posesorios. Tanto es así que, como veremos más adelante, la prescripción se interrumpe naturalmente cuando se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios por el prescribiente, inclusive en el caso que la cosa siga en su poder y que no haya pasado a otras manos. Por lo tanto, no toda posesión es útil para prescribir. Hay posesiones inútiles y tienen esta calidad, en primer lugar, aquella en que el poseedor no ejecuta actos posesorios; y, en segundo lugar, aquella en que si bien el poseedor ejecuta actos posesorios, lo hace en forma clandestina, ocultándolos al que tiene derecho a oponerse a la prescripción.

En consecuencia, estimamos que el artículo 925 del CC debe aplicarse cuando el poseedor necesita probar la ejecución de actos posesorios, lo que será obligatorio, por ejemplo, cuando alegue la prescripción adquisitiva o cuando entable una acción publiciana. Si bien el artículo 925 del CC alude a la prueba de la posesión del suelo, lo que parece referirse a la prueba de la posesión del derecho real de dominio y no a otro derecho real inmueble, lo que se confirma incluso con los ejemplos de actos positivos que sólo podría ejecutar el dueño, creemos que el campo de aplicación de la disposición es más amplio que el que se desprende de su solo tenor literal, pues también se aplica cuando se alega la prescripción de cualquier derecho real inmueble que no sea el de dominio, por ejemplo, usufructo, uso o habitación, servidumbre, etc., caso en el cual el prescribiente tiene que probar que ha ejercido en relación con el derecho real del cual es poseedor, actos positivos de aquellos a que da derecho la calidad de titular del derecho real de que se trata.

Por último, debe señalarse que si bien el artículo 925 del CC sólo regula la prueba de la posesión de los bienes raíces, sin que exista ninguna disposición en lo relativo a la prueba de la posesión de los muebles, creemos, no obstante, que el poseedor de una cosa mueble que alega la prescripción adquisitiva debe también comprobar el ejercicio de actos posesorios, aún a falta de disposición expresa que así lo establezca porque, como se ha dicho reiteradamente, el ejercicio de actos posesorios es de la esencia de la institución de la prescripción, estableciendo el artículo 925 un principio general para su prueba, que no por estar referido expresamente a los inmuebles impide que se aplique a la prueba de la posesión de los muebles.

Tema 12: Conclusiones finales en relación con la inscripción en materia posesoria.

Cabe destacar el importante rol que cumple la inscripción en materia posesoria. Sintetizando, se dice que la inscripción es requisito, prueba y garantía de la posesión de los bienes raíces inscritos.

Efectivamente la inscripción es requisito para adquirir la posesión, y no sólo de



los inmuebles inscritos sino que también de los que no lo están, pero única y exclusivamente cuando el título en que se funda la posesión es la tradición. Los títulos posesorios distintos de la tradición no requieren inscripción alguna para hacer nacer la posesión, de lo que es posible inferir que la regla general es que no se necesita inscripción para adquirir la posesión de un inmueble inscrito o no y que la excepción constituida por la inscripción se hace efectiva solamente tratándose del título posesorio tradición.

Efectivamente la inscripción es la única manera de probar la posesión, pero sólo cuando la inscripción constituye un requisito esencial para adquirir la posesión, lo que ocurre con el título posesorio tradición. Tratándose de títulos distintos que no requieren inscripción, la posesión se puede probar de acuerdo con las reglas generales, que suponen la comprobación de los hechos que la constituyen. En consecuencia, por regla general la inscripción no es un requisito para probar la posesión de inmuebles. Por excepción, sólo es indispensable para probar la posesión de inmuebles adquiridos en virtud del título tradición.

Efectivamente la inscripción es garantía de posesión de los inmuebles inscritos, pero en el solo sentido de que el titular de la inscripción queda protegido del riesgo de perder la posesión como consecuencia del apoderamiento por parte de terceros. No tiene, por consiguiente, el alcance amplio que suponen algunos, en el sentido que el poseedor inscrito, mientras no se cancele la inscripción, no puede perder la posesión de la cosa, porque hemos visto que ello puede ocurrir cuando otra persona adquiere la posesión del inmueble por el título accesión, por ejemplo.

Tema 13: Estudio particular de los artículos 2505 y 2510 del CC.

El artículo 2505 del CC, que cabe reglamentar dentro de las disposiciones con que se reglamenta la posesión inscrita y que tiene particular relieve o importancia en relación con ésta, dispone: *“Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces o de derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo”*.

Podría sostenerse que desde el momento en que un inmueble se inscribe en el Registro del CBR queda a salvo de que otra persona distinta del titular de la inscripción adquiera el dominio u otro derecho real sobre el mismo por prescripción, a menos que la posesión del prescribiente se haya adquirido por un título, asimismo inscrito en el CBR. Dicho alcance sería plenamente válido si todos los títulos posesorios requirieran inscripción, lo que hemos visto antes que no es así. En efecto, los títulos posesorios accesión y sucesión por causa de muerte en que puede fundarse la posesión de un inmueble inscrito y que no necesitan ninguna inscripción para que se adquiera la posesión, en caso que no cumplan los requisitos legales para que el respectivo modo de adquirir permita la adquisición del dominio, posibilitan que se adquiera la posesión y consecuentemente

el dominio por prescripción, sin que tampoco requiera la ley inscripción alguna en relación con los títulos mencionados para que habiliten a prescribir. Por otra parte, inclusive el título tradición que invoca el poseedor para adquirir por prescripción, puede no estar inscrito si el objeto de la tradición era un derecho de servidumbre.

De lo anteriormente expuesto concluimos que el alcance del artículo 2505 del CC es más restringido que el que sugiere su tenor literal, y que en el fondo éste no hace más que aplicar el principio de que para adquirir la posesión de un derecho real inmueble si se invoca el título tradición es indispensable la inscripción, de modo tal que sólo la tradición inscrita permite adquirir por prescripción adquisitiva el derecho real de que se trata, constituyendo dicha inscripción el título que permite la prescripción contra otro título también inscrito. Se aplica, asimismo, cuando invocándose la tradición como título posesorio se pretende adquirir por prescripción el dominio u otro derecho real sobre un inmueble no inscrito.

El artículo 2510 del CC, referido a la prescripción extraordinaria, establece lo siguiente: *“Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio. Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 1° que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción; 2° que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo”*.

A nuestro juicio también para adquirir la prescripción extraordinaria el poseedor irregular necesita un título posesorio. Las palabras rotundas del CC en el sentido de que no se necesita título alguno obedecen a que en estricto rigor los títulos injustos en mérito de los cuales se adquiere posesión irregular que habilita para la prescripción extraordinaria, no tienen en verdad existencia jurídica, son una mera apariencia de lo que en realidad no es. En cuanto a la presunción de buena fe establecida en la prescripción extraordinaria, el legislador se dejó llevar por razones eminentemente prácticas, resultantes del hecho que para adquirir por prescripción extraordinaria, que supone un largo tiempo de posesión, se privilegia ésta última circunstancia por sobre la buena o mala fe del poseedor, que resulta para estos efectos irrelevante. Sin embargo, la presunción es meramente legal, que admite prueba en contrario. La parte final da a entender que podría ser dueño por prescripción un mero tenedor, lo que pugna con los principios básicos de este modo de adquirir, que supone la posesión del prescribiente. Creemos que en esta materia hay una constante voluntad del CC por transformar con arreglo a derecho aquellas situaciones de hecho que se arrastran indefinidamente en el tiempo. En otras palabras, legitimar jurídicamente las situaciones de hecho que no pueden mantenerse en forma indefinida sin un grave trastorno social. Frente a este propósito, el CC optó por abandonar la indelebilidad de la mera tenencia y, excepcionalmente, la convierte en posesión, si al paso del tiempo, diez años, se agregan circunstancias tan especiales como que el mero tenedor haya mantenido la cosa en su poder sin

violencia ni clandestinidad, ni haya el poseedor, a nombre de quien se ostenta la mera tenencia, realizado acto alguno destinado a recuperar la cosa o hacerse reconocer su derecho, ni tampoco ha transcurrido un hecho que le haya impedido al mero tenedor ejecutar actos de posesión, interrupción civil o natural. Por lo tanto, un título de mera tenencia por regla general no puede invocarse para prescribir, y sólo excepcionalmente, cuando se cumplen las circunstancias del artículo 2510 del CC, una de las cuales es que el mero tenedor posea, y la posesión no va a derivar del mero transcurso del tiempo sino que de un título al cual la ley le atribuye, a lo menos en apariencia, el carácter de posesorio, toda vez que el mero transcurso del tiempo jamás puede invocarse como título para prescribir.

Unidad 5: De La Prescripción Adquisitiva.

Tema 1: Generalidades.

Quien no ejerce un derecho revela, si no dudas sobre su efectiva titularidad, a lo menos, falta de interés en cuanto a que el ejercicio de aquél pueda satisfacer una necesidad. El derecho y las facultades que éste establece para su titular no se justifican, desde el momento que nada hace para hacerlos efectivos. Por otra parte, la vigencia indefinida en el tiempo de un derecho puede ser fuente de conflictos que perturbarían la paz social, pues como los derechos no se extinguen, generalmente, por la muerte del titular sino que se traspasan a sus herederos, nadie puede asegurar que el derecho que detenta hoy un titular no corresponda, en verdad, a otra persona que, aunque no lo haya ejercido, lo deriva de un remoto antecesor, ni nadie puede asegurar que una persona no sea perseguida por el cumplimiento de una deuda que contrajo, alguna vez, un antepasado lejano.



Se considera el transcurso del tiempo desde un doble carácter: por una parte, extingue irrevocablemente los derechos personales que no se ejercen; y, por la otra, permite que una persona que no es titular de un derecho real pero que lo ejerce, a diferencia del verdadero titular, que se mantiene inactivo en relación con el derecho, pueda llegar a adquirirlo, de lo que deriva consecuentemente la extinción del derecho para su antiguo titular. Y surge así la clasificación de la prescripción en dos tipos o especies: la que extingue derechos personales y la que opera la adquisición de derechos reales, pasando ésta última a constituir uno de los modos de adquirir el dominio. La primera se denomina prescripción extintiva o liberatoria y se concibe como un medio de extinción de los derechos personales o de las obligaciones. La segunda se llama prescripción adquisitiva o usucapión, y se estructura sobre la base de que quien posee por un lapso determinado por la ley una cosa o derecho real sin ser titular de éste o dueño de aquélla, puede llegar a adquirir el dominio de la cosa o del derecho real de que se trata, todo bajo el natural entendimiento de que el dueño o el titular del derecho real ha perdido la posesión y nada ha hecho por recuperarla.

Ambos tipos de prescripción presentan elementos en común, siendo el primero de ellos el tiempo y el segundo la inacción o inactividad del titular del derecho personal o real. Ambos permanecen inactivos: el acreedor no reclama el derecho, no exige al deudor el cumplimiento de la obligación; y el dueño no reclama la posesión que perdió y nada hace por recuperarla. La institución de la prescripción ha sido objeto de críticas por quienes consideran injusto y hasta inmoral que la ley proteja al deudor que no cumple su obligación y que castigue al acreedor con la pérdida del derecho personal; o que beneficie al que sin ser dueño de la cosa simplemente la posee, castigando al dueño con la pérdida o extinción del derecho real de dominio.

Los últimos artículos del CC, 2492 a 2524, reglamentan la prescripción, con la particularidad de que el legislador trata conjuntamente la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva.

Tema 2: Concepto de prescripción.

El artículo 2492 del CC la define como: “Un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”.

La definición comprende los dos tipos de prescripción:

- i. Prescripción adquisitiva o usucapión; es un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberse poseído las cosas durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.
- ii. Prescripción extintiva o liberatoria; es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.

Tema 3: Requisitos para que opere la prescripción adquisitiva.

Desde la perspectiva que la prescripción opera un efecto tan importante como es la adquisición del dominio, resulta justificado que el legislador, como lo hace por lo demás en todos los modos de adquirir el dominio, establezca rigurosamente requisitos para que opere tal efecto y describa los supuestos de hecho que la hacen procedente:

- a) La cosa debe ser susceptible de adquirirse por prescripción.
- b) Posesión del prescribiente.
- c) Transcurso de un espacio de tiempo.
- d) Concurrencia de los demás requisitos legales:
 - i. La prescripción debe alegarla judicialmente el que quiera aprovecharse de ella, el juez no puede declararla de oficio.
 - ii. La prescripción no debe encontrarse interrumpida.
 - iii. La prescripción no debe encontrarse suspendida.
 - iv. Aunque no es requisito legal, suele agregarse como tal que la prescripción no debe haberse renunciado.

Sección primera: cosas susceptibles de adquirirse por prescripción.

Alcance de la prescripción como modo de adquirir.

Permite adquirir el dominio de todas las cosas corporales muebles o inmuebles que están en el comercio humano; permite, asimismo, la adquisición de todos los derechos reales, salvo cierto tipo de servidumbres, y posibilita, inclusive, la adquisición de una universalidad jurídica, lo que ocurre cuando se gana por prescripción el derecho real de herencia.

Hay ciertas cosas, sin embargo, que no pueden adquirirse por prescripción:

- i. Las cosas inmerciables, como ocurre tratándose de las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres y los bienes nacionales de uso público.
- ii. Las servidumbres inaparentes o discontinuas de acuerdo al artículo 917 del CC. La servidumbre discontinua es la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo. La servidumbre inaparente es la que no se conoce por señal exterior.
- iii. Los derechos personales, es decir, la calidad de acreedor de una persona respecto de otra, el obligado o deudor. La prescripción no está contemplada entre los hechos jurídicos que la ley considera idóneos para hacer nacer un derecho personal. Se ha discutido este punto porque algunos sostienen que la prescripción de los derechos personales estaría permitida, por cuanto el artículo 1576 del CC permite la posesión de los derechos personales. Pero la referencia que hace el artículo al poseedor del crédito es con el alcance de justificar el pago que se haga de buena fe a una persona que no es realmente el acreedor pero que se comporta y actúa como si el crédito realmente le perteneciera, sin que esa sola referencia permita estimar que pueda haber una posesión de los derechos personales que habilite para ganarlos por prescripción.
- iv. Se ha discutido la posibilidad de la prescripción entre comuneros. Sobre el particular se postulan dos interpretaciones: una considera que no es posible la prescripción entre comuneros porque aún cuando uno de ellos en el hecho posea la cosa, debe entenderse que tal posesión la ejerce, en lo que respecta a su cuota, a nombre propio; y en la que respecta a las cuotas de los restantes comuneros, en representación de éstos. Otra interpretación considera que desde el momento que un comunero desconoce el derecho de los otros sobre la cosa, actúa como propietario exclusivo de ésta y si ejerce en tal calidad actos posesorios, sin oposición de los segundos, puede adquirir el dominio por prescripción. Reconociendo que el tema es discutible, nos inclinamos, sin embargo, por la interpretación que rechaza la posibilidad de prescripción entre comuneros porque concordamos con aquellos que piensan que la naturaleza jurídica de la comunidad no hace

posible la posesión exclusiva de un comunero, porque aún cuando éste desconociera el derecho de los otros, debe entenderse que la posesión la ejerce a nombre de todos. Para constituirse en poseedor exclusivo no basta con la tenencia de una cosa, materialmente o por inscripción, sino que es esencial el ánimo de señor y dueño que debe concurrir copulativamente y que no existe si se reconoce la calidad de comunero. Todos y cada uno de los comuneros son poseedores de todos y cada uno de los bienes comunes sin tener posesión exclusiva sobre una parte o cuota de éstos. Entre comuneros no existe la prescripción. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario.

Sección Segunda: La Posesión Como Elemento de la Prescripción Adquisitiva.

La persona que desea prescribir debe realizar actos posesorios, es decir, debe poseer. Hay actos que no constituyen posesión en concepto de la ley:

- i. La mera tenencia nunca conduce a prescripción excepto en el caso contemplado en la regla tercera del artículo 2510 del CC.
- ii. Los actos de mera tolerancia de los que no resultan gravámenes., conforme a los incisos primero y tercero del CC.
- iii. La omisión de actos de mera voluntad, conforme a los incisos primero, segundo y cuarto del artículo 2499 del CC.

La posesión debe ser pública, no clandestina, tranquila, continua y no interrumpida.

Sección Tercera: Transcurso de un Cierta Espacio de Tiempo.

Tiempo para adquirir por prescripción el dominio.

Para determinar el tiempo de prescripción, hay que distinguir dos tipos de prescripción adquisitiva:

- i. Prescripción adquisitiva ordinaria, según el artículo 2507 del CC, es aquella que supone posesión regular no interrumpida. El artículo 2508 del CC dispone: “El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de dos años para los muebles y de cinco años para los bienes raíces”.
- ii. Prescripción adquisitiva extraordinaria, es aquella que supone posesión irregular no interrumpida. El artículo 2511 señala: “El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de diez años contra toda persona y no se suspende a favor de

las enumeradas en el artículo 2509 del CC”. La disposición no distingue entre cosas muebles e inmuebles.

Tiempo para adquirir por prescripción los demás derechos reales.

Todos los derechos reales se pueden adquirir por prescripción excepto las servidumbres discontinuas y las continuas inaparentes. En cuanto al lapso de tiempo necesario para adquirirlos derechos reales distintos del dominio, se siguen las mismas reglas que para la adquisición de éste, con excepción de los derechos reales de herencia, censo y servidumbre, que se rigen por una norma especial contenida en el artículo 2512 del CC.

Lo anterior determina la necesidad de distinguir si el derecho real de que se trata tiene o no alguna regla especial en lo relativo a su prescripción. Si no la tiene, y aplicándose a su respecto las mismas reglas que el dominio, hay que distinguir entre prescripción adquisitiva ordinaria y prescripción adquisitiva extraordinaria, y en caso de la primera, si el derecho real se ejerce sobre una cosa mueble o inmueble. Así, los derechos reales de usufructo y uso constituidos sobre muebles y el de prenda que siempre es mueble se rigen por las mismas reglas para adquirir por prescripción el dominio de una cosa mueble: dos años si es prescripción ordinaria y diez si es extraordinaria. Por su parte, los derechos reales de usufructo y uso constituidos sobre inmuebles y los de habitación e hipoteca que son siempre inmuebles, al igual que el dominio sobre cosa inmueble, se adquieren por prescripción ordinaria de cinco años y por prescripción extraordinario de diez.

Según lo dispuesto en el artículo 882 del CC, al cual se remite el segundo número del artículo 2512 del CC, las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por prescripción de cinco años.

El derecho real de herencia y el de censo se adquieren por prescripción extraordinaria de diez años, conforme a la primera regla del artículo 2512 del CC. Ella confirma que es independiente de que la posesión que se hubiere tenido de ellos pueda calificarse como regular o irregular. Sin embargo, cabe hacer presente que el derecho real de herencia puede adquirirse por prescripción ordinaria de cinco años conforme a dos artículos del CC. El primero, el artículo 704 del CC señala que al heredero putativo a quien por decreto judicial se le haya dado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto. Por su parte, el artículo 1269 del CC dispone que la acción de petición de herencia, que es la que tiene el heredero para reclamar la herencia que ocupa otra persona como heredero putativo, se extingue, por regla general, si no se ejerce dentro del plazo de diez años, que coincide con el plazo en que el heredero putativo puede adquirir el derecho real de herencia por prescripción adquisitiva extraordinaria. Sin embargo, señala dicho artículo que el heredero putativo en el caso del inciso final del artículo 704 podrá oponer a esta acción la prescripción de cinco años.

Sección Cuarta: La Prescripción no Debe Encontrarse Interrumpida.

Interrupción de la prescripción.

La prescripción se funda en dos hechos: uno positivo, la actividad del prescribiente que realiza actos posesorios que revelan su ánimo de dueño; y, el otro negativo, la inacción o inactividad del dueño, quien encontrándose en situación de percibir que el otro posee la cosa, nada hace para evitarlo. Dichos hechos configuran la prescripción en su esencia, de modo que no se puede concebir ésta si falta uno u otro de aquellos.

El ejercicio de actos posesorios por parte del prescribiente supone, no sólo que tanga la cosa en su poder por el tiempo de prescripción, sino que ésta se encuentre en condiciones que hagan posible dicho ejercicio, toda vez que la ejecución de actos posesorios y su posterior comprobación es lo que permite al poseedor ganar el dominio por este modo de adquirir.

La inactividad del dueño supone, como decíamos antes, que éste nada hace por recuperar la posesión. Pero dicho estado de inacción termina si el dueño recurre a los Tribunales de Justicia y entabla una acción judicial en contra del poseedor.

La ocurrencia de cualquiera estos dos hechos, es decir, la imposibilidad en el poseedor de ejercicio de actos posesorios, o la acción o demanda judicial del dueño, obstan a la prescripción que podría haber operado si no hubieran ocurrido y hacen que la posesión del prescribiente se convierta en inútil, lo que reconoce la institución que se denomina interrupción de la prescripción, la cual establece los efectos que producen ciertos hechos que hacen imposible la ejecución de actos posesorios por parte del poseedor o los efectos que produce cualquiera acción judicial del dueño en contra del poseedor, ambos en relación con la prescripción que estaba corriendo.

En general, los efectos de la interrupción de la prescripción son los siguientes: por una parte, como efecto inmediato y directo, la prescripción que estaba corriendo se detiene; por otra, y como efecto adicional, el tiempo de prescripción ganado con anterioridad se pierde, aunque veremos que a veces este efecto no se produce.

Veámos que la interrupción de la prescripción supone, ya sea la imposibilidad de ejercer actos posesorios, o la acción judicial intentada por el que se pretende dueño en contra del poseedor. Sobre esta base, la interrupción de la prescripción se clasifica en natural y civil.

Interrupción natural de la prescripción.

El artículo 2502 del CC dispone: “La interrupción es natural: 1° Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido inundada; 2° Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra

persona. La interrupción natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duración; pero la interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de posesión anterior, a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, en conformidad a lo dispuesto en el título De las Acciones Posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído”.

De acuerdo con la disposición transcrita, cabe distinguir dos especies de interrupción natural:

i. Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios.

Ciertos hechos o circunstancias de la naturaleza o del hombre, ajenos a la voluntad del prescribiente o imputables a hecho o culpa de éste, hacen imposible el ejercicio de actos posesorios sobre la cosa. El hecho interrumpe la prescripción que estaba corriendo en beneficio del poseedor, lo que significa de partida que la prescripción se detiene. Habiendo desaparecido la causal de interrupción, la prescripción vuelve a correr, pero con un importante efecto: el tiempo de prescripción ganado con anterioridad no se pierde, lo que significa que se computa para completar el plazo que necesítale poseedor para adquirir el dominio por prescripción. Cabe tener presente, eso sí, que conforme a lo dispuesto en el artículo 653 del CC, si la inundación dura más de cinco años, sobre el terreno inundado se pierde el dominio y la posesión, de modo tal que si con posterioridad a los cinco años las aguas se retiran y restituyen el terreno, el dominio y la posesión sobre el mismo se adquieren por lo propietarios riberaños por el modo de adquirir accesión.

ii. Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona.

Se funda en la imposibilidad de ejercicio de actos posesorios por parte del prescribiente, pero con una diferencia con respecto a la causal anterior, en el primero éste conserva la posesión; en el segundo, en cambio, la posesión se pierde porque ha pasado a otras manos, es decir, otra persona tiene la cosa en su poder con ánimo de señor y dueño porque, por ejemplo, se ha apoderado de la cosa mueble o del inmueble no inscrito. El primer efecto que produce este segundo tipo o especie de interrupción natural es que la prescripción que estaba corriendo se detiene, efecto común a toda interrupción de cualquier tipo. El segundo efecto es que el tiempo de prescripción ganado con anterioridad se pierde, a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título De las Acciones Posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído, conforme al segundo número del artículo 2502 del CC. Conforme a lo señalado, sólo tiene aplicación si se recobra la posesión de inmuebles, pues sólo ésta

es la que amparan las acciones posesorias y no si se recupera legalmente la posesión de una cosa mueble. Sin embargo, no es posible desconocer que esta interpretación se aparta del principio general contenido en el artículo 731 del CC que dispone: “El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio”, artículo que no distingue entre muebles e inmuebles, por lo que se aplica a ambos, lo que aparece corroborado por el hecho de que no menciona a las acciones posesorias como el único medio de recuperar legalmente la posesión perdida. Estimamos que el artículo 731 del CC establece la regla general en el sentido que el poseedor de cosa mueble o inmueble que recupera por los medios que franquea la ley la posesión perdida y que descartan las vías de hecho que suponen hacerse justicia por sí mismo, no pierde el tiempo de prescripción ganado antes de haber sido privado de la posesión, hecho que provocó la interrupción de ella. En el caso del poseedor de bienes raíces, las acciones posesorias constituyen, por expresa disposición de la ley, uno de los medios de recuperar la posesión perdida en virtud del cual no se pierde el tiempo de posesión anterior, pero no el único. Otros medios de recuperar legalmente la posesión que se tenía tanto sobre cosa mueble como inmueble son, por ejemplo, la acción reivindicatoria y la acción publiciana.

Interrupción civil de la prescripción.

Se interrumpe civilmente cuando, cesando la inactividad del dueño, éste demanda judicialmente al poseedor. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2503 del CC la interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa, contra el poseedor. Partiendo del supuesto que el recurso o demanda se notifica legalmente al poseedor, por el solo hecho de su interposición se produce el efecto de la interrupción de la prescripción ordinaria o extraordinaria, cual es la detención del tiempo de prescripción que estaba corriendo, con lo cual la posesión se convierte en inútil.

Sin embargo, no siempre la demanda interrumpe la prescripción, lo que significa que ésta, a pesar de aquella, sigue corriendo. Lo anterior ocurre solamente en tres casos enumerados en el artículo 2503 del CC y que son los siguientes:

- i. Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal.
- ii. Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia.
- iii. Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.

En estos tres casos, se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. La ley no califica cual recurso judicial es idóneo para interrumpir la prescripción, señalando, por el contrario, que todo recurso judicial tiene tal calidad, significando ello, en términos amplios,

cualquiera alegación ante los Tribunales de Justicia que constituya procesalmente hablando la oposición del dueño o de quien se pretende tal en contra de la posesión que otro tiene sobre la cosa. Si el recurso judicial no llegara a interrumpir la prescripción, se entiende que no se detiene la prescripción, y que ésta sigue corriendo, como si nunca se hubiera interrumpido, lo que significa que no se pierde el tiempo de prescripción ganado con anterioridad.

Sección Quinta: La Prescripción no Debe Encontrarse Suspendida.

Hemos visto que la institución de la prescripción beneficia al poseedor y perjudica al dueño, que revela con su inacción falta de interés en la conservación de su derecho. Ocurre, sin embargo, que no todos los propietarios se encuentran en situación de reaccionar en forma oportuna cuando otra persona los priva de la posesión de la cosa, presumiendo la ley que tienen tal calidad las personas incapaces, sea que tengan o no representante legal, bajo el supuesto que si carecen de representante, están imposibilitados de ejercer por sí mismos cualquiera acción legal en contra del poseedor, y que si lo tienen, el representante puede no ser lo suficientemente acucioso para actuar en defensa de sus derechos.

Consecuencia de lo anterior, la prescripción que puede afectar a los incapaces no corre en contra de ellos, por regla general desde el momento en que surge la incapacidad legal hasta que ésta cesa, de modo tal que una vez que ha cesado la incapacidad del dueño, la prescripción en su contra corre o vuelve a correr, computándose, asimismo, para el plazo de prescripción el tiempo de posesión anterior a la causal de incapacidad, si lo hubo.

El artículo 2509 del CC define la suspensión como: “Es un beneficio establecido por la ley a favor de ciertas personas, por lo general incapaces, y de la herencia yacente, en contra de las cuales no corre la prescripción”. El citado artículo se conforma con el principio general establecido en el artículo 2497 del CC que dispone: “Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”.

De conformidad con lo que dispone el artículo 2509 del CC, puede suspenderse, sin extinguirse la prescripción ordinaria, palabras con las que el CC da a entender que si bien la prescripción estaba corriendo se detiene, no se extingue, lo que significa que cesando la causa de suspensión vuelve la prescripción a correr y se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo.

Es importante advertir que la suspensión y sus efectos sólo los contempla excepcionalmente la ley en la prescripción adquisitiva ordinaria, pues el artículo 2511 del CC señala que la prescripción extraordinaria corre contra toda persona y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2509 del CC.

Es importante señalar que la suspensión de la prescripción ordinaria beneficia exclusivamente, de acuerdo al artículo 2509 del CC, a las siguientes personas:

a) Los menores, los dementes, los sordomudos, y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría.

Son los incapaces de ejercicio, ya sea absoluto o relativo. No se menciona al pródigo disipador porque para que éste sea incapaz relativo debe estar declarado en interdicción, nombrándole el decreto de interdicción un curador.

b) La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta.

Constituye una excepción al principio general de que sólo se suspende la prescripción en beneficio de las personas que no pueden administrar libremente los suyos. Si bien la mujer casada en régimen de sociedad conyugal es capaz, la sociedad conyugal la administra el marido. No se suspende la prescripción a favor de la mujer divorciada o separada de bienes respecto de aquellos que administra.

c) La herencia yacente.

Son los bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada y a los cuales el juez designa un curador con facultades que dicen relación con la administración, custodia y conservación de los bienes de la herencia, incluyéndose dentro de ellas la de interrumpir las prescripciones por medio de las cuales podrían adquirirse bienes del difunto comprendidos en la herencia yacente.

El artículo 2509 del CC termina diciendo que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges, los cuales no están comprendidos en la enumeración sino que están contemplados en un párrafo aparte, lo cual, conjuntamente con la interpretación de la palabra siempre, se ha prestado para diversas interpretaciones. Por una lado, hay quienes sostienen que la prescripción ordinaria se suspende entre cónyuges, sea que éstos se encuentren o no casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Otros sostienen que tanto la prescripción ordinaria como la extraordinaria se suspende entre cónyuges por los siguientes argumentos:

- i. El artículo 2509 del CC dice que la prescripción ordinaria se suspende a favor de las personas que la disposición enumera, lo que reitera el artículo 2511 que establece que la prescripción extraordinaria no se suspende a favor de las personas enumeradas en el artículo 2509 del CC, y resulta que éste último no enumera a los cónyuges entre las personas beneficiadas con la suspensión, sino que los contempla en un párrafo aparte.
- ii. El inciso final del artículo 2509 del CC se refiere a ambos tipos de prescripción y luego dice que se suspende siempre entre cónyuges, de lo que es posible concluir que un cónyuge jamás puede adquirir por prescripción ordinaria o extraordinaria los bienes del otro.

Nos parece que ésta es la interpretación correcta, lo que corrobora hebreo que presumiblemente la disposición quiso evitarlos conflictos que, sin duda, provocaría entre marido y mujer la posibilidad de que uno adquiriera por prescripción los bienes del otro, precaución que es válida independientemente del régimen conyugal bajo el cual se encuentren casado y aplicable a ambas clases de prescripción, ordinaria y extraordinaria.

En cuanto a los efectos de la suspensión, debe mencionarse que en contra de las personas y de la herencia yacente que enumera el artículo 2509 del CC no corre la prescripción adquisitiva ordinaria. Entre los cónyuges, independientemente del régimen bajo el cual se encuentren casados, jamás corre prescripción ni ordinaria ni extraordinaria, lo que revela que la posesión de los bienes del otro será inútil. En caso que hubiere corrido algún tiempo de prescripción antes que se hubiera configurado la causal de suspensión, se detiene la prescripción hasta que cese la causal y después sigue corriendo. En todo caso, el tiempo ganado con anterioridad a la suspensión no se pierde y se computa para el plazo de prescripción.

Sección Sexta: Renuncia de la Prescripción.

La prescripción beneficia exclusivamente al poseedor que adquiere el derecho de alegarla para poder acogerse a los efectos de esta institución. Conforme al artículo 12 del CC puede renunciarse todo derecho que mitre al interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia.

El artículo 2494 del CC dispone: *“La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero sólo después de cumplida”*. Por lo tanto, no puede renunciarse antes de haber expirado el tiempo de posesión que habilita para adquirir el dominio por prescripción. La ley prohíbe, en consecuencia, la renuncia del poseedor a la prescripción que no se ha cumplido. Renuncia expresamente a la prescripción el poseedor que manifiesta su voluntad en tal sentido, en una declaración verbal o por escrito, sin que la ley exija ninguna solemnidad. Renuncia tácitamente, en cambio, cuando la voluntad de renunciar, no manifestada en términos explícitos y directos en una declaración, se desprende inequívocamente de un comportamiento del poseedor. En inciso segundo del artículo 2494 del CC señala específicamente el comportamiento del poseedor del cual la ley desprende la intención de renunciar tácitamente a la prescripción: cualquier hecho de éste que manifieste que reconoce el derecho del dueño, mencionando el artículo, como ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción el poseedor de la cosa la toma en arriendo.

El efecto que produce la renuncia expresa o tácita a la prescripción es que el renunciante no puede alegarla en su beneficio. De lo anterior se desprende que la renuncia constituye un acto de disposición del derecho de dominio, como si éste se enajenara. Como consecuencia de ser la renuncia a la prescripción un acto de disposición, sólo puede efectuarla la persona que tenga facultad para enajenar. Esto significa no sólo que el renunciante debe ser capaz o un incapaz debidamente representado o autorizado, sino que debe, además, tener la capacidad de enajenar

la cosa que adquirió por prescripción y cumplir, en su caso, las formalidades legales a que pudiera estar sujeta la enajenación.

Cabe agregar que hay personas que piensan que la renuncia a la prescripción presupone, no sólo una prescripción cumplida, sino que una sentencia judicial que haya declarado la prescripción a favor del poseedor, pues sólo entonces operan los efectos de la prescripción y cabe jurídicamente hablar de renuncia a ella. Discrepamos de esta opinión porque estimamos que para la adquisición del dominio por prescripción no se requiere sentencia judicial y que, por el contrario, la prescripción opera una vez que la persona que ha tenido la posesión que habilita para prescribir ha cumplido el plazo de posesión que requiere este modo de adquirir. Desde ese momento se entiende que el poseedor es dueño. Sin embargo, para que ese dominio sea reconocido por todos y produzca efectos erga omnes, es menester que una sentencia judicial lo reconozca y esta función la cumple la sentencia que declara la prescripción. Creemos, sin embargo, que manifestada la opción encaminada a aprovechar la prescripción, una vez dictada la sentencia tal decisión es irrevocable, porque la sentencia que reconoció el dominio adquirido por prescripción produce efectos no sólo respecto del poseedor sino que de cualquiera persona, en el sentido que el prescribiente es el dueño de la cosa. Lo anterior justifica, a nuestro juicio, que antes de la sentencia el poseedor pueda renunciar a este dominio sui generis, porque sólo existe para él, y que después de la sentencia no pueda renunciar al dominio porque éste ya adquirió la connotación propia del derecho real que es la de existir respecto de toda persona, lo que significa que todos están obligados a respetarlo, pudiendo el dueño hacerlo oponible a cualquiera que lo desconozca.

Creemos, en consecuencia, que la renuncia de la prescripción constituye, en estricto rigor, una renuncia a la facultad de alegar la prescripción. Con posterioridad a la sentencia no cabe hablar de renuncia a la prescripción, porque aquella supone un hecho que revela una intención contraria, cual es la alegación de la prescripción, sino que de renuncia al derecho real que la sentencia reconoció e hizo oponible a todos, correspondiendo en tal caso analizar si tal derecho real puede extinguirse por el solo hecho de su renuncia, lo que la ley permite, por ejemplo, tratándose del derecho de usufructo, pero no así respecto del dominio sobre una cosa corporal.

Lo que puede ocurrir es que si ejecuta algún acto que implique reconocer el dominio de la persona que lo perdió como consecuencia de la prescripción, como es pagar una renta a título de arrendamiento, revela con ello que tiene la cosa a nombre y en lugar de otro, en esta hipótesis del dueño anterior, o lo que es lo mismo, que no es poseedor. O sea, no pierde el dominio que sigue radicado en él, pero pierde la posesión, y ésta la adquiere el antiguo dueño, que si bien no tiene la cosa en su poder, la tiene a través de otra persona; además con el ánimo de señor y dueño que revela el cobro y percepción de las rentas de arrendamiento. De esta manera, el antiguo dueño en contra de quien se declaró la prescripción puede adquirir, a su vez, por prescripción el dominio de la cosa.

Unidad 6: De Las Limitaciones al Dominio.

Tema 1: Derechos Reales Limitados.

Son los que no confieren todas las facultades del dominio, por ejemplo, la facultad de gozar la cosa en el derecho de habitación, la facultad de disponer de la cosa en el derecho de usufructo, uso y habitación. Lo dicho es sin perjuicio de la facultad que tiene el usufructuario de disponer de su derecho de usufructo, facultad que no tiene el usuario ni el habitador. Se les conoce también **como desmembraciones del dominio o como derechos reales en cosa ajena.**



Tema 2: Clasificación de los Derechos Reales Limitados.

a) Derechos reales limitados de goce o de uso.	Son aquellos quedando el goce o uso de la cosa, el titular no tiene todas las facultades que confiere el dominio al titular de este derecho. Son el usufructo, el uso o la habitación y las servidumbres. En el fideicomiso, el derecho de dominio que tiene el propietario fiduciario, si bien es derecho de dominio con todos sus atributos, es limitado en cuanto el fiduciario debe conservar la integridad y valor de la cosa sobre la que recae la propiedad fiduciaria conforme al artículo 758 del CC.
b) Derechos reales limitados de garantía.	Son aquellos que sólo dan derecho sobre una cosa para hacer efectiva en ella una obligación. Son, fundamentalmente, el derecho de hipoteca, el de prenda y el de censo.

Tema 3: Derechos Reales Limitados del Dominio.

Son los que limitan o restringen las facultades que otorga el derecho de dominio a su titular. Por regla general, los derechos reales limitados son limitativos del dominio. No lo es el fideicomiso ya que la limitación que tiene el propietario fiduciario es en beneficio del fideicomisario, que no es titular de ningún derecho real. Es decir, la limitación le es impuesta por la ley y no por otro derecho real. Tampoco lo serían los derechos de usufructo o uso sobre cosa mueble abandonada al primer ocupante pues, si bien es cierto que el usufructo y el uso normalmente limitan al derecho de dominio, no lo harían en el caso propuesto por no existir tal derecho mientras la cosa no es ocupada por alguna persona.

Tema 4: Limitaciones del Dominio.

De acuerdo al artículo 732 del CC: **“El dominio puede ser limitado de varios modos:**

- i. Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición.
- ii. Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga derecho en las cosas que le pertenecen a otra.
- iii. Por las servidumbres”.

Ya hemos visto como hay otras imitaciones del dominio, por ejemplo, la hipoteca, la prenda y el censo. También hemos visto que hay limitaciones del dominio que no son derechos reales, por ejemplo, las obligaciones reales, el abuso del derecho, las que derivan de la vecindad, las que se establecen en razón de salubridad pública, etc.

Unidad 7: De La Acción Reivindicatoria.

Tema 1: Concepto.

El artículo 889 del CC dispone: **“La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela”**. No es la única forma en que puede ampararse el derecho de dominio pues, del contrato de arrendamiento, del comodato, etc., nacen acciones personales para obtener la restitución de la cosa. El dueño, en todo caso, puede emplear la reivindicación; ello no es frecuente debido a las dificultades de prueba, ya que es necesaria la prueba del dominio. En cambio, si se emplea la acción

Tema 2: Condiciones necesarias para entablar la acción reivindicatoria.

Para ello es necesario:

- Que la persona sea dueña de la cosa.
- Que no esté en posesión de la cosa.
- Que la cosa sea susceptible de reivindicarse.

2.1 Es necesario ser dueño de la cosa.



Observación

El artículo 893 del CC dice que **puede reivindicar el propietario cualquiera sea la calidad que tenga, propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria**. Podrá, entonces, también reivindicar el **comunero**, en cuanto es propietario de su cuota, conforme al artículo 892 del CC. Excepcionalmente el poseedor podrá reivindicar la cosa, aunque no pruebe su dominio, ejerciendo la llamada acción publiciana contemplada en el artículo 894 del CC y que se concede al que ha perdido la posesión regular de la cosa y se hallaba en el caso de poder ganarla por prescripción, pero no se podrá ejercer ni contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho. Muchas veces es difícil probar el dominio y en cambio es posible acreditar la posesión, además, conforme al artículo 700 del CC, al poseedor se le presume dueño por tener generalmente esa calidad.

Se presenta un problema doctrinario en relación a las situaciones en que se puede encontrar el poseedor regular. El primer caso es cuando el poseedor regular ha enterado ya su plazo de prescripción y ello ha sido declarado judicialmente. En este caso, siendo ya el propietario, si es privado de la cosa puede entablar la acción reivindicatoria. No entabla la acción publiciana ya que en tal caso no es poseedor sino dueño. El segundo caso se da cuando el poseedor regular ha enterado ya el plazo pero la prescripción no ha sido declarada judicialmente. El tercer caso se da cuando el poseedor regular le está corriendo el plazo de prescripción. Alessandri piensa que la acción publiciana sólo puede intentarla el poseedor regular que haya cumplido el plazo indicado para la prescripción ya que si no, el hecho de que otro se apodere de la cosa constituirá interrupción natural que hace perder el tiempo ganado con anterioridad, de manera que el poseedor no estaría en situación de adquirir la cosa por prescripción. Otros piensan que la acción publiciana ha sido establecida a favor del poseedor regular que está en vías de poder ganar la cosa por prescripción, cuando el plazo aún no se ha cumplido. Se argumenta que el que ha cumplido el plazo no es poseedor, es dueño, pues la sentencia que declara la prescripción es un título declarativo; el dueño entabla la acción reivindicatoria y no la publiciana. El inciso final del artículo 894 del CC confirmaría que ésta es la buena doctrina al decir que esta acción no puede alegarse contra el verdadero dueño ni contra el que posea con igual o mejor derecho.

2.2 El dueño debe haber sido privado de la posesión de la cosa.

Los litigantes de esta acción son el propietario no poseedor contra el poseedor no dueño. El objeto de la litis es la posesión de la cosa. En la acción reivindicatoria el dominio sirve como antecedente, como causa a pedir. Se observa la diferencia que existe entre esta acción y las posesorias: **en la reivindicatoria el dominio es la causa a pedir; en las posesorias la causa a pedir es la posesión.**

El que reivindica una cosa, diciéndose dueño de ella, debe acreditar su dominio, ya que al entablar la acción reconoce en su contrincante la calidad de poseedor, el cual está amparado por la presunción consagrada en el artículo 700 del CC. Pero hay una excepción: cuando el reivindicante es el Fisco, no está obligado a probar su derecho de dominio, ya que el artículo 590 del CC señala que son bienes del Estado todas las tierras que carezcan de dueño. Hay que tener presente que esta presunción a favor del Fisco se refiere al dominio y no a la posesión.

Para probar el dominio se aplican las reglas generales referentes a la prueba. Recordemos que si el modo de adquirir es originario bastará que el reivindicante pruebe su propio dominio; en cambio, si el modo de adquirir es derivativo, tiene que probar, además, el dominio de sus antecesores, porque nadie puede adquirir más derechos que los de sus antecesores. Hemos dicho que la inscripción representa la posesión, es el corpus y el animus. Si un poseedor inscrito es privado

materialmente de un inmueble, no entabla la acción reivindicatoria porque no se le ha privado de la posesión.

2.3 Que la cosa sea susceptible de reivindicarse.

Es condición esencial para que pueda prosperar la acción reivindicatoria que se determine y especifique de tal manera la cosa singular que se reivindica que no pueda caber duda en su individualización, a fin de que la discusión de las partes pueda recaer sobre una cosa concreta y que los Tribunales de Justicia resuelvan el litigio con pleno conocimiento de los hechos. Sólo pueden reivindicarse las cosas singulares y no las universalidades.

El artículo 890 del CC señala que pueden reivindicarse las cosas corporales, sean raíces o muebles, con tal que se individualicen y sean singulares. También pueden reivindicarse los derechos reales que signifiquen cosas singulares corporales. También se puede reivindicar una cuota determinada proindiviso de una cosa singular, conforme al artículo 892 del CC. El derecho del comunero burlado se puede hacer presente de dos maneras: primero, entablando la acción reivindicatoria en contra de terceros; y, segundo, pidiendo él que el actual poseedor le reconozca la calidad de comunero. Sabemos que respecto de las cuotas de los otros comuneros, por parte de uno de ellos, ha habido venta de cosa ajena, la cual es válida, sin perjuicio de los derechos del dueño, mientras no se extingan por el lapso del tiempo conforme al artículo 1815 del CC.

No se pueden reivindicar las siguientes cosas:

- i. **El derecho de herencia porque es una universalidad jurídica.** El heredero está amparado por la acción de petición de herencia, que emana del dominio, ya que la herencia es el derecho de dominio sobre una universalidad en relación con la sucesión por causa de muerte. En la acción de petición de herencia no se discute el dominio sino la calidad de heredero. Sin embargo, podrá intentar la acción reivindicatoria para reclamar cosas singulares que están dentro de la universalidad, conforme al artículo 1268 del CC.
- ii. **Tampoco pueden reivindicarse los derechos personales,** sin perjuicio de que pueda reivindicarse el documento en el cual consta el crédito.
- iii. De acuerdo al segundo inciso del artículo 890, **no pueden reivindicarse las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento industrial** que vendan cosas muebles de la misma clase. Se desprende que hay una protección a la buena fe ya que justificada esta circunstancia, no estará el poseedor obligado a restituir la cosa si no se le reembolsa lo que ha dado por ella y lo que ha gastado en repararla y mejorarla.

- iv. **En el pago de lo no debido**, si el título es oneroso y el poseedor está de buena fe, no se puede reivindicar. Si el título es gratuito se puede reivindicar siempre que la cosa sea reivindicable.
- v. Tampoco prospera la acción reivindicatoria cuando **el tercero adquirió la cosa por prescripción**.
- vi. Cuando se ha declarado resuelto un contrato **no hay acción reivindicatoria en contra de terceros poseedores de buena fe**, conforme a los artículos 1490 y 1491 del CC.

Tema 3: Contra quien se puede reivindicar.

3.1 Generalidades.

La regla general es que la acción reivindicatoria se dirija en contra del actual poseedor conforme al artículo 895 del CC. **Para el reivindicante tiene importancia determinar quién es el poseedor, porque él debe litigar contra legítimo contradictor.** Por otra parte, las sentencias judiciales producen efectos relativos, de ahí que si el reivindicante entabla la demanda contra quien no es poseedor ha perdido su tiempo porque esta sentencia no va a producir ningún efecto contra el verdadero poseedor.

Por este motivo, **se toman medidas de resguardo a favor del reivindicante para que sus esfuerzos no sean inútiles:**

- i. Puede suceder que el reivindicante conozca al mero tenedor, pero no sabe quién es el poseedor. En este caso, el artículo 896 del CC dispone: “El mero tenedor de la cosa que se reivindica es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene”.
- ii. Si una persona de mala fe se hace pasar por poseedor sin serlo, está obligada a indemnizar de todo perjuicio al reivindicante, conforme al artículo 897 del CC.

3.2 Acción de dominio contra herederos.

Puede ocurrir que el poseedor haya fallecido dejando varios herederos. La acción reivindicatoria tiene por objeto no sólo la entrega de la cosa sino que también el pago de otras indemnizaciones: deterioros, devolución de los frutos o de su valor, etc. El artículo 899 del CC dispone: ***“La acción de dominio no se dirige contra un heredero, sino por la parte que posea en la cosa, pero las prestaciones a que estaba obligado el poseedor por razón de los frutos o de los deterioros que le sean imputables, pasan a los herederos de éste a prorrata de sus cuotas hereditarias”***. La razón de esta diferencia está en que existan dos obligaciones: una divisible, las indemnizaciones; y la otra indivisible, que es la restitución de la cosa.

3.3 Casos en que la acción reivindicatoria se dirige contra el actual poseedor.

El principio indicado en el artículo 895 del CC de que la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor tiene excepciones:

a) Se puede dirigir en contra del que dejó de poseer la cosa.

En este caso se pueden presentar dos situaciones: que el poseedor esté de buena fe o de mala fe, considerando el momento inicial de la posesión.

Si el poseedor está de buena fe, se dirige la acción para que le entregue el precio que recibió por la cosa al enajenarla. Se produce la figura llamada subrogación real, se sustituye una cosa por otra, se reemplaza la cosa por el precio. Puede suceder que el poseedor de buena fe haya enajenado la cosa sabiendo que era ajena. Esto es perfectamente posible ya que para considerar la buena fe se atiende al momento en que empezó la posesión. Entonces, además, debe pagar las debidas indemnizaciones. El reivindicador, al aceptar y recibir el precio, está confirmando un acto que le era inoponible conforme al segundo inciso del artículo 898 del CC.

Si el poseedor estaba de mala fe, y por un hecho o culpa suya ha dejado de poseer, conforme al artículo 900 del CC podrá intentarse la acción de dominio como si actualmente poseyese a disponer: “De cualquier modo que haya dejado de poseer y aunque el reivindicador prefiera dirigirse contra el actual poseedor, respecto del tiempo que ha estado la cosa en su poder tendrá las obligaciones y derechos que según este título corresponden a los poseedores de mala fe en razón de frutos, deterioros y expensas”. En caso que el que dejó de poseer pague al reivindicante lo que recibió por la cosa, se entiende que ratifica la venta.

El comprador que ha sido privado de la cosa en juicio por el verdadero dueño tiene dos derechos: primero, que el vendedor lo ayude en el juicio en contra del verdadero dueño; y, segundo, si es vencido en este juicio el vendedor debe indemnizarlo. El saneamiento es una obligación que tiene el vendedor con respecto al comprador de la cosa y que consiste en indemnizarlo, especialmente cuando el comprador es privado de todo o parte de la cosa por sentencia judicial. Es lo que se llama evicción de la cosa, respondiendo el vendedor al comprador de saneamiento por evicción. El inciso final del artículo 900 del CC nos revela que el saneamiento no pesa sobre el reivindicante sino que recae sobre el poseedor de mala fe que dejó de poseer. Por el contrario, el artículo 898 del CC, que se refiere al que dejó de poseer de buena fe, no dice nada al respecto, por lo que se entiende que el reivindicante responde del saneamiento.

b) La acción reivindicatoria se puede dirigir en contra del mero tenedor.	El artículo 915 del CC dispone que el arrendador o el comodante tienen dos acciones para obtener la restitución de la cosa arrendada o dada en comodato: primero , la acción personal que nace del respectivo contrato; y, segundo , la acción reivindicatoria. Generalmente se emplea la acción derivada del contrato porque es de tramitación más corta.
---	--

Tema 4: Prescripción de la acción reivindicatoria.

4.1 Generalidades.

Se extingue no por la prescripción extintiva, ni por el no ejercicio del derecho por el transcurso del tiempo, sino que por la **prescripción adquisitiva**. Por lo tanto, no basta la inacción del propietario para que prescriba la acción reivindicatoria sino que es necesario que otra persona obtenga la posesión. La acción reivindicatoria se extingue cuando se ha extinguido el derecho de dominio, luego, no tiene un plazo fijo de prescripción. Con respecto a los muebles podrá durar dos años o un tiempo intermedio; respecto a los inmuebles, en cinco años o un tiempo intermedio; tratándose de prescripción extraordinaria el plazo será de diez años. Ello se deduce del artículo 2517 del CC que dispone: *“Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho”*. Tanto la acción reivindicatoria como la de petición de herencia son acciones propietarias porque se extinguen por la prescripción adquisitiva.

4.2 Naturaleza.

La acción reivindicatoria **es una acción real porque deriva de un derecho real**.

4.3 Calidad.

Puede ser mueble o inmueble, según sea la cosa en que ha de ejercerse. Esto es importante para determinar la competencia del Tribunal de Justicia que ha de conocer de ella. El juicio de reivindicación es un juicio ordinario, juicio de pleno conocimiento.

4.4 Medidas precautorias durante el juicio.

El demandado está muy protegido ya que goza de la presunción de ser dueño de la cosa, aún durante el juicio. Además, conserva el goce de la cosa conforme al primer inciso del artículo 902 del CC. Aplicados estos principios a las cosas muebles, llegamos a establecer que el poseedor podría enajenarlas. El reivindicante podría ser burlado por el poseedor de la cosa, por ello, los artículos 901 y 902 del CC lo autorizan para solicitar ciertas medidas precautorias con el objeto de asegurar los resultados del juicio.

Si la cosa que se va a reivindicar es muebles, el reivindicante tiene derecho a solicitar el secuestro de ese bien, es decir, el depósito hecho por orden judicial en manos de una persona. Si la cosa que se va a reivindicar es inmuebles, se puede pedir nombramiento de uno o más interventores. Pueden solicitarse, además, otras medidas precautorias como, por ejemplo, la prohibición de celebrar actos y contratos relativos a la cosa objeto de la litis, medidas para evitar los deterioros de la cosa, etc.

Tema 5: Prestaciones mutuas.

5.1 Concepto.

Son las indemnizaciones, devoluciones recíprocas que se deben mutuamente reivindicante y poseedor, cuando este último es vencido en el juicio reivindicatorio. Lógicamente que cuando el poseedor vence en el juicio reivindicatorio estas prestaciones no tienen lugar.



5.2 Obligaciones que tiene el poseedor vencido para con el reivindicante.

a) Restitución de la cosa.

De acuerdo al artículo 904 del CC debe hacerse en el plazo que el juez señale. Esta es una norma excepcional en nuestro derecho ya que el juez no puede fijar plazos, salvo en casos excepcionales en que la ley lo autorice. La sentencia que da lugar a la demanda, se cumple en conformidad a las reglas especiales de procedimiento, y éste va a depender de la época en que se exige el cumplimiento. Si se pide dentro del plazo de un año contado desde que la ejecución se hizo exigible, se cumple en forma incidental. Si el reivindicante pide el cumplimiento del fallo pasado el plazo de un año, debe entablar un juicio ejecutivo. La sentencia le servirá de título ejecutivo.

b) Indemnización de los deterioros que hubiere causado en la cosa

Conforme al artículo 906 del CC debemos distinguir entre poseedor de buena fe y poseedor de mala fe. Aplicando por analogía el artículo 913 del CC, esta mala o buena fe del poseedor para los efectos de los deterioros se considerará en el momento en que se produjeron. Debemos tener presente que después de la contestación de la demanda el poseedor de buena fe es considerado de mala fe. El inciso primero del artículo 906 del CC dispone: “El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa ha sufrido la cosa”. En cambio, el poseedor de buena fe no responde por los deterioros sino en cuanto se hubiere aprovechado de ellos, por ejemplo, destruyendo un árbol. En este caso, no pudiendo haber enriquecimiento sin causa, el poseedor de buena fe debe una indemnización equivalente al beneficio que le hubiere ocasionado el deterioro.

c) Restitución de los frutos.

Se distingue también entre poseedores de buena o mal fe conforme al artículo 907 del CC que dispone: *“El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa y no solamente los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieren tenido al momento de la percepción: se considerarán como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder”*. En cambio, el poseedor de buena fe no está obligado a devolver los frutos que hubiere percibido antes de la contestación de la demanda. Después de ella se asimila automáticamente al poseedor de mala fe. Debemos relacionar esta materia con el artículo 913 del CC que dispone: *“La buena o mala fe del poseedor se refiere, relativamente a los frutos al tiempo de la percepción y relativamente a las expensas y mejoras al tiempo en que fueron hechas”*.

d) Debe abonarle al reivindicante los gastos de custodia y conservación de la cosa durante el juicio.

Si la cosa fue secuestrada pagará el actor al secuestro los gastos de custodia y conservación, y tendrá derecho para que el poseedor de mala fe se los reembolse. Esto es lo que se llama contribución a los gastos y que está obligado a pagarlos el poseedor de mala fe pero no el de buena fe.

5.3 Obligaciones el reivindicante para el poseedor vencido.

a) Debe satisfacerle los gastos ordinarios y costos de producción de frutos.

Es lógico porque aún cuando la cosa hubiere estado en manos del reivindicante siempre para producir los frutos habría sido necesario efectuar esos gastos.

b) Debe abonarle las mejoras.

Mejora es toda obra que se ejecuta en una cosa y que tiene por objeto su conservación o un aumento de su valor, o en razón de su ornato o recreo. Las mejoras pueden ser de tres clases: primero, las **mejoras necesarias**, son aquellas indispensables para la conservación y mantenimiento de la cosa; segundo, **mejoras útiles**, son aquellas que aumentan el valor venal de la cosa; y, tercero, **mejoras voluptuarias**, son las que consisten en objetos de lujo y recreo, y si aumentan el valor de la cosa es en forma insignificante. Para el pago de las mejoras se atenderá a dos factores: a la buena o mala fe del poseedor, y a la calidad de las mejoras.

En el pago de las mejoras necesarias prevalece la calidad de las mejoras sobre la buena o mala fe del poseedor. Siempre el reivindicante debe abonar al poseedor vencido estas mejoras ya que si hubiere estado en su poder, también las debería haber hecho. Estas mejoras pueden ser: primero, obras materiales, caso en que el reivindicante abonará al poseedor estas mejoras en cuanto

hubieren sido realmente necesarias pero reducidas a lo que valgan al tiempo de la restitución porque antes el poseedor gozó de estas mejoras; y, segundo, obras inmateriales, caso en que el reivindicante las pagará en cuanto le aprovechen y se hubieren ejecutado con mediana inteligencia y economía.

Con respecto a las mejoras útiles, se hace el distingo entre el poseedor de buena o de mala fe y se atiende al momento en que se ejecutan las mejoras y no al momento en que se inicia la posesión. Debe rembolsar al poseedor de buena fe las mejoras útiles existiendo la buena fe al momento en que ellas se ejecutan. Se da al reivindicador el derecho optativo según el cual puede elegir entre pagarle al poseedor de buena fe el valor de las mejoras útiles o bien el aumento de valor que la cosa hubiere experimentado. El poseedor de mala fe no tiene derecho a que se le restituyan las mejoras útiles sino que se le autoriza a llevarse los materiales que hubiere invertido en la cosa siempre que ellos puedan separarse sin detrimento de la cosa y si, además, el reivindicante se niega a pagar el valor de esos materiales. Se entiende que la separación no ocasiona detrimento a la cosa cuando esta no queda en peores condiciones de las que estaba al hacer las mejoras. Si los materiales no se pueden sacar sin detrimento de la cosa el poseedor de mala fe pierde esas mejoras.

Con respecto a las mejoras voluptuarias, el reivindicador no está obligado a pagarlas ni al poseedor de buena fe ni al poseedor de mala fe, sino que ambos tendrán el derecho de llevarse los materiales siempre que el reivindicante no se allane a pagarles el valor de dichos materiales. El poseedor de buena y mala fe está colocado en igualdad de condiciones.

c) Derecho de retención del poseedor vencido.

El artículo 914 del CC autoriza al poseedor vencido para retener la cosa, es decir, le da el derecho legal de retención, hasta que el reivindicante verifique el pago o se lo asegure a su satisfacción. Los bienes retenidos se equiparan a los bienes dados en prenda e hipoteca, para los efectos de las preferencias y de las realizaciones, conforme al artículo 546 del CC.